การขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาการจำกัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณา

โดย

นางสาวศัลยา ชาญศรีสมุทร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554

Trial detention : Studies limitations on the duration of trial detention

By

Miss Sunlaya Charnsrismoot

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Law

Criminal Law

Faculty of Law

Thammasat University

2011

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

ของ

นางสาวศัลยา ชาญศรีสมุทร

เรื่อง

การขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาการจำกัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณา

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. คณิต ณ นคร)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(อาจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล)

บทคัดย่อ

การขังระหว่างพิจารณาของประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 บัญญัติให้ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ โดยการขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทยมีข้อพิจารณาและประเด็นปัญหาที่สำคัญ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง บทบาทของศาลกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา กล่าวคือ การพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาไม่มีการแยกแยะความเป็นเหตุหลักและเหตุรองของการขังระหว่างพิจารณา โดยจะพิจารณาเหตุแห่งความร้ายแรงของความผิดซึ่งเป็นเหตุรองที่สามารถปล่อยชั่วคราวได้ ในลักษณะเดียวกันกับเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น ซึ่งเป็นเหตุหลักที่ไม่สามารถปล่อยชั่วคราวได้ จึงเกิดกรณีของการขังระหว่างพิจารณาโดยไม่จำเป็นซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มักมีความเข้าใจว่าเมื่อศาลมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้ว ต้องเอาตัวจำเลยไว้ในระหว่างพิจารณาจนกว่าจะมีคำพิพากษาเสมอ ดังนั้นเมื่อมีการขังระหว่างพิจารณาแล้วจึงไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในช่วงระยะเวลาระหว่างระยะเวลาที่มีการขังระหว่างพิจารณานั้นอีกต่อไป

ประการที่สอง การขังระหว่างพิจารณาไม่พบการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด กล่าวคือ เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลแล้วไม่มีการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา ดังนั้น หากจำเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจสั่งขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล

ประการที่สาม ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาของจำเลยแต่ละคนนั้น แม้ว่าจำเลยจะถูกฟ้องตามฐานความผิดที่มีความร้ายแรงหรืออัตราโทษจำคุกแตกต่างกันเพียงใด ก็สามารถถูกขังระหว่างพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการพิจารณาถึงสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องและไม่พบว่ามีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นโดยไม่มีการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาอย่างจริงจังและไม่มีการจำกัด

ระยะเวลากระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยเกินสมควร ทั้งในกรณีที่มีการขังระหว่างพิจารณายาวนานและต่อมาศาลมีคำพิพากษายกฟ้องหรือให้ลงโทษจำคุกเท่ากับหรือเกินกว่าระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมุ่งให้ความสำคัญกับบทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยและการตรวจสอบดุลพินิจของศาลในการใช้ดุลพินิจขังจำเลยระหว่างพิจารณา โดยการเพิ่มบทบาทเชิงรุกของศาลในการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเพิ่มมากขึ้นทั้งช่วงก่อนและระหว่างมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณาและกำหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาและระยะเวลาขังระหว่างพิจารณานั้นควรมีสัดส่วนตามอัตราโทษจำคุกของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องหรือระดับความร้ายแรงของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง อีกทั้งควรมีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาด้วย เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่จำเลยว่าจะต้องอยู่ในอำนาจรัฐโดยการขังระหว่างพิจารณาในระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็น และเป็นระยะเวลาที่ได้สัดส่วนและมีจำกัดระยะเวลาสูงสุด ย่อมจะทำให้จำเลยได้การคุ้มครองตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด (Presumption of Innocence) มากยิ่งขึ้น

Abstract

In Thailand, the rules of detention during trial are stated in section 88 of the Criminal Procedural Code of Thailand. The Court shall order either to detent or release the defendant when court accepts the charge and defendant has been arrested, in case of individual plaintiff filing the suit, or when the public prosecutor enters a charge in court, in case of public prosecutor doing. The detention during trial in Thailand has its crucial aspects to be considered, following:

Firstly, the role of the court toward the protection of right and freedom of defendant needs to be deliberated. In particular, considering process of detention does not require enough evidence to differentiate between main ground and subordinate ground of the cases. This is to say, even the severe case that the defendant is not allowed to liberate, the defendants are required of detention the same way as minor cases that detention is not necessary. Therefore, it leads to the unnecessary detention that causes the negative impact to the defendant's right of freedom. Moreover there is always understood that when the court ordered the trial detention . All defendants have to be detained until the trial has ended with sentencing. Therefore, there is not considered the necessity of the trial detention during the period of detention pending longer.

Secondly, the process of check and balance of detention is not found. In particular, when the trial has been started proceeding, there is not limitation of detention. Therefore, if the motion of temporary release is denied, the court may rule the detention until the trial has ended with sentencing.

Thirdly, the length of detention of distinguish defendant is not verified specifically. All defendants have to be detained till the hearing process is done regardless of cases and sentences disparities. There is no time line indicated in particular between the degree of the sentence and the maximum length of remand.

As stated above, it is obvious that detention during trial process without considering the necessity and controlling period leads to the constraint of defendant's

right and freedom, both the case of long period of detention and ruling in afterward of dismissal or imprisonment being equal to or more than the period of detention. Therefore, problem analysis should be conducted by enhancing the role of court toward defendant's right and freedom advocacy and profoundly investigate court's decision toward the detention. The solutions are to enhance the proactive role of court toward defendant's right and freedom both before and after the trial process. Moreover, to determine the detention period based on the necessity and the basis of detention objective, to ensure the visibility of defendant as long as the complexity of trial procedure. Accordingly, the portion period of detention should be conducted based on the degree of the sentence, and also the maximum length of the detention to ensure the rational obligation in order to inform the defendant the exact right. Consequently, determining appropriate period of detention encourages the presumption of innocence in order to protect the right and the freedom of defendants.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นอย่างสูงที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยท่านได้ให้ความรู้ คำแนะนำ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี รวมทั้งให้ความเมตตาอบรมสั่งสอนและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. คณิต ณ นคร ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต และท่านอาจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ คุณหมอประดิษฐ์ ประทีปวณิช หน่วยระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช และพี่ก้อย นักวิจัยใจดี ที่ดูแลอาการเจ็บป่วยของผู้เขียนและทำให้ผู้เขียนรู้วิธีดูแลตนเองให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

ขอขอบคุณ ท่านพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผอ. กาญจน์ วรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 8 ผู้บังคับบัญชา ที่สนับสนุนให้ผู้เขียนลาศึกษา และให้ความห่วงใยและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง ภา พี่หนุ่ย และใจ+ เพื่อนร่วมงาน ที่ช่วยรับภาระงานแทนผู้เขียนในระหว่างลาศึกษา

ขอขอบคุณ พี่เก็จ พี่คุณ และเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา รุ่น 50 ทุกท่าน ยุ เฟิร์ส ออมสิน เปรม อ้อม น้องดาว น้องโบ้ท พี่ขวัญ รวมถึงผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ไม่อาจเอ่ยนามได้หมด ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ผู้เขียนเสมอมา

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณพ่อและแม่ ที่ให้การสนับสนุนผู้เขียนในทุกเรื่อง และเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งในชีวิตของผู้เขียน รวมถึงน้องชายที่ดูแลและเป็นเพื่อนที่ดีของผู้เขียนในทุกช่วงเวลา

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบความดีทั้งหมดให้แก่บิดา มารดา คณาจารย์ รวมถึงทุกท่านที่มีพระคุณต่อผู้เขียน ส่วนข้อบกพร่องทั้งหมด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ศัลยา ชาญศรีสมุทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2554

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (1)

กิตติกรรมประกาศ (5)

บทที่

1. บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4
1.3 สมมติฐานการศึกษา 4
1.4 วิธีการศึกษา 4
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขัง ระหว่างพิจารณา 6

2.1 ข้อความคิดเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณา 6
2.1.1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 6
2.1.1.1 วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 7
(1) การควบคุมอาชญากรรม 7
(2) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 7
2.1.1.2 ระบบการดำเนินคดีอาญา 8
(1) ระบบไต่สวน 9
(2) ระบบกล่าวหา 9

2.1.1.3 ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา 10
(1) การดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน 10
(2) การดำเนินคดีชั้นศาล 10
(3) การดำเนินคดีชั้นบังคับโทษ 11
2.1.2 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา 11
2.1.2.1 การควบคุมตัวระหว่างคดี 11
2.1.2.2 จุดมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดีกับเหตุการออกหมายจับและเหตุการออกหมายขัง 15
2.1.2.3 การขังระหว่างพิจารณา 16
2.1.3 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา 17
2.1.3.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา 17
2.1.3.2 หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ 19
2.1.3.3 สิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว 20
2.1.3.4 หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว 21
2.2 ข้อความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา 23
2.2.1 หลักการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นศาล 23
2.2.1.1 หลักการตรวจสอบถ่วงดุล 23
2.2.1.2 ขอบเขตในการตรวจสอบถ่วงดุล 25
2.2.1.3 ลักษณะการตรวจสอบถ่วงดุล 26
(1) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร 26
(2) การตรวจสอบถ่วงดุลจากภายนอกองค์กร 29
2.2.2 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา 30

2.2.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 30
2.2.2.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 30
2.2.2.3 กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษ ค.ศ. 1955 32
2.2.2.4 หลักการเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุก ค.ศ. 1988 32
2.3 ข้อความคิดเกี่ยวกับการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา 34
2.3.1 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ 34
2.3.2 หลักความได้สัดส่วน 35
2.3.2.1 ข้อความคิดของหลักความได้สัดส่วน 35
2.3.2.2 สาระสำคัญของหลักความได้สัดส่วน 36
(1) หลักความเหมาะสม 36
(2) หลักความจำเป็น 37
(3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 37
2.3.2.3 หลักความได้สัดส่วนกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 38

3. การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในต่างประเทศ 39

3.1 ประเทศญี่ปุ่น 39
3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา 39
3.1.1.1 ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญา 39
3.1.1.2 ขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญา 40
3.1.2 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา 40
3.1.3 การขังระหว่างพิจารณา 42
3.1.3.1 เหตุของการขังระหว่างพิจารณา 42

3.1.3.2 การยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาเหตุในการขัง
โดยเปิดเผยในศาล 44
3.1.3.3 ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา 45
3.1.3.4 เหตุสิ้นสุดการขังระหว่างพิจารณา 46
(1) กรณีครบระยะเวลาขังหรือศาลมีคำพิพากษา 46
(2) การยกเลิกการขังระหว่างพิจารณา 46
(3) การปล่อยชั่วคราว 48
(4) การพักการขังระหว่างพิจารณา 49
3.2 ประเทศฝรั่งเศส 50
3.2.1 ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา 50
3.2.1.1 ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญา 51
3.2.1.2 ขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญา 53
3.2.2 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่าง
พิจารณา 54
3.2.3 การขังระหว่างสอบสวน 55
3.2.3.1 เหตุของการขังระหว่างสอบสวน 55
3.2.3.2 การไต่สวนเพื่อมีคำสั่งขัง 56
3.2.3.3 ระยะเวลาขังระหว่างสอบสวน 57
3.2.3.4 การปล่อยชั่วคราว 62
3.2.4 การขังระหว่างรอการเริ่มพิจารณา 63
3.2.4.1 กรณีความผิดมัธยโทษ 63
3.2.4.2 กรณีความผิดอุกฤษโทษ 64
3.2.5 การขังระหว่างพิจารณา 64

4. การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทย 66

4.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา 66
4.1.1 หลักการพื้นฐานของขังระหว่างพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 66
4.1.2 เหตุการออกหมายขังระหว่างพิจารณา 68
4.1.3 กำหนดระยะเวลาของหมายขังระหว่างพิจารณา 69
4.2 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกขังระหว่างการพิจารณา 70
4.2.1 หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา เป็นผู้บริสุทธิ์ 70
4.2.2 สิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว 70
4.2.3 สิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 71
4.3 การตรวจสอบและถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา 72
4.3.1 การปล่อยชั่วคราว 72
4.3.2 การร้องขอให้ปล่อยจากการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 74
4.4 วิเคราะห์การขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทย 75
4.4.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา 75
4.4.1.1 ลักษณะของเหตุแห่งการออกหมายขังกับการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา 76
4.4.1.2 ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 77
(1) การขังหรือปล่อยชั่วคราวจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 77
(2) หลักการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรมกับการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา 78
4.4.2 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบการขังระหว่างสอบสวนกับการขังระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 79
4.4.2.1 หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา 79

4.4.2.2 จุดมุ่งหมายในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลย
ไว้ในอำนาจรัฐ 79
4.4.2.3 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา
และจำเลย 81
4.4.2.4 การตรวจสอบและถ่วงดุลความจำเป็นในการเอาตัว
ผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจรัฐ 81
(1) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร 81
(2) การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก 82
(3) การตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลา 83
4.4.3 ข้อพิจารณาตามหลักความได้สัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่าง
พิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง 87

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 90

5.1 บทสรุป 90
5.2 ข้อเสนอแนะ 101

บรรณานุกรม 106

ประวัติการศึกษา 113

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการชี้ขาดข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นและหากมีการชี้ขาดว่าได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้ว ก็จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดต่อไป ดังนั้น วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงมุ่งไปสู่การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อค้นหาและตรวจสอบความจริงชี้ขาดเรื่องที่มีการกล่าวหาและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การมุ่งค้นหาความจริงแต่เพียงอย่างเดียวอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะต่อผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การดำเนินคดีอาญาที่ดีจะต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างอำนาจรัฐในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน กระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องเปิดเผย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

ในการดำเนินคดีอาญา แม้บุคคลจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดและถูกดำเนินคดีอาญาก็ตาม ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดและต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเสมอว่า บุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลัก Presumption of innocence และจะปฏิบัติต่อผู้ถูกดำเนินคดีเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้ อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการบังคับต่าง ๆ กับผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญายังมีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรลุผล ดังนั้นการใช้มาตรการบังคับซึ่งล้วนแล้วแต่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องมีขอบเขตจำกัด กล่าวคือ สามารถกระทำได้เมื่อมีกฎหมายให้อำนาจและต้องกระทำภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น

การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้นนั้น มาตรการบังคับซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยเป็นอย่างมาก คือ การขังระหว่างการพิจารณา[1] อันเป็นการจำกัดเสรีภาพ

---

[1]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้

ในร่างกายและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของจำเลย ซึ่งศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความจำเป็นในการขังตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยหลักแล้วการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐเป็นข้อยกเว้น หากไม่มีความจำเป็นก็ต้องปล่อยชั่วคราวแก่จำเลยเสมอ เพื่อมิให้การดำเนินคดีอาญาต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของจำเลยโดยไม่มีความจำเป็น

ปัจจุบันมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณามากขึ้นทุกปี ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ในส่วนของผู้ต้องขังการถูกขังทำให้ต้องเสียโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เจือจุนครอบครัว เรือนจำที่แออัด ขาดสุขลักษณะที่ดี ทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกาย ในด้านจิตใจ ผู้ต้องขังมักมีความกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้คดีและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ส่วนครอบครัวของผู้ต้องหานั้นก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว รวมทั้งปัญหาสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญคือการยอมรับจากสังคมภายนอก ในส่วนของภาครัฐเอง ก็ต้องเสียทั้งเงินงบประมาณและบุคลากรจำนวนมากในการดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่อยู่ในเรือนจำ[2]

ทั้งนี้ ตามสถิติของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553[3] ปรากฏว่า มีผู้ต้องขังระหว่างไต่สวน - พิจารณา เป็นร้อยละ 5.15 ของผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ และจากการวิจัยพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการขังระหว่างพิจารณาเท่ากับ 1 ปี 2 เดือน[4] โดยการขังระหว่างพิจารณาในบางคดีนั้นมีระยะเวลาที่ยาวนานอันเนื่องมาจากมักมีการขังระหว่างพิจารณาจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล และการพิจารณาคดีของศาลมีระยะเวลานานและไม่มีกรอบเวลา ส่งผลกระทบต่อจำเลยที่ต้องถูกขังระหว่างพิจารณาซึ่งแม้จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดของก็ตาม แต่การถูกขังระหว่างพิจารณาด้วยระยะเวลาที่ยาวนานก็เสมือนเป็นการถูกลงโทษอยู่นั่นเอง โดยมีทั้งกรณีที่มีการขังระหว่างพิจารณานานและ

---

[2]เพลินใจ แต้เกษม และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2547) , น. 61 - 84.

[3]สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ, http://www.correct.go.th /correct2009 /stat. html ,วันที่ 1 ธันวาคม 2553.

[4]เพลินใจ แต้เกษม และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2* , น. 52.

ต่อมาศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง และกรณีที่ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาเกินกว่าโทษจำคุกตามคำพิพากษาเสียอีก ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำเลยเป็นอย่างมาก

จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณามักขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้น การพิจารณาคดีที่ล่าช้าส่งผลให้มีการขังระหว่างพิจารณาที่ยาวนาน กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของจำเลยผู้ซึ่งได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างมาก และแม้ปัจจุบันศาลจะใช้ระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องซึ่งทำให้ระยะเวลาในช่วงของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลสั้นลง หากแต่ระยะเวลาในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีต่อเนื่อง กล่าวคือ นับแต่จำเลยถูกขังระหว่างพิจารณาจนถึงวันพิจารณา นั้น ยังคงมีระยะเวลานาน

นอกจากนี้ แม้รัฐจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่จำเลยในคดีอาญาอันเนื่องจากการคุมขังอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึ่งมีหลักการโดยสรุปว่า ให้จำเลยในคดีอาญามีสิทธิได้รับทดแทนและค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เป็นจำเลยซึ่งถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และต่อมาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าหรือปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดแล้วก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการเยียวยาความเสียหายของรัฐ (state responsibility) ที่มิได้เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเยียวยาให้ของรัฐในกรณีจำกัด ซึ่งแม้แต่กรณีที่จำเลยถูกขังระหว่างพิจารณามากกว่าโทษจำคุกตามคำพิพากษาก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และท้ายที่สุดแม้เป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับค่าทดแทนแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินที่ได้รับไม่สามารถเทียบกับการสูญเสียอิสรภาพระหว่างถูกขังระหว่างพิจารณาได้เลย

การขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นโดยไม่มีการจำกัดระยะเวลาโดยสามารถขังระหว่างพิจารณาได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานั้น ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาเอง สังคม และยังเป็นปัญหาต่อความเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม จึงควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา เพื่อเป็นการให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่จำเลยให้ได้รับการคุ้มครองตามหลัก Presumption of Innocence มากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพระหว่างพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2. เพื่อศึกษาบทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

3. เพื่อศึกษาแนวคิดในการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณาโดยการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นของต่างประเทศ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นของประเทศไทยสอดคล้องกับหลัก Presumption of Innocence มากขึ้น

1.3 สมมติฐานการศึกษา

การขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นโดยไม่มีการจำกัดระยะเวลากระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด (Presumption of Innocence) เกินสมควร จึงควรมีการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่จำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา และเป็นการตรวจสอบดุลพินิจของศาลในการใช้ดุลพินิจขังจำเลยระหว่างพิจารณา

1.4 วิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสารทางวิชาการ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาของศาล และข้อมูลจากสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อนำมารวบรวมเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อเสนอแนะต่อไป

1.5 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาเฉพาะการจำกัดระยะเวลาขังจำเลยระหว่างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้น (Pending Trial Detention)

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพระหว่างพิจารณาในกระบวนยุติธรรมทางอาญา
2. ทราบบทบาทของศาลที่ควรในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
3. ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น
4. ทราบแนวทางในการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นของต่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นของประเทศไทยสอดคล้องกับหลัก Presumption of Innocence มากขึ้น

บทที่ 2

แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ได้แก่ ข้อความคิดเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณา ข้อความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา และข้อความคิดเกี่ยวกับการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา เพื่อเป็นหลักการพื้นฐานในการศึกษาการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาต่อไป

2.1 ข้อความคิดเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณา

2.1.1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เมื่อเกิดการกระทำความผิดอาญา เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นเครื่องมือของรัฐในการดำเนินการดังกล่าว โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ กระบวนการนับแต่มีการกระทำความผิดอาญา การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่การสอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาพิพากษา ตลอดจนการบังคับโทษภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ขาดข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น และหากมีการชี้ขาดว่าได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดต่อไป[1] และโดยที่การชี้ขาดข้อเท็จจริงในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนฟ้องหรือขั้นตอนการสอบสวนฟ้องร้อง หรือขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา อาจมีการดำเนินการที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาได้ แม้ว่าการดำเนินคดีอาญาได้กระทำไปเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม การดำเนินคดีอาญา

---

[1]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ความโปร่งใสและการตรวจสอบกระบวนยุติธรรมทางอาญา ตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540,” บทบัณฑิตย์, เล่ม 54 , ตอน 4 (ธันวาคม 2541) , น. 57.

ในขั้นตอนต่าง ๆ จึงต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย

2.1.1.1 วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ กล่าวคือ

(1) การควบคุมอาชญากรรม (Crime control)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาชญากรรมนี้ มุ่งค้นหาและตรวจสอบความจริงของเรื่องเพื่อชี้ขาดและลงโทษผู้กระทำความผิด ปราบปรามการกระทำความผิด และป้องกันและควบคุมการก่ออาชญากรรม

(2) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (Due process)

วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนี้ได้รับอิทธิพลจาก 3 หลักการ คือ หลักสิทธิมนุษยชน แนวคิดเสรีนิยม หลักประชาธิปไตย กล่าวคือ ในนิติรัฐ รัฐต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยต้องให้หลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ดังนั้น แม้การกระทำผิดอาญาจะเป็นการกระทำที่กระทบต่อสังคมโดยรวม หากแต่การมุ่งค้นหาความจริงเพียงอย่างเดียวอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได้ การดำเนินคดีอาญาจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาด้วย อย่างไรก็ดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น มิได้หมายความว่ารัฐจะไม่สามารถกระทำการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาได้เลย เพราะรัฐยังคงต้องพยายามค้นหาความจริงเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยการกระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้เท่านั้นและจะต้องไม่กระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจนั้น จากอิทธิพลของหลักการทั้งสามดังกล่าวข้างต้น การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องอยู่บนหลักการของการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดีจึงต้องประสานวัตถุประสงค์ทั้งสองประการดังกล่าวซึ่งมีความขัดแย้งให้เกิดความสมดุลกัน และต้องมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะมาควบคุม

การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานของรัฐให้ใช้อำนาจภายในขอบเขตของกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมใช้อำนาจอย่างมีภาวะวิสัย (Objectivity) ไม่ใช่ใช้อย่างอำเภอใจ (Subjectivity) และรัฐจะต้องกำหนดกลไกที่จะให้องค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกัน (check and balance) ระหว่างองค์กร นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือควบคุมกันเองภายในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่แล้ว[2] เพื่อทำให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ[3]

ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองสังคม ปราบปรามและป้องกันการกระทำความผิด และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีภารกิจในการทำให้กฎหมายอาญามีผลบังคับและทำให้ภารกิจของกฎหมายอาญาเกิดผลอย่างจริงจัง[4] ดังนั้น กฎหมายทั้งสองส่วนนี้จึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสองประการดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง

2.1.1.2 ระบบการดำเนินคดีอาญา[5]

หลักเกณฑ์การจำแนกระบบการดำเนินคดีอาญานั้น ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ

---

[2]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล , *เพิ่งอ้าง* , น. 57.

[3]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา , (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2551) ,น. 16.

[4]คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2549) , น. 40.

[5]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล , “การนำรูปแบบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป”, รายงานการวิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) , รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม , 2548 , น. 5 - 8.

ก. มีองค์กรที่ทำหน้าที่ที่ต่างกันเพื่อถ่วงดุลอำนาจ กล่าวคือ ต้องมีการพิจารณาว่ามีการแยกองค์กรที่ทำหน้าที่ “สอบสวน – ฟ้องร้อง” ออกจากองค์กรที่ทำหน้าที่ “พิจารณา – พิพากษา” หรือไม่

ข. มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในการดำเนินคดีหรือไม่

(1) ระบบไต่สวน (Inquisitorial System)

ระบบการดำเนินคดีในโลกนี้จะเริ่มพัฒนาจาก “ระบบไต่สวน” ก่อน กล่าวคือ ในการดำเนินคดีอาญาไม่มีการแยกองค์กรที่ทำหน้าที่ “สอบสวน – ฟ้องร้อง” ออกจากองค์กรที่ทำหน้าที่ “พิจารณา – พิพากษา” แต่การดำเนินคดีทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินการของบุคคลหรือองค์กรเดียว โดยศาลจะมีบทบาทหน้าที่ทั้งการสอบสวน ฟ้องร้อง และพิจารณาพิพากษา และผู้ถูกกล่าวหาตกเป็น “กรรมในคดี” ไม่ได้รับการรับรองสิทธิต่าง ๆ แต่อย่างใด และมีฐานะเป็นเพียงผู้ถูกซักฟอกจากการไต่สวนของศาลเท่านั้น

(2) ระบบกล่าวหา (Accusatorial System)

ระบบกล่าวหาเป็นระบบการดำเนินคดีที่เข้ามาแทนที่ระบบการไต่สวน เนื่องจากแนวความคิดเรื่องเสรีนิยม (liberalism) ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยระบบกล่าวหานี้มีการแยกองค์กรที่ทำหน้าที่ “สอบสวน – ฟ้องร้อง” ออกจากองค์กรที่ทำหน้าที่ “พิจารณา – พิพากษา” โดยองค์กรทั้งสองมีอิสระต่อกันและมุ่งให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลกัน และผู้ถูกกล่าวหาได้รับการยกฐานะเป็น “ประธานในคดี” วิธีพิจารณาความอาญาจึงให้สิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ถูกกล่าวหา และเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับหลักประกันว่าจะถูกลงโทษต่อเมื่อมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้น

จากระบบการดำเนินคดีอาญาทั้งสอง จะเห็นได้ว่าแนวคิดของระบบกล่าวหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ในขณะที่แนวคิดของระบบไต่สวนตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะในการดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิด ซึ่งหากใช้เกณฑ์แนวคิดการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน อาจกล่าวได้ว่า ระบบกล่าวหามีแนวโน้มไปทางการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(Due process) ในขณะที่ระบบไต่สวนเน้นหนักไปที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime control)[6]

2.1.1.3 ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา

ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน (Pre – trial stage) การดำเนินคดีชั้นศาล (Trial stage) และการดำเนินคดีชั้นบังคับโทษ (Execution stage)

(1) การดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน (Pre – trial stage)

การดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานนี้เป็นขั้นตอนการสอบสวน – ฟ้องร้อง ได้แก่ การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้รู้ตัวผู้กระทำความผิดและนำตัวมาดำเนินคดี อันจะนำไปสู่การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดและนำพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เสนอต่อศาล[7] เพื่อนำไปสู่การชี้ขาดในการดำเนินคดีต่อไป และองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสอบสวน – ฟ้องร้อง โดยทั่วไป ได้แก่ องค์กรพนักงานสอบสวน องค์กรพนักงานอัยการหรือองค์กรอื่น เช่น ศาล เจ้าพนักงานของรัฐ ฯลฯ

การดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานนี้ มีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ การดำเนินคดีเป็นการลับ การดำเนินคดีเป็นลายลักษณ์อักษร และการดำเนินคดีไม่ต้องทำต่อหน้าผู้ต้องหา

(2) การดำเนินคดีชั้นศาล (Trial stage)

การดำเนินคดีชั้นศาลนี้เป็นขั้นตอนการพิจารณา – พิพากษา ได้แก่ การชี้ขาดข้อเท็จจริงที่มีการฟ้องร้องและกำหนดผลของการดำเนินคดี โดยขั้นตอนการชี้ขาดข้อเท็จจริงเรียกว่า การพิจารณา และขั้นตอนการกำหนดผลของการดำเนินคดี เรียกว่า การพิพากษา และองค์กรที่ทำหน้าที่ในการพิจารณา – พิพากษานี้ มีเพียงองค์กรเดียวคือศาลซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ

---

[6]สัญลักษ์ ปัญวัฒนลิขิต, “ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน และชั้นศาล” , (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552) , น. 10 -11.

[7]วิลาสินี รอตฤดี, “ปัญหากฎหมายในการเยียวยาแก่จำเลยในการพิจารณาคดีอาญาที่ผิดพลาด”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548) ,น. 11.

การดำเนินคดีชั้นศาลนี้ มีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ การดำเนินคดีโดยเปิดเผย การดำเนินคดีด้วยวาจา และการดำเนินคดีต้องทำต่อหน้าจำเลย

(3) การดำเนินคดีชั้นบังคับโทษ (Execution stage)

การดำเนินคดีชั้นบังคับโทษนี้ ได้แก่ ขั้นตอนการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ซึ่งเรียกว่า ขั้นตอนการบังคับโทษ

จากขั้นตอนการฟ้องคดีอาญาทั้งสามขั้นตอนนั้น จะเห็นว่าเป็นผลมาจากระบบการดำเนินคดีระบบกล่าวหาที่มีการแยกองค์กรที่ทำหน้าที่สอบสวน – ฟ้องร้อง ออกจากองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา โดยหลักการดำเนินคดีในแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรนั้น

2.1.2 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา

2.1.2.1 การควบคุมตัวระหว่างคดี

การควบคุมตัวระหว่างคดี คือ การจำกัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับรัฐใน “การดำเนินคดีชั้นกำหนดคดี” หรือเป็นหลักประกันสำหรับรัฐใน “การดำเนินคดีชั้นบังคับคดี” หรือเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับรัฐทั้งสองประการดังกล่าว[8] ในที่นี้หมายถึง การควบคุมและการขัง

การดำเนินคดีอาญาในปัจจุบัน แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นประธานในคดี แต่การใช้มาตรการบังคับของรัฐกับผู้ถูกกล่าวหาก็ยังมีความจำเป็น เพราะหากรัฐไม่อาจใช้มาตรการบังคับกับผู้ถูกกล่าวหาได้เลยแล้ว การดำเนินคดีอาญาของรัฐย่อมไม่อาจกระทำได้หรือยากต่อการที่รัฐจะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหานั้น การควบคุมตัวระหว่างคดีจึงอาจมีความจำเป็นที่ต้องกระทำ[9] เพื่อเอาตัวบุคคลผู้ถูกกล่าวหานั้นมาไว้ในอำนาจรัฐ

การควบคุมตัวระหว่างคดีกับการเรียกและการจับเป็นเรื่องเดียวกัน ฉะนั้น เหตุที่จะออกหมายจับกับเหตุที่จะควบคุมหรือขังไว้ต่อไปหลังการจับจึงเป็นเหตุเดียวกัน[10] กล่าวคือ การที่ต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาก็เพราะกรณีมีความจำเป็นต้องได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เพื่อสอบสวนปากคำผู้ต้องหา และเมื่อได้ทำการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาที่ได้

---

[8]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 341.

[9]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 338.

[10]คณิต ณ นคร , “บทบาทของศาลในคดีอาญา”, วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ , ปีที่ 1 , (มกราคม - มิถุนายน 2544) ,น. 57.

เรียกมานั้นแล้ว ตามปกติก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นไป และการที่ต้องจับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เพราะกรณีอาจมีความจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลผู้นั้นมาไว้ในอำนาจรัฐ และเมื่อความจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลผู้นั้นไว้ในอำนาจรัฐไม่มีหรือหมดไปในภายหลัง ก็ต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับนั้นไปเช่นเดียวกัน[11] ดังนั้น บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจับ การควบคุม การขัง และการปล่อยชั่วคราว จึงเป็นบทบัญญัติที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ การตีความบทบัญญัติดังกล่าวทั้งหมดจึงต้องตีความตามความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบของกฎหมาย คือ ถือว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการจับ การควบคุม การขัง และการปล่อยชั่วคราว เป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการกระทำตามจุดมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดี[12]

อย่างไรก็ดี การเรียกและการจับหาใช่เหตุที่ก่อให้เกิดอำนาจควบคุมตัวระหว่างคดีแก่เจ้าพนักงานหรือศาล แล้วแต่กรณี โดยอัตโนมัติไม่ แต่การควบคุมตัวระหว่างคดีจะต้องเกิดจากความจำเป็นที่ว่า หากไม่ควบคุมหรือขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าพนักงานหรือหากไม่ขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแล้ว การดำเนินคดีของเจ้าพนักงานหรือศาล แล้วแต่กรณี จะไม่อาจกระทำได้เท่านั้น ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดมุ่งหมายในการคุมขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว ยังเป็นเงื่อนไขที่ป้องกันมิให้เกิดสภาวะแห่งการลงโทษโดยกระบวนการอันเป็นการสอดคล้องกับแนวความคิดตามข้อสันนิษฐานในคดีอาญาที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิด[13]

การควบคุมตัวระหว่างคดีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ[14]

(1) เพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อย

เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนการฟ้องคดี (Pre – trial stage) เป็นขั้นตอนในการสอบสวนและการฟ้องร้อง การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถกระทำเพื่อประสงค์จะทราบ

---

[11]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 338.

[12]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 78.

[13]ทวีวัฒน์ ธาราจันทร์, “การชดใช้ค่าทดแทนโดยรัฐเนื่องจากการคุมขังอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540) ,น. 14.

[14]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 341 - 343.

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา และเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดนั้น[15]

ดังนั้น เมื่อการสอบสวนคดีอาญาเริ่มคลี่คลายไปถึงจุดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าคดีมีมูลและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากที่อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อไป และโดยที่ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านอันเป็นไปตาม “หลักฟังความทุกฝ่าย” เพื่อประกันสิทธิดังกล่าวกรณีจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องฟังคำแก้ตัวของผู้ต้องหา ในกรณีเช่นนี้จะต้องมีการเรียกหรือออกหมายเรียกหรือการขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพื่อดำเนินการต่อไป[16] และในการสอบสวนดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งดังกล่าวนั้น รัฐอาจมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการสอบสวนปากคำผู้ต้องหา เพราะหากไม่มีการสอบสวนผู้ต้องหาแล้ว การฟ้องผู้ต้องหาต่อไป (หากจำเป็นต้องกระทำ) ก็ย่อมไม่อาจกระทำได้ และเมื่อได้มีการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาแล้ว กรณีอาจมีความจำเป็นต้องควบคุมผู้ต้องหานั้นไว้ต่อไปอีก เพราะหากไม่มีการควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปแล้ว ผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ทำให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนคดีนั้นได้

(2) เพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย

เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาและพิพากษาคดี (trial stage) นั้นเป็นขั้นตอนการชั้นชี้ขาดข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่การพิพากษาคดีนั้น ๆ [17] ซึ่งในการดำเนินคดีอาญาในชั้นนี้มีความจำเป็นต้องมีตัวจำเลยในชั้นพิจารณาพิพากษา เนื่องจากจำเลยจะต้องปรากฏตัวอยู่จริง (Physical Presence) ในระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อให้จำเลยมีโอกาสได้รับรู้กระบวนพิจารณาทุกขั้นตอน ซึ่งกระบวนพิจารณาในศาลเหล่านั้นอาจเป็นผลดีหรือผลร้ายกับตัวจำเลยมากที่สุด ดังนั้นจำเลยจึงควรที่จะรับทราบและมีโอกาสต่อสู้หรือมีโอกาสเผชิญหน้ากับพยานที่เป็นปรปักษ์แก่ตน และสามารถที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ และพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองให้ศาลเห็นประจักษ์ว่าตนกระทำความผิดหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากจำเลยเป็นผู้ที่รับรู้เหตุการณ์ที่ตนถูกกล่าวหาได้ดีที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้จำเลยมีสิทธิเผชิญหน้ากับพยานที่เป็นปรปักษ์ (Right to Confront Witness) ซึ่งการเผชิญหน้ากันอาจส่งผลดีในแง่จิตวิทยาว่า

---

[15]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1* , น. 59.

[16]คณิต ณ นคร, “การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐกับการปล่อยชั่วคราว” ใน กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2553) , น. 57.

[17]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1* , น. 61.

พยานอีกฝ่ายไม่กล้าที่จะเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลย เพราะจำเลยมีสิทธิในการถามค้านพยานได้ (Right to Cross-Examination) รวมทั้งศาลก็สามารถค้นหาความจริงได้จากการที่คู่ความเผชิญหน้าต่อกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการแสดงออกในลักษณะที่เป็นพิรุธหรือเบิกความเท็จหรือไม่ และเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การที่จำเลยเป็นผู้ที่อาจต้องได้รับผลร้ายจากคำพิพากษา จำเลยจึงควรมีโอกาสที่จะได้รับรู้กระบวนพิจารณาในทุกขั้นตอน และรับทราบถึงพยานหลักฐานที่ได้นำสืบในชั้นพิจารณา ซึ่งจะส่งผลให้จำเลยสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่[18]

จากหลักการพิจารณาและสืบพยานซึ่งโดยหลักต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยเป็นดังกล่าวข้างต้นนั้น ในการฟ้องคดี พนักงานอัยการจึงต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมฟ้อง หรือต้องมีตัวจำเลยอยู่ในอำนาจของศาล ดังนั้น กรณีจึงอาจมีความจำเป็นต้องควบคุมจำเลยไว้ในระหว่างการดำเนินคดีกับจำเลยนั้นในชั้นศาล เพราะหากจำเลยหลบหนีย่อมทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีกับจำเลยนั้นได้ เว้นแต่ กรณีที่สามารถพิจารณาลับหลังจำเลยได้ เหล่านี้คือหลักประกันการมีตัวของจำเลยในการดำเนินคดีอาญาของรัฐนั่นเอง

(3) เพื่อประกันการบังคับโทษ

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษผู้กระทำผิดแล้ว ก็จะต้องมีการบังคับโทษเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล การมีตัวจำเลยไว้ในอำนาจรัฐจึงมีความจำเป็นเพื่อจะทำให้สามารถบังคับโทษตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ แม้จุดมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดีจะมี 3 ประการ แต่จุดมุ่งหมายหลักของการควบคุมตัวระหว่างคดี คือ เพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อย และเพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่วนจุดมุ่งหมายเพื่อการบังคับโทษเป็นเพียงจุดมุ่งหมายรอง เพราะกรณีอาจไม่มีการบังคับโทษในคดีนั้นเลยก็ได้แม้ศาลจะพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิด เป็นต้นว่า ศาลพิพากษาให้รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษจำเลยไว้[19] นอกจากนี้ การควบคุมตัวระหว่างคดีเป็นเรื่องของข้อยกเว้น กล่าวคือ โดยหลักเจ้าพนักงานและศาลจะต้องปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยเสมอ จะควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น คือการควบคุมตัวระหว่างคดีต้องเป็นการเอาตัวไว้เพราะความจำเป็นเพื่อให้บรรลุ

---

[18]ภัทร์รพี อุ่นใหม่ , “การพิจารณาคดีอาญาต่อหน้าจำเลย : ศึกษากรณีข้อยกเว้นและปัญหา”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550) , น. 19 – 21.

[19]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16* , น. 64.

วัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวระหว่างคดีดังกล่าวข้างต้นอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่อย่างใด เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเป็นกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย[20]

2.1.2.2 **จุดมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดีกับเหตุการออกหมายจับและเหตุการออกหมายขัง**[21]

จุดมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดีหรือความจำเป็นที่ต้องเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐนั้น แท้จริงคือเหตุแห่งการออกหมายจับและเหตุแห่งการออกหมายขัง ซึ่งตามกฎหมายเป็นเหตุเดียวกันนั่นเอง ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การเรียก การจับ การควบคุม และการขังเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของเหตุแห่งการออกหมายจับและเหตุแห่งการออกหมายขังกับการพิจารณาความจำเป็นของการควบคุมตัวระหว่างคดี กล่าวคือ

(1) เหตุออกหมายจับหรือเหตุออกหมายขังที่เป็นเหตุหลักและเหตุรอง

เหตุออกหมายจับหรือเหตุออกหมายขังนั้น มีทั้ง “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” และ “เหตุที่เป็นเหตุรอง” “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” คือ เหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น ส่วน “เหตุที่เป็นเหตุรอง” คือ เหตุแห่งความร้ายแรงของความผิด เมื่อกรณีใดมี “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” แล้ว การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐย่อมมีความจำเป็นเสมอ และส่งผลต่อไปว่าการปล่อยชั่วคราวย่อมกระทำไม่ได้ เพราะจะทำให้การดำเนินคดีไม่อาจเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและขัดขวางต่อการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดี

ส่วนกรณีใดมี “เหตุที่เป็นเหตุรอง” หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความร้ายแรงของความผิด กรณีนั้นย่อมไม่แน่นอนเสมอไปว่าการดำเนินคดีจะไม่อาจเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและจะขัดขวางต่อการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดี เหตุความร้ายแรงของความผิดจึงเป็น “เหตุที่เป็นเหตุรอง” และส่งผลต่อไปเกี่ยวกับการพิจารณาปล่อยชั่วคราว กล่าวคือ ในกรณีของเหตุรองนั้น อาจมีการปล่อยชั่วคราวได้ตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการคุ้มครองตามหลักการสันนิษฐานว่าไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) นั่นเอง

---

[20]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4*, น. 343 - 344.

[21]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16*, น. 60 - 63.

(2) เหตุออกหมายจับหรือเหตุออกหมายขังที่เป็นเหตุเกี่ยวกับการกระทำในอดีตและเหตุในทางป้องกัน

เหตุออกหมายจับหรือเหตุออกหมายขังนั้น มีทั้ง “เหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้กระทำมาแล้วในอดีต” และ “เหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจจะกระทำขึ้นในอนาคต” ซึ่งเหตุในกรณีหลังนี้คือเหตุในทางป้องกัน

“เหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้กระทำมาแล้วในอดีต” คือ เหตุแห่งความร้ายแรงของความผิด เหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี และเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ส่วน “เหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจจะกระทำขึ้นในอนาคต” คือ เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปก่ออันตรายประการอื่น เช่น การไปกระทำความผิดนั้นหรือความผิดอื่นซ้ำอีก

2.1.2.3 การขังระหว่างพิจารณา

การขังระหว่างพิจารณา คือ การควบคุมตัวระหว่างคดีโดยการจำกัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของจำเลย โดยเป็นการดำเนินกระบวนการดำเนินคดีในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (Trial stage) กล่าวคือได้ผ่านกระบวนการดำเนินคดีในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง (pre – trial stage) และมีการนำตัวจำเลยมาต่อศาลและเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นแล้ว โดยในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีนี้มีศาลเพียงองค์กรเดียวในฐานะผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในชั้นนี้ การขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นใช้ดุลพินิจของศาลพิจารณาความจำเป็นในการขังจำเลยในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น

เนื่องจากในการดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น มีหลักว่าต้องเป็นการดำเนินคดีโดยเปิดเผยเป็นการดำเนินคดีด้วยวาจา และการดำเนินคดีต้องทำต่อหน้าจำเลย ดังนั้นควบคุมตัวระหว่างคดีโดยการขังระหว่างพิจารณาจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ตามความมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดีเพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย นอกจากนี้หากศาลพิพากษาให้จำเลยต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว การขังระหว่างพิจารณายังเป็นการประกันการบังคับโทษกับจำเลยตามความมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดีเพื่อการบังคับโทษอีกด้วย

อย่างไรก็ดี หากเมื่อพิจารณาถึงจำเลยแต่ละรายแล้ว การดำเนินคดีในชั้นศาลนี้อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขังจำเลยไว้ระหว่างการพิจารณาเสมอไป กล่าวคือ แม้ไม่มีการขังจำเลยระหว่างพิจารณาก็สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาได้ตามปกติ ดังนั้นการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจว่าควรปล่อยจำเลยชั่วคราวหรือขังจำเลยระหว่างพิจารณา จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลย และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแก่จำเลยคนหนึ่งคนใด

2.1.3 **หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา**

เมื่อกรณีมีความจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐโดยการควบคุมตัวระหว่างคดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดการกระทบต่อเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของบุคคลนั้น ทั้งกรณีการควบคุมหรือการขัง การควบคุมหรือการขังดังกล่าวจึงต้องเป็นไปโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่งให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาและจุดมุ่งหมายในการควบคุมตัวระหว่างคดีประกอบกัน โดยรัฐต้องให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกควบคุมตัวระหว่างคดีในทุกขั้นของการดำเนินคดีนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับหลักการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา ได้แก่

2.1.3.1 **หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา** (Nullum crimen , nulla poena , nullum judicium sine lege)

หลักการดังกล่าวนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ว่า บุคคลจะมีความผิดและมีโทษทางอาญาได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น และหลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญานี้ไม่เพียงจะหมายถึงกฎหมายอาญาสารบัญญัติเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติด้วย กล่าวคือ องค์กรที่จะมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ ต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้รวมถึงการดำเนินการพิจารณาตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วย

ผลของหลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญานี้ ได้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ ให้ต้องบัญญัติกฎหมายอาญาสารบัญญัติและกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาสารบัญญัติ ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องบัญญัติกฎหมายอาญาให้มีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ และจะออกกฎหมายมาบังคับได้ก็แต่เฉพาะกับการกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังการประกาศใช้กฎหมายเท่านั้น โดยจะให้กฎหมายที่ออกมาใหม่มีผลย้อนหลังแก่การกระทำที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้กฎหมายไม่ได้

สำหรับในส่วนของกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัตินั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องประสานวัตถุประสงค์ 2 ประการ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ วัตถุประสงค์ในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีความขัดแย้งให้เกิดความสมดุลกัน โดยกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติในด้านองค์กรศาลนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องให้หลักประกันแก่ศาลในด้านความเป็นอิสระของตุลาการและกำหนดขอบเขตในการพิจารณาคดีอย่างชัดเจน ส่วนในด้านวิธีพิจารณาความนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่จำเลย เช่น การลงโทษจำเลยจะต้องฟังพยานหลักฐานจนแน่ใจว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพในการต่อสู้คดีของจำเลย โดยเฉพาะการห้ามมิให้มีการข่มขู่ ขู่เข็ญ หรือทรมานผู้ต้องหาหรือจำเลย[22] ทั้งนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยการนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมายอาญามาลงโทษ โดยได้บัญญัติมาตรการบังคับต่าง ๆ ตั้งแต่การจับ การค้น การควบคุม การขัง การสอบสวน การฟ้องคดีอาญา การพิจารณาและพิพากษาคดี โดยในขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ กฎหมายได้ให้อำนาจรัฐอย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญ ก็ได้วางกรอบกำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจรัฐไว้อย่างรัดกุม เพื่อมิให้การใช้อำนาจรัฐกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดีประการแรกจึงต้องมีลักษณะของความเป็นเสรีนิยม การกระทำใดในการค้นหาความจริงของรัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องกระทำภายใต้กรอบบทบัญญัติของกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมอ การกระทำที่กระทบต่อ

---

[22]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา” ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536) , น. 13-16.

สิทธิเสรีภาพของประชาชนทำได้เท่าที่มีกฎหมายบัญญัติและต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสาระสำคัญของสิทธิเสรีภาพนั้น

ประการที่สองวิธีพิจารณาความอาญาที่ดีจะต้องมีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ กระบวนการในการดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องเปิดเผย สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปตามกรอบบทบัญญัติของกฎหมาย มิให้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบจากบุคคลในองค์กรของรัฐ เป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่าการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

การดำเนินคดีอาญาจะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การกระทำที่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในสังคมที่ยอมรับสิทธิมนุษยชนนั้น มนุษย์ต้องมีสิทธิที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและต้องมีสิทธิที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี การดำเนินคดีอาญาจะเป็นการกระทำที่ทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ วิธีพิจารณาความอาญาที่ดีจึงต้องมีลักษณะเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อีกประการหนึ่งด้วย[23]

2.1.3.2 หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)

เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาในปัจจุบันได้รับอิทธิพลของความคิดในเรื่องเสรีนิยม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้การดำเนินคดีอาญาสมัยใหม่ยอมรับว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญามิได้เป็นกรรมในคดีอีกต่อไป หากแต่เป็นประธานในคดีซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริง หลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นี้ก่อให้เกิดผลตามหลักดังกล่าวหลายประการโดยเฉพาะในแง่ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ

---

[23]คณิต ณ นคร, “ความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการยุติธรรม” , ใน รวมบทความด้านวิชาการ ของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด , (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อักษร, 2540) , น. 428 - 430.

ความผิด[24] โดยตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาจะต้องมิได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการขังระหว่างพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าเนื่องจากจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณายังคงเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ความจริงในชั้นศาล กล่าวคือไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดตามคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น การปฏิบัติต่อจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักการนี้ด้วยเสมอ

2.1.3.3 **สิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว**

เนื่องจากตามหลักนิติรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหน้าที่หลักของรัฐ โดยหากรัฐจะกระทำการอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพใด ๆ ของประชาชน จะต้องเป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและจะกระทำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น การปล่อยชั่วคราวเป็นมาตรการในการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเพื่อผ่อนคลายหลักการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกคุมขังระหว่างคดีโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo) โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหา โดยหลักจะต้องมีการปล่อยชั่วคราวเสมอ โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นต้องควบคุมหรือขังระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยในการใช้สิทธิต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาพยานหลักฐานจากผู้ต้องหาหรือจำเลยเกินสมควร และป้องกันมิให้มีการลงโทษผู้ต้องหาหรือจำเลยล่วงหน้าก่อนที่จะพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริง การปล่อยชั่วคราวจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ประสานประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ของเอกชนไว้ด้วยกันนั่นเอง[25]

---

[24]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, "ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจำเลยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย", ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม , จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2538) , น. 452.

[25]อรวรรณ ไทยวานิช , "การปล่อยชั่วคราว" , (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539) ,น. 78 - 79.

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการขังระหว่างพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า เนื่องจากการขังระหว่างพิจารณาเป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยโดยตรง ดังนั้นการขังระหว่างพิจารณาจึงต้องมีการชั่งน้ำหนักประโยชน์ระหว่างประโยชน์ในการเอาตัวจำเลยไว้ในอำนาจของศาลกับสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่ต้องสูญเสียไปในระหว่างถูกขังระหว่างพิจารณา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการขังระหว่างพิจารณามีความจำเป็นและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามความมุ่งหมายของการควบคุมตัวระหว่างคดี จึงจะสามารถขังจำเลยนั้นในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลได้ ดังนั้น จำเลยทุกคนจึงมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และการขังระหว่างพิจารณาเป็นเพียงกรณียกเว้นเท่านั้น

2.1.3.4 **หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว** (Speedy Trial)

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรมแก่จำเลย[26] โดยเป็นหลักที่ใช้ในชั้นการพิจารณาคดีของศาลเท่านั้น เหตุที่ไม่นำไปใช้ในชั้นสอบสวนด้วยเพราะในการสอบสวนคดีของเจ้าพนักงานนั้นต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อตรวจสอบค้นหาความจริงของเรื่องในเบื้องต้นทั้งที่เกี่ยวกับการกระทำของผู้ต้องหาและเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหา ดังนั้นเจ้าพนักงานอาจมีความจำเป็นต้องใช้เวลาตามสมควร รวมทั้งอาจมีการใช้มาตรการบังคับประการ เช่น การจับหรือการคุมขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญาเพื่อช่วยให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุผล ซึ่งความจำเป็นเช่นนี้ย่อมจะต้องมีข้อจำกัดตามความเหมาะสม กฎหมายจึงได้กำหนดระยะเวลาในชั้นสอบสวนไว้โดยถือเอาประเภทแห่งความผิดเป็นหลัก กำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความจำเป็นแห่งการสอบสวนคดีและเพื่อเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ถูกดำเนินคดีอาญาเป็นสำคัญ หาใช่เป็นการกำหนดระยะเวลาที่บังคับให้เจ้าพนักงานต้องทำการสอบสวนคดีให้แล้วเสร็จโดยตรงไม่ เพราะในกรณีที่เจ้าพนักงานไม่อาจกระทำการสอบสวนคดีให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดระยะเวลานั้น ก็มีผลเพียงให้ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาที่ถูกคุมขังอยู่ได้รับเสรีภาพกลับคืนเท่านั้น แต่การสอบสวนคดีหรือการค้นหาความจริงของเจ้าพนักงานยังคงต้องดำเนินต่อไป สำหรับในชั้นพิจารณาคดีของศาลที่ต้องกระทำโดยเร็วนี้ก็เพื่อให้สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ของผู้ถูกดำเนินคดีอาญาได้รับการ

---

[26]บุศรา เกิดวิชัย , “สิทธิของจำเลยที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2534) ,น. 27.

กระทบกระเทือนน้อยที่สุด การพิจารณาคดีที่ล่าช้าย่อมทำให้จำเลยอยู่ในสภาพที่เลวร้ายตลอดการพิจารณาคดี[27]

ดังนั้น การดำเนินคดีอาญาที่ดีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมหรือรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ 2 ประการ กล่าวคือ เพื่อเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษ คำพิพากษาของศาลก็จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถส่งผลในด้านการป้องปรามไม่ให้เกิดการเอาเยี่ยงอย่างกันในสังคม ส่วนในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องนั้น ผู้ที่ถูกดำเนินคดีจะได้รับความเสียหายอันอาจเกิดจากมาตรการบังคับทางอาญาต่าง ๆ ที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพน้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะกรณีที่ถูกขังระหว่างพิจารณานั้น ความรวดเร็วในการพิจารณาคดียิ่งมีความสำคัญมากขึ้น[28] เพราะผู้ถูกดำเนินคดีอาญาที่เป็นผู้บริสุทธิ์จะได้รับเสรีภาพกลับคืนภายในระยะเวลาที่รวดเร็วหากมีคำพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการขังระหว่างพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าการพิจารณาคดีที่รวดเร็วย่อมส่งผลให้กรณีที่แม้ศาลจะใช้ดุลพินิจขังจำเลยระหว่างพิจารณา แต่จำเลยก็จะถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น โดยเป็นหลักประกันให้กับจำเลยผู้บริสุทธิ์ว่าจะได้รับการพิจารณาคดีภายในระยะอันสมควร[29] โดยหากเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก จำเลยก็จะเข้าสู่กระบวนการในชั้นบังคับโทษต่อไป แต่หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด จำเลยก็จะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติรัฐ

---

[27]ทวีวัฒน์ ธาราจันทร์ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13* , น. 10 -11.

[28]ทวีวัฒน์ ธาราจันทร์ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13* , น. 11.

[29]บุศรา เกิดวิชัย , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26* , น. 28.

2.2 ข้อความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา

2.2.1 หลักการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นศาล

เนื่องจากศาลเป็นองค์กรเดียวที่ใช้อำนาจตุลาการในการสั่งขังระหว่างพิจารณา อีกทั้งยังเป็นองค์กรเดียวอีกเช่นกันที่สามารถสั่งปล่อยชั่วคราวได้ การตรวจสอบและถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากการขังระหว่างพิจารณาเป็นการดำเนินคดีในชั้นศาล การตรวจสอบและถ่วงดุลคำสั่งขังระหว่างพิจารณาจึงย่อมเป็นไปตามหลักการและลักษณะการตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นศาล

2.2.1.1 หลักการตรวจสอบถ่วงดุล

จากอิทธิพลของหลักประชาธิปไตยซึ่งนำมาสู่วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ทำให้มีการแยกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมออกจากกัน เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องและองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในทุกขั้นตอนทั้งภายในและระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ กระบวนยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอนต้องสามารถถูกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบจากบุคคลในองค์กรในการดำเนินคดีอาญาของรัฐ และเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล หรือมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้เกิดการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดลงจนไม่อาจเป็นกระบวนการได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการควบคุมอาชญากรรมลดลง ทั้งยังกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมดำรงอยู่ได้ในที่สุดด้วย กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ

(1) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร

การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กรเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ตามลำดับบังคับบัญชาของแต่ละองค์กร ได้แก่ “การบังคับบัญชา” และ “การกำกับดูแล” โดยการบังคับบัญชาเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรนั้นในรูปของการบังคับบัญชา

ตามลำดับชั้น โดยให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจของตนในการตรวจสอบการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดกรณีที่การกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการได้ รวมทั้งยังมีอำนาจเพิกถอน แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือใช้อำนาจแทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ส่วนการกำกับดูแลเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในด้วยกันเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การบังคับบัญชาและการกำกับดูแลจะมีผลให้ผู้รับผิดชอบองค์กรต้องใช้อำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องและต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรด้วย[30]

ทั้งนี้ โดยหลักแล้วการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจภายในองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรจะต้องกระทำอยู่เป็นปกติเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่าในการทำงานขององค์กรนั้นได้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยอำเภอใจ อันจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน กรณีจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ (Responsibility) ในการทำงานขององค์กรที่มีต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กรแต่ละองค์กรนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามเนื้อหาของภารกิจที่ต้องกระทำ โดยอาจมีลักษณะการตรวจสอบและถ่วงดุลในลักษณะเป็นสายการบังคับบัญชา เช่น องค์กรตำรวจ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องให้ความเห็นชอบในการออกคำสั่งหรือมาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือในกรณีของศาล แม้จะไม่สามารถใช้การตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะของสายบังคับบัญชาได้ เนื่องจากผู้พิพากษาต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี แต่ยังสามารถตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กรได้ด้วยการกำหนดให้นั่งพิจารณาครบองค์คณะ เป็นต้น

(2) การตรวจสอบถ่วงดุลจากภายนอกองค์กร

การตรวจสอบถ่วงดุลจากภายนอกองค์กรเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่โดยองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดการคานอำนาจหรือการถ่วงดุลอำนาจมิให้องค์กรใดใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขต นอกจากนี้จะยังทำให้องค์กรผู้ใช้อำนาจระมัดระวังการใช้อำนาจมากยิ่งขึ้น[31] เพราะสามารถถูกตรวจสอบได้เสมอด้วยกรณีจึงกล่าวได้ว่าการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจโดยองค์กรภายนอกนั้นเป็นการดุลและคานอำนาจกันและกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ

---

[30]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* , น. 21 , 102 .

[31]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* , น. 21 , 102 .

ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมโปร่งใส (Transparency) และถูกตรวจสอบได้ (Accountability) ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐ

ทั้งนี้ การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจโดยองค์กรภายนอกนั้น เป็นการตรวจสอบองค์กรโดยองค์กร โดยเป็นการตรวจสอบที่ออกแบบมาให้ใช้ระบบในการตรวจสอบที่ไม่ให้ความสำคัญกับการเชื่อถือในตัวบุคคลซึ่งไม่มีความแน่นอน แต่เป็นการสร้างกลไกขึ้นมาให้ต่างองค์กรมีอำนาจหน้าที่ที่ดุลและคานซึ่งกันและกัน ทำให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเมื่อส่งผ่านไปในแต่ละองค์กรก็จะเกิดการตรวจสอบในทุกขั้นตอน

2.2.1.2 **ขอบเขตในการตรวจสอบถ่วงดุล**[32]

ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ การตรวจสอบถ่วงดุลในชั้นศาลเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐธรรมนูญ ประเด็นเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลในกระบวนพิจารณาคดีจึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการตรวจสอบถ่วงดุลในชั้นเจ้าพนักงาน เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ศาลหรือตุลาการต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยปราศจากการแทรกแซงทั้งจากอำนาจอธิปไตยอื่นหรือการแทรกแซงจากภายในองค์กรตุลาการเองก็ดี ดังนั้น ขอบเขตในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายตุลาการจึงต้องคำนึงถึงหลักความเป็นอิสระของตุลาการ (Independent of Judge) ด้วยเสมอ

หลักความเป็นอิสระของตุลาการ คือ หลักการรับประกันความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจอื่นใด เพื่อให้ตุลาการสามารถดำรงตนในฐานะเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ ความเป็นอิสระของตุลาการนี้ จะต้องมีความอิสระทั้งในทางเนื้อหาและในทางส่วนตัวด้วย[33] กล่าวคือ ความเป็นอิสระในทางเนื้อหา นั้นผู้พิพากษาย่อมมีความอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่า ผู้พิพากษาหรือตุลาการจะพิจารณาพิพากษาคดีไปตามกฎหมายและนำกฎหมายที่มีอยู่ปรับเข้ากับข้อเท็จจริงแห่งคดีด้วยความรอบคอบและโดยวิจารณญาณแห่งวิชาชีพของตนเพื่อรักษาและปกป้องความยุติธรรมและเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายโดยเสมอหน้ากัน ซึ่งเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือหลักความผูกพันต่อกฎหมายของ

---

[32]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* , น. 86-89.

[33]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* , น. 100 - 101.

ฝ่ายตุลาการนั่นเอง ส่วนความเป็นอิสระในทางส่วนตัวนั้น ได้แก่ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายสำนวนตามกฎหมายอย่างชัดเจน การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโยกย้าย และการกำหนดระบบบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนความเป็นอิสระในทางเนื้อหาและสร้างระบบความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษานั่นเอง

และเนื่องจากอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอำนาจเฉพาะของฝ่ายตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความคุ้มครองแก่หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ กล่าวโดยเฉพาะในการดำเนินคดีอาญา ภารกิจของศาลมีเป้าหมายเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่และจะลงโทษจำเลยได้หรือไม่ จากภารกิจดังกล่าวศาลจึงเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทำหน้าที่ยุติข้อพิพาทของประชาชน และทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐโดยองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาหรือตุลาการจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยกลไกตรวจสอบการทำงานทั้งจากภายนอกและภายในและต้องถูกตรวจสอบการใช้อำนาจโดยเสมอด้วย

2.2.1.3 ลักษณะการตรวจสอบถ่วงดุล

เนื่องจากขอบเขตในการตรวจสอบถ่วงดุลในชั้นศาลที่ต้องคุ้มครองหลักความเป็นอิสระของตุลาการดังกล่าวข้างต้น การตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนการยุติธรรมในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น โดยหลักจะเป็นการตรวจสอบภายในองค์กรตุลาการเอง เช่น การตรวจสอบระหว่างผู้พิพากษาซึ่งร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดี หรือการตรวจสอบตามชั้นศาล ส่วนการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกมักเป็นลักษณะการตรวจสอบเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ และจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้มีการตรวจสอบได้ เช่น การถอดถอนผู้พิพากษา เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถแบ่งลักษณะการตรวจสอบในชั้นศาลนี้ได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ

(1) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร

1. หลักการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษา

หลักการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานี้เป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในองค์กรศาลเอง โดยหลักการนี้เป็นหลักที่ต้องพิจารณาประกอบกับ

หลักการพิจารณาคดีต่อเนื่องด้วย กล่าวคือ ผู้พิพากษาจะต้องนั่งพิจารณาครบองค์คณะเพื่อเป็นการตรวจสอบภายในกันเองเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการรับฟังพยานหลักฐาน เพราะการที่จะสามารถตรวจสอบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ข้อมูลของผู้ที่ตรวจสอบกันจะต้องเสมอกัน กล่าวคือได้นั่งฟังคำเบิกความของพยานมาด้วยกัน โดยเหตุนี้ผู้พิพากษาซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใดก็จะทำคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยในคดีนั้นไม่ได้ เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจจะก้าวล่วงได้ และเมื่อผู้พิพากษานั้นนั่งพิจารณาคดีเป็นองค์คณะอย่างต่อเนื่องย่อมช่วยแก้ปัญหาในเรื่องจิตวิทยาพยานหลักฐานและยังทำให้คดีเสร็จจากศาลโดยรวดเร็วและเป็นธรรม อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเต็มที่และรอบคอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเป็นลักษณะสำคัญของการพิจารณาคดีในชั้นศาล เพื่อประโยชน์ในการที่สาธารณะจะได้รู้เห็นการดำเนินคดีในชั้นพิจารณาพิพากษาคดีอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และเพื่อพิสูจน์ความจริงในคดีอันเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของจำเลยไม่ว่าที่สุดแล้วศาลจะพิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม โดยการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เป็นการให้หลักประกันแก่จำเลยว่าจะได้รับการพิจารณาคดีจากศาลที่มีความยุติธรรมและถูกต้อง ไม่ว่าผลคำพิพากษาจะเป็นประการใด เป็นการแสดงต่อสาธารณชนถึงความชอบธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นการลดโอกาสในการบ่ายเบี่ยงความเป็นธรรมโดยอคติ ตลอดจนลดพฤติกรรมที่มิชอบของผู้เกี่ยวข้องในคดี รวมทั้งปัญหาการทำคำพิพากษาที่อาจเกิดขึ้นโดยอคติ นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนอีกด้วย อย่างไรก็ดี การพิจารณาโดยการลับก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการพิจารณาคดีลับนั้นมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ที่เหนือกว่าวัตถุประสงค์ของการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและต้องดำเนินการอย่างจำกัดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้เนื่องจากหลักในการพิจารณาคดีที่ต้องกระทำโดยเปิดเผยเป็นหลักที่สืบเนื่องมาจากหลักนิติรัฐอันต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การพิจารณาคดีจึงต้องกระทำโดยเปิดเผยในห้องพิจารณาคดีที่ระหว่างการพิจารณาคดีนั้นตามปกติประชาชนทุกคน

มีสิทธิที่จะเข้าไปฟังการพิจารณาคดีได้ อันจะเป็นการเปิดโอกาสประชาชนได้ควบคุมการทำงานของศาลอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง[34]

3. หลักการพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย

หลักการพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลยเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยในคดีอาญาซึ่งต้องถูกดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทราบข้อกล่าวหา เพื่อให้จำเลยสามารถในการใช้สิทธิต่อสู้คดีแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การที่พยานจะเบิกความปรักปรำจำเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าจำเลยย่อมไม่อาจทำได้สะดวก ทั้งนี้ การพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย หมายว่าจำเลยต้องมีส่วนรับรู้การดำเนินการทั้งหลายภายในศาลเพราะเป็นกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้โอกาสจำเลยในการต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าเมื่อการพิจารณาคดีจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลย ถ้าจำเลยไม่มาศาล การพิจารณาคดีจะต้องหยุดลงจนกว่าจำเลยจะมาศาล ทำให้จำเลยอาจหลบหนีไปในระหว่างการประกันตัวเพื่อให้ศาลไม่สามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ หลักนี้จึงต้องมีข้อยกเว้นให้ศาลสามารถสืบพยานลับหลังจำเลยที่ไม่มาศาลโดยเจตนาหรือสมัครใจได้ หรือสืบพยานต่อไปโดยไม่มีตัวจำเลยอยู่ร่วมด้วยขณะพิจารณานั่นเอง[35]

4. หลักการให้เหตุผลในคำพิพากษาหรือคำสั่งระหว่างพิจารณา

การที่ศาลต้องให้เหตุผลในคำพิพากษาหรือคำสั่งระหว่างพิจารณาเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจของศาล โดยศาลจะต้องให้เหตุผลในการพิพากษาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งการให้เหตุผลในคำสั่งระหว่างพิจารณาด้วย ซึ่งเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบของศาลเอง และเพื่อประโยชน์ต่อจำเลยในการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปว่าเหตุผลอันเป็นที่มาของคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายเพียงใด หากในคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ได้ระบุเหตุผลในการวินิจฉัยโดยชัดแจ้งเพียงพอ อาจทำให้จำเลยไม่ได้ใช้สิทธิโต้แย้งและส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาโดยศาลสูงในคดีนั้นได้ ดังนั้น การให้เหตุผลในคำพิพากษาและคำสั่งระหว่างพิจารณาจึงนำไปสู่การตรวจสอบภายในองค์กรโดยศาลสูงหากมีการอุทธรณ์หรือฎีกานั่นเอง

---

[34]คณิต ณ นคร , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 70.

[35]*ภัทร์รพี อุ่นใหม่ , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18* , น. 20.

5. หลักการอุทธรณ์และฎีกา

การให้สิทธิแก่คู่ความในการอุทธรณ์และฎีกาไปยังศาลสูงได้ในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติกฎหมาย เป็นกลไกที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลภายในองค์กรของศาลให้ศาลสูงจะได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลล่าง นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบระหว่างกันเองตามชั้นศาลอันเป็นการตรวจสอบภายในของศาลเองอีกด้วย[36]

(2) การตรวจสอบถ่วงดุลจากภายนอกองค์กร

1. การถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการ

ผู้พิพากษาสามารถถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ หากมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้มีอำนาจในการถอดถอน กรณีจึงเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเอง

2. การวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินคดี

การวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินคดีของศาลเป็นการตรวจสอบโดยประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบโดยสื่อมวลชนในฐานะเป็นปากเสียงแทนประชาชน เพราะสื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเมื่อได้ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วสื่อมวลชนอาจสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมโดยการวิพากษ์วิจารณ์และเผยแพร่ข้อมูลสู่การรับรู้ของสาธารณชน อย่างไรก็ดี เนื่องจากศาลมีบทบัญญัติในเรื่องละเมิดอำนาจศาล การวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินคดีของศาลโดยประชาชนหรือสื่อมวลชนจึงย่อมต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง การแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ที่กระทำโดยสุจริต ไม่ควรเป็นการละเมิดอำนาจศาล เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นการตรวจสอบศาลโดยประชาชน[37]

---

[36]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* , น. 110.

[37]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* , น. 120.

2.2.2 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา

2.2.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948)[38]

ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได้

ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการไม่ได้

ข้อ 11 (1) บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที่ซึ่งตนได้รับหลักประกันทั้งหมดที่จำเป็นในการต่อสู้คดี

2.2.2.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966)[39]

ข้อ 7 บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้ามิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลใดจะถูกทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจอย่างอิสระหาได้ไม่

ข้อ 9

(1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน บุคคลใดจะถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการมิได้ บุคคลใดจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและอาศัยกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

(3) บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญาย่อมต้องถูกนำตัวไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายโดยพลัน เพื่อที่จะมีการใช้อำนาจทางตุลาการ และได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือมีการปล่อยตัว มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องคุมขังบุคคลผู้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี แต่จะปล่อยชั่วคราวโดยอาจให้มีหลักประกันว่าจะกลับมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี หรือในกรณีจำเป็นตามโอกาสจะกลับมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาในระหว่างกระบวนพิจารณาขั้นใดก็ได้

---

[38]นพนิธิ สุริยะ, สิทธิมนุษยชน , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน ,2537) , น. 119 - 123.

[39]นพนิธิ สุริยะ, *เพิ่งอ้าง* , น. 151 - 161.

(4) บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม ย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาโดยมิชักช้าได้ถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวผู้นั้น และหากมีการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวได้

(5) บุคคลใดที่ตกเป็นผู้ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อ 10

(1) บุคคลทั้งหลายที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

(2) (ก) พึงจำแนกผู้ต้องหาว่ากระทำผิดออกจากผู้ต้องโทษ และพึงได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมแก่สถานะอันมิใช่เป็นผู้ต้องโทษ

(ข) พึงแยกตัวผู้ต้องหาว่ากระทำผิดที่เป็นเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ และให้นำตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อ 14

(1) บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคในการพิจารณาของศาล ในการพิจารณาคดีอาญาอันบุคคลต้องหาว่ากระทำผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาลที่มีอำนาจ มีอิสระ และเป็นกลาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ...

(2) บุคคลทุกคนผู้ถูกหาว่ากระทำผิดอาญา ย่อมมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ากระทำผิดตามกฎหมาย

(3) ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึ่งถูกหาว่ากระทำผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ำอย่างเสมอภาคเต็มที่ ดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิที่จะได้รับแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยพลันและละเอียดในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้

(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อสู้คดี และติดต่อกับทนายความได้ตามความประสงค์ของตน

(ค) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยปราศจากการชักช้าอย่างไม่เป็นธรรม

(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง หรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บุคคลจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย และบุคคลนั้นไม่สามารถ

รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทนได้ ในกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งขึ้นโดยไม่คิดมูลค่า

(จ) สิทธิที่จะถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน

(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้

(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ให้การเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด

2.2.2.3 **กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษ ค.ศ**. 1955 (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1955)[40]

ผู้ถูกคุมขังที่อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือรอการพิจารณาคดี

ข้อ 84

(1) ผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังด้วยเหตุที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนั้น ไม่ว่าจะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจหรือถูกขังอยู่ในเรือนจำ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในกฎฉบับนี้ จะเรียกว่า “ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี”

(2) ผู้ถูกคุมขังที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนั้นพึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์และพึงได้รับการปฏิบัติแยกต่างหากจากผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าได้กระทำความผิด

2.2.2.4 **หลักการเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุก ค.ศ**. 1988 (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988)[41]

ข้อ 1 บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุกพึงได้รับการปฏิบัติในฐานะมนุษย์และอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้น

---

[40]กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ, มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม ,2548), น.15.

[41]กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ, *เพิ่งอ้าง* , น. 121 - 127.

ข้อ 2 การจับกุม คุมขัง หรือจำคุก จะกระทำได้อย่างจำกัดเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายและโดยบุคคลผู้ที่กฎหมายระบุอำนาจหน้าที่นั้นไว้สำหรับการดังกล่าว

ข้อ 4 การคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใด หรือการจำคุก ตลอดจนมาตรการอื่นที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกคุมขังหรือจำคุกนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นคำสั่งหรือการควบคุมขององค์กรศาลหรือองค์กรอื่น

ข้อ 8 ผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดีพึงได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะของการที่ผู้นั้นยังไม่ได้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ดังนั้นหากเป็นไปได้ การคุมขังผู้นั้นให้พึงแยกต่างหากจากนักโทษเด็ดขาด

ข้อ 9 ผู้มีอำนาจหน้าที่จับกุม คุมขัง หรือสอบสวนคดีอาญา จะใช้อำนาจหน้าที่นั้นได้เพียงภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและการใช้อำนาจหน้าที่นั้นพึงถูกตรวจสอบได้โดยองค์กรศาลหรือองค์กรอื่น

ข้อ 11

(1) บุคคลจะถูกคุมขังโดยปราศจากการไต่สวนขององค์กรศาลหรือองค์กรอื่นนั้นไม่ได้ ผู้ที่ถูกคุมขังพึงมีสิทธิให้การแก้ข้อกล่าวหาหรือได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ผู้ที่ถูกคุมขังและที่ปรึกษากฎหมายของผู้นั้นพึงมีสิทธิได้ทราบถึงรายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งที่ให้คุมขังผู้นั้น

(3) องค์กรศาลหรือองค์กรอื่นพึงมีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนหรือตรวจสอบความชอบด้วยเหตุผลในการจะคุมขังผู้นั้นต่อไป

ข้อ 36

(1) ผู้ที่ถูกคุมขังในฐานะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญานั้น พึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และพึงได้รับการปฏิบัติเหมือนอย่างข้อสันนิษฐานด้วย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดจริง ทั้งนี้จะต้องมีหลักประกันตามกฎหมายที่จะคุ้มครองให้ผู้นั้นสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้แก้ข้อกล่าวหานั้นด้วย

(2) การจับกุมหรือคุมขังบุคคลดังกล่าวในระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดีนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น การออกคำสั่งจำกัดอิสรภาพของบุคคลโดยที่มิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการคุมขังดังกล่าว หรือมิได้เป็นไปเพื่อการป้องกันขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่คุมขังนั้นแล้ว จะกระทำมิได้

ข้อ 37 ผู้ที่ถูกคุมขังในระหว่างการดำเนินคดีอาญานั้น จะต้องถูกนำตัวไปยังองค์กรศาลหรือองค์กรอื่นตามที่กฎหมายกำหนดในทันทีที่จะกระทำได้นับแต่เวลาที่ผู้นั้นถูกจับกุม ทั้งนี้เพื่อจะได้มีการตรวจสอบและวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้นั้นเป็นการชอบหรือจำเป็นหรือไม่ การคุมขังบุคคลใดในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาคดีนั้น จะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีหมายคุมขังที่ออกโดยชอบขององค์กรที่ออกคำสั่งคุมขังนั้น ผู้ที่ถูกคุมขังดังกล่าวมีสิทธิที่จะทำหนังสือระบุถึงสิ่งที่เขาได้รับการปฏิบัติในระหว่างที่ถูกคุมขังให้องค์กรที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคุมขังดังกล่าวนั้นได้ทราบข้อเท็จจริงด้วย

ข้อ 38 บุคคลที่ถูกคุมขังในระหว่างการดำเนินคดีอาญาพึงได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นด้วย

ข้อ 39 เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ บุคคลที่ถูกคุมขังในระหว่างการดำเนินคดีอาญามีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เว้นแต่องค์กรศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นจะเห็นเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย อย่างไรก็ดีการให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการดำเนินคดีนั้นอาจมีการทบทวนคำสั่งใหม่ได้ตามกรณีแห่งความจำเป็น

2.3 ข้อความคิดเกี่ยวกับการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา

2.3.1 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ

หลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการถือว่าเป็นหลักการที่เป็นหัวใจของหลักนิติรัฐ เพราะเป็นการที่รัฐแสดงว่ารัฐยอมที่จะให้ความเป็นอิสระแก่อำนาจศาลในการเข้ามาควบคุมตรวจสอบการกระทำต่าง ๆ ของรัฐว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือไม่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 บัญญัติรับรองหลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพต่อองค์กรรัฐ โดยองค์กรตุลาการย่อมผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพในการใช้และตีความกฎหมาย กล่าวคือ ในการพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ นั้น ศาลมีหน้าที่ในการตรวจสอบ 2 ประการ ประการแรก ศาลจะต้องตรวจสอบว่ากรณีที่เป็นปัญหามาสู่การพิจารณาคดีของศาลนั้นมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ และประการที่สอง

ศาลเองก็จะต้องไม่ใช้หรือตีความกฎหมายให้เป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเองก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทางวิธีพิจารณาของคู่ความในคดีด้วย

หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพต่อองค์กรรัฐนี้ จะต้องควบคู่ไปกับหลักการควบคุมตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” หลักการนี้เป็นหลักการที่ทำให้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มีผลในทางปฏิบัติ เพราะหลักการที่บัญญัติให้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองมีผลผูกพันองค์กรของรัฐโดยตรงนั้นจะไร้ความหมายหากไม่ให้โดยให้ศาลเข้าควบคุมตรวจสอบการกระทำต่าง ๆ ของรัฐว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีค่าบังคับในทางปฏิบัติ โดยในส่วนกรณีการใช้หรือตีความกฎหมายขององค์กรตุลาการนั้น หากเป็นการใช้หรือตีความกฎหมายโดยศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ ศาลที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปก็ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ[42]

2.3.2 **หลักความได้สัดส่วน**

2.3.2.1 **ข้อความคิดของหลักความได้สัดส่วน**

หลักความได้สัดส่วนหรือหลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จำเป็นหรือหลักพอสมควรแก่เหตุหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลักห้ามมิให้กระทำเกินกว่าเหตุ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นหลักกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาใช้ควบคุมการใช้อำนาจของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามหลักกฎหมายของเยอรมันนั้น ถือว่าเป็นหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปอย่างกว้างขวาง มิใช่แต่เฉพาะในเยอรมัน ยังรวมถึงออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักกฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปด้วย

จะเห็นได้ว่า หลักความได้สัดส่วนเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักในทางกฎหมายที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะรากฐานของหลักความได้สัดส่วนนั้นมีพื้นฐานมาจากหลักความ

---

[42]บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน ,2552) , น. 232 - 233.

ยุติธรรมอันเป็นพื้นฐานของกฎหมายทั่วไป หลักความได้สัดส่วนนั้นเป็นหลักที่คำนึงถึงความยุติธรรมทั้งในส่วนของปัจเจกชนและความยุติธรรมต่อสังคมโดยรวมด้วย ทั้งนี้เพราะการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลก็ดี ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันก็ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาชนก็ดี ย่อมมีผลกระทบต่อกันและกันโดยเสมอ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันเป็นไปบนหลักการของกฎหมายที่คำนึงถึงความยุติธรรมของทุกฝ่าย โดยหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักสำคัญในการตรวจสอบการกระทำของรัฐทั้งหลาย อันมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำนั้น ๆ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันได้เคยวินิจฉัยว่าหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักที่มีผลมาจากหลักนิติรัฐ ดังนั้น หลักความได้สัดส่วนจึงมีลำดับชั้นในระดับของรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักการที่มีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อจำกัดการใช้อำนาจของรัฐและเป็นหลักที่ก่อให้เกิดความมั่นคงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภาระหน้าที่ของหลักความได้สัดส่วนมิได้มุ่งหมายเฉพาะการจำกัดการแทรกแซงของอำนาจรัฐเท่านั้น แต่หากตีความตามหลักความได้สัดส่วนอย่างถูกต้องแล้ว หลักความได้สัดส่วนนอกเหนือจะเป็นหลักการในทางเนื้อหาที่ห้ามมิให้มีการใช้อำนาจอย่างอำเภอใจแล้ว ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งนำมาใช้ในขอบเขตของเรื่องสิทธิและเสรีภาพ กล่าวคือเป็นหลักที่มีความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย[43]

2.3.2.2 **สาระสำคัญของหลักความได้สัดส่วน**

หลักความได้สัดส่วนมีหลักที่เป็นสาระสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ หลักความเหมาะสม หลักความจำเป็น และหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ[44]

(1) หลักความเหมาะสม

หมายถึง มาตรการนั้นเป็นมาตรการที่อาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้ มาตรการอันใดอันหนึ่งจะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม หากมาตรการนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เช่น กฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

---

[43]บรรเจิด สิงคะเนติ, *เพิ่งอ้าง* , น. 268 - 273.

[44]บรรเจิด สิงคะเนติ, *เพิ่งอ้าง* , น. 27 – 28.

มาตรการหรือกลไกทางกฎหมายก็ต้องสามารถป้องกันมิให้เกิดการจลาจล หรือความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมนั้นได้ และถ้ามาตรการหรือกลไกทางกฎหมายนั้นไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ถือว่ากฎหมายฉบับนั้นไม่บรรลุผลหรือไม่เป็นไปตามหลักความสัมฤทธิผลและขัดต่อรัฐธรรมนูญ[45]

(2) หลักความจำเป็น

หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดได้และเป็นมาตรการหรือวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น หากมีมาตรการอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้และมีผลกระทบน้อยกว่ามาตรการที่รัฐได้เลือกใช้ ในกรณีนี้ย่อมถือได้ว่ามาตรการที่รัฐนำมาใช้มิได้เป็นไปตามหลักความจำเป็น ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยแล้ว รัฐจะเรียกร้องให้ราษฎรจำต้องสละสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นแก่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและ/หรือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นแก่การดำเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ย่อมเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ[46]

(3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ

หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการ และหมายความว่า มาตรการอันใดอันหนึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือมาตรการอันใดอันหนึ่งจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างวิธีการกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาความสมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกกระทบกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่สมดุลกัน แต่หากกระทบสิทธิของปัจเจกบุคคลมากแต่ประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการกระทบสิทธิดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กรณีย่อมถือว่าไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ[47]

---

[45]คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, <u>รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษอาญา</u> , (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2547) ,น. 338.

[46]คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, *เพิ่งอ้าง* ,น. 338.

[47]บรรเจิด สิงคะเนติ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 44* , น. 279 - 280.

2.3.2.3 หลักความได้สัดส่วนกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

ในขอบเขตของการบัญญัติกฎหมายที่จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน การใช้หลักความได้สัดส่วนในขั้นแรกเป็นเรื่องความจำเป็นเพื่อการเปรียบเทียบ โดยในขั้นต้นจะต้องประเมินค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์มหาชนประการหนึ่งกับการสูญเสียเสรีภาพของปัจเจกชนอีกประการหนึ่ง ดังนั้น กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานจำเป็นที่จะต้องให้เหตุผลที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่า ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลมีความสำคัญมากกว่าในกรณีนั้น ๆ [48]

[48]บรรเจิด สิงคะเนติ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 44* , น. 280 - 282.

บทที่ 3

การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในต่างประเทศ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการขังระหว่างพิจารณาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับการขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทยและนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

3.1 ประเทศญี่ปุ่น

3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา

3.1.1.1 ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญา

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีหรือก่อนการดำเนินกระบวนพิจารณาเป็นขั้นตอนสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้อง ญี่ปุ่นใช้ระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ เฉพาะอัยการเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา ผู้เสียหายฟ้องคดีเองไม่ได้ โดยเจ้าพนักงานหลักในการสอบสวนและฟ้องร้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ[1] และหลักพื้นฐานของการสอบสวนและพิจารณาคดี คือ การพิสูจน์ความจริงให้แจ้งชัด ปรับบทกฎหมายด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว รักษาประโยชน์สาธารณะ และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานส่วนบุคคล[2]

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 189 ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ เมื่อทำการสอบสวนคดีอาญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งสำนวนพร้อมกับเอกสารและพยานหลักฐานทั้งปวงไปยังพนักงานอัยการ[3] สำหรับพนักงานอัยการนั้น มีอำนาจสมบูรณ์ปรากฏตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ ประการแรกสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดคดีอาญา โดยสอบปากคำผู้ต้องหา สอบปากคำพยาน และพิจารณาพยานที่รวบรวมมาโดยพนักงานตำรวจ ประการที่สอง พิจารณาวินิจฉัยสั่งคดีว่าสมควรฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่ ประการที่สาม ฟ้องคดี และประการสุดท้าย ควบคุมตรวจสอบการบังคับตาม

---

[1]สถาบันกฎหมายอาญา, สารานุกรมกระบวนการยุติธรรมนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร : เซเว่น , 2540) , น.39.

[2]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 1948 มาตรา 1

[3]สถาบันกฎหมายอาญา, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1* , น.44.

คำพิพากษาของศาล[4] สำหรับการสอบสวนนั้น ให้ดุลพินิจในการสอบสวน มิได้บังคับให้ต้องทำการสอบสวน แต่เมื่อเห็นว่าจำเป็นพนักงานอัยการสามารถทำการสอบสวนได้ด้วยตนเอง พนักงานอัยการจึงมีอิสระสอบสวนคดีได้ทุกประเภทไม่จำกัด[5]

3.1.1.2 ขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญา

เมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จำเลยมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ โดยพนักงานอัยการมีภาระการพิสูจน์จนกว่าจะพิสูจน์ความผิดของจำเลยให้ศาลเห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยปราศจากความสงสัยอันควร มิฉะนั้นศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย และการดำเนินกระบวนพิจารณาต้องเป็นไปโดยเปิดเผย รวดเร็ว โดยคู่ความมีหน้าที่นำส่งพยานหลักฐานของตนให้แก่ฝ่ายตรงข้ามโดยเร็ว ตรวจสอบพยานหลักฐานและแจ้งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบว่าตนยอมรับพยานหลักฐานที่เตรียมไว้สำหรับการพิจารณาคดีในศาลหรือไม่ คู่ความต้องใช้ความพยายามในการนำพยานของตนมาให้การในศาล และคู่ความจะต้องติดต่อทำความเข้าใจกันในประเด็นที่เกี่ยวกับคดีและรายงานให้ศาลทราบเพื่อกำหนดวันและเวลาพิจารณาคดี นอกจากนั้นในส่วนของศาล ศาลจะต้องใช้ความพยายามในการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชักช้า โดยเฉพาะในคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน กล่าวคือ เมื่อศาลเห็นสมควรให้เรียกคู่ความมาประชุมพร้อมกันก่อนเริ่มการพิจารณาคดีเพื่อกำหนดวันพิจารณาคดี โดยศาลจะต้องพยายามกำหนดวันพิจารณาคดีล่วงหน้าตามที่ได้ประชุมกับคู่ความและเว้นระยะวันพิจารณาคดีให้สั้นที่สุดเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว[6]

3.1.2 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา

ในอดีตหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนญี่ปุ่นได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1890 ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การปกครองประเทศโดยอาศัยหลักนิติธรรม และมีหลักการแบ่งแยกอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร

---

[4]สถาบันกฎหมายอาญา, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1* ,น. 40.

[5]รัตนา ธมรัตน์, "อำนาจรัฐในการควบคุมผู้ต้องหา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น" , (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544) ,น. 123 - 128.

[6]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , <u>รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สิทธิผู้ต้องหา จำเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา</u> , 2540 , น. 130.

และฝ่ายตุลาการ รวมทั้งมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองด้วย ต่อมาญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1947 ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมขึ้น

ในส่วนของหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณานั้น รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1947 ได้วางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการขังระหว่างพิจารณาไว้หลายประการ ดังนี้[7]

(1) บุคคลจะไม่สูญเสียชีวิตหรือเสรีภาพหรือถูกลงโทษทางอาญาใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (มาตรา 31)

(2) บุคคลมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลยุติธรรม (มาตรา 32)

(3) บุคคลจะไม่ถูกจับโดยปราศจากหมายจับซึ่งออกโดยผู้พิพากษาที่มีอำนาจเท่านั้น และหมายจับต้องระบุความผิดซึ่งบุคคลนั้นถูกกล่าวหา เว้นแต่บุคคลนั้นจะถูกจับในขณะกระทำความผิด (มาตรา 33)

(4) บุคคลจะไม่ถูกจับหรือถูกคุมขังโดยปราศจากการแจ้งข้อหาให้ทราบ หรือโดยปราศจากสิทธิในการพบทนายความในทันที หรือถูกคุมขังโดยไม่มีเหตุอันควร และเหตุแห่งการถูกคุมขัง จะต้องเสนอต่อศาลในทันทีโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ถูกคุมขังและทนายความของเขา (มาตรา 34)

(5) จำเลยมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เปิดเผย และเป็นธรรม (มาตรา 37 วรรคหนึ่ง)

(6) สิทธิได้รับการชดเชยจากรัฐกรณีได้รับความเสียหายจากการดำเนินคดีอาญา บุคคลใดเมื่อได้รับการตัดสินให้พ้นโทษภายหลังถูกจับหรือขัง อาจเรียกค่าชดเชยจากรัฐได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 40)

(7) การพิจารณาและการพิพากษาอรรถคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผย หากศาลเห็นว่าการเปิดเผยต่อสาธารณะจะเป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การพิจารณาคดีนั้นอาจกระทำโดยไม่เปิดเผยก็ได้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความผิดทางการเมือง ความผิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หรือสิทธิของประชาชนตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเสมอ (มาตรา 82)

---

[7]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *เพิ่งอ้าง* , น. 118 - 119.

3.1.3 การขังระหว่างพิจารณา

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญานั้น มีหลักทั่วไปกรณีการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ การพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดจะต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้โดยปราศจากข้อสงสัยแล้วเท่านั้น การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจลงโทษจำเลยได้ และการสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จะใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีอาญา เริ่มตั้งแต่การสอบสวนถึงขั้นพิจารณาคดีและจะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นเดียวกับพลเมืองทั่ว ๆ ไป[8]

สำหรับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้ต้องหาและจำเลยเกี่ยวกับเสรีภาพในชีวิตร่างกายและเสรีภาพในการเปลี่ยนที่ทางนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่นคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย โดยการคุมขังเป็นข้อยกเว้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่ต้องถูกควบคุมหรือขังนานเกินควรด้วยการกำหนดระยะเวลาควบคุมและขังไว้เป็นการแน่นอน และมีการปล่อยชั่วคราว โดยผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน[9] ทั้งในชั้นสอบสวนฟ้องร้องของตำรวจและพนักงานอัยการ และในชั้นพิจารณาของศาล

3.1.3.1 เหตุของการขังระหว่างพิจารณา

การขังระหว่างพิจารณาเป็นอำนาจของศาลเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้จำเลยหลบหนีหรือทำลายพยานหลักฐาน และสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้จำเลยหลบหนีนั้น ไม่ได้มีความจำเป็นเฉพาะในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเท่านั้น หากแต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลด้วย[10]

การขังระหว่างพิจารณาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีหมายขังระหว่างพิจารณา ทั้งนี้พนักงานอัยการจะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลออกหมายขังระหว่างพิจารณา (มาตรา 62 มาตรา 64 และมาตรา 70)

---

[8]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6*, น. 128.

[9]อรวรรณ ไทยวานิช , “การปล่อยชั่วคราว” , (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539) ,น. 45.

[10]Shigemitsu Dando, Japanese criminal procedure, (South Hackensack,N.J. : Fred B. Rothman & Co. , 1965) , p. 257.

สำหรับเหตุของการขังระหว่างพิจารณานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60 วรรคหนึ่ง[11] บัญญัติว่า ศาลอาจขังจำเลยระหว่างพิจารณาได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1. จำเลยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน
2. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะซ่อนเร้นหรือทำลายพยานหลักฐาน
3. จำเลยหลบหนีหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะหลบหนี

นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60 วรรคสาม[12] บัญญัติว่า นอกจากกรณีตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง ศาลสามารถสั่งขังระหว่างพิจารณาได้ในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 เยน หรือโทษกักขัง หรือโทษปรับเล็กน้อย เมื่อจำเลยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนได้ด้วย

นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเงื่อนไขในเชิงรูปแบบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาด้วย กล่าวคือ

---

[11]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 60

(1) The court may detain the accused when there is probable cause to suspect that he/she has committed a crime and when:

(i) The accused has no fixed residence;

(ii) There is probable cause to suspect that he/she may conceal or destroy evidence;

(iii) The accused has fled or there is probable cause to suspect that he/she may flee.

[12]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 60

(3) With regard to cases which shall be punished with a fine of not more than 300,000 yen (with regard to crimes other than those under the Penal Code, the Act on Punishment of Physical Violence and Others (Act No. 60 of 1925), and the Act on Penal Provisions related to Economic Activities (Act No. 4 of 1944), 20,000 yen for the time being), a misdemeanor detention or petty fine, the provision of paragraph (1) of this Article shall apply only when the accused has no fixed residence.

1. จำเลยไม่อาจถูกคุมขังได้ถ้าจำเลยไม่ได้รับแจ้งข้อหาหรือเหตุแห่งการฟ้องร้อง ยกเว้นกรณีจำเลยหลบหนี (มาตรา 61)

2. ก่อนที่จำเลยจะถูกขัง จำเลยต้องได้รับสิทธิในการมีทนายความ เว้นแต่กรณีเป็นการขังต่อเนื่องมาจากการจับหรือการควบคุม กล่าวคือ เมื่อจะถูกขังระหว่างพิจารณา จำเลยจะต้องได้รับการแจ้งทันทีว่าจำเลยสิทธิในการมีทนายความ และหากจำเลยไม่สามารถแต่งตั้งทนายความได้ด้วยตนเองเพราะเหตุแห่งความยากจนหรือเหตุอื่น จำเลยมีสิทธิที่จะขอให้ศาลแต่งตั้งทนายความให้ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่จำเลยมีทนายความแล้ว (มาตรา 77 (1) (3))

อย่างไรก็ดีเงื่อนไขทั้งสองข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่จำเลยหลบหนี ซึ่งในทันทีที่จำเลยถูกจับ จำเลยจะได้รับการแจ้งสรุปสาระสำคัญแห่งการฟ้องคดีและถ้าจำเลยไม่มีทนายความก็ต้องแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีทนายดังกล่าวด้วย (มาตรา 61 และประกอบมาตรา 77 (2) (3))

3.1.3.2 การยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาเหตุในการขังโดยเปิดเผยในศาล

จำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา ทนายความของจำเลย ผู้แทนโดยชอบธรรม สามี ภรรยา ทายาท พี่น้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการพิจารณาเหตุผลของการขังระหว่างพิจารณาโดยเปิดเผยในศาล ทั้งนี้ การยื่นคำร้องดังกล่าวต้องยื่นในขณะที่มีการขังระหว่างพิจารณา หากจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว หรือมีการเลื่อนการขังระหว่างพิจารณาออกไป หรือคำสั่งขังระหว่างพิจารณาถูกยกเลิก หรือหมายขังระหว่างพิจารณาไม่มีผลทางกฎหมายแล้ว คำร้องย่อมไม่มีผล (มาตรา 82 และมาตรา 83) และถ้าผลการพิจารณาปรากฏชัดแจ้งว่าการขังระหว่างพิจารณาเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีมูล หรือไม่มีความจำเป็น ต้องสั่งยกเลิกการขังระหว่างการพิจารณานั้น (มาตรา 87)

3.1.3.3 ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา

สำหรับระยะเวลาของการขังระหว่างพิจารณานั้น มาตรา 60 วรรคสอง[13] บัญญัติว่า ศาลสามารถขังจำเลยระหว่างพิจารณาได้เป็นเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่พนักงานอัยการฟ้องคดี ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องขังระหว่างพิจารณานานกว่านั้น สามารถขอขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาได้ต่อไปอีก 1 เดือน โดยต้องมีเหตุผลโดยชัดแจ้งในการขอขยายระยะเวลานี้ อย่างไรก็ดี สามารถขยายระยะเวลาได้ออกไปเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ดังนั้น ระยะเวลาสูงสุดในการขังระหว่างพิจารณาจึงเป็น 3 เดือน นับแต่วันที่พนักงานอัยการฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้เป็นการยากที่จะพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว หากแต่การกำหนดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณานี้เป็นไปเพื่อให้การพิจารณาคดีเสร็จในเวลาอันรวดเร็วในกรณีที่มีการขังจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองจำเลยตามสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็วตามหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 37

สำหรับข้อยกเว้นของการขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา กล่าวคือ กรณีที่สามารถขยายระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณาได้มากกว่า 1 ครั้ง นั้น ได้แก่

1. กรณีได้รับการตัดสินโทษที่ให้จำเลยถูกคุมขังหรือการลงโทษที่หนักกว่าซึ่งจำเลยไม่ได้รับการคุ้มครองตามหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป[14] (มาตรา 344)

2. กรณีเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 60 วรรค 2 คือ กรณีตามมาตรา 89 (1) เมื่อจำเลยถูกฟ้องในความผิดที่มีโทษขั้นสูงให้ประหารชีวิต หรือจำคุกขั้นต่ำเกินกว่าหนึ่งปี (3) เมื่อจำเลยเป็นผู้กระทำผิดติดนิสัย เคยถูกลงโทษจำคุกเกินกว่าสิบปี (4) เมื่อมีเหตุผลเพียงพออันสมควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะทำลายพยานหลักฐาน หรือ (6) เมื่อไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ของจำเลย

---

[13]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 60

(2) The period of detention shall be two months from the date of institution of prosecution. In cases where it is especially necessary to continue the detention, the period may, by a ruling with a specific reason, be extended for additional one-month periods; provided, however, that the extension shall only be allowed once, except as otherwise prescribed in item (i), (iii), (iv) or (vi) of Article 89.

[14]Shigemitsu Dando, *supra note 10*, p. 262.

อย่างไรก็ดี การขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณานี้ต้องไม่ทำให้เป็นการขังระหว่างพิจารณายาวนานจนเกินสมควร[15] โดยกรณีการขังระหว่างพิจารณายาวนานเกินสมควร ศาลโดยคำร้องของบุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องตามมาตรา 88 หรือโดยดุลพินิจของศาลเอง อาจยกเลิกการขังระหว่างพิจารณาหรือให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขได้ (มาตรา 91)[16]

จะเห็นได้ว่า การขังระหว่างพิจารณาคดีของญี่ปุ่นมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดจำกัด กล่าวคือ สามารถขังจำเลยระหว่างพิจารณาได้เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันฟ้อง และขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน ดังนั้น ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถขังจำเลยระหว่างพิจารณาได้ คือ 3 เดือน ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติเช่นนี้เพราะต้องการให้การพิจารณาคดีทำไปได้โดยรวดเร็วเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของจำเลย[17] อย่างไรก็ดี ยกเว้นกรณีตามมาตรา 89 (1) (3) (4) หรือ (6) ที่สามารถขยายระยะเวลาได้มากกว่า 1 ครั้ง

3.1.3.4 เหตุสิ้นสุดการขังระหว่างพิจารณา

(1) กรณีครบระยะเวลาขังหรือศาลมีคำพิพากษา

หมายขังระหว่างพิจารณาจะสิ้นสภาพเมื่อครบระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยไม่มีความผิด ยกฟ้อง หรือลงโทษปรับ ไม่ว่าคำพิพากษานั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 345) และเมื่อถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตหรือจำคุก

(2) การยกเลิกการขังระหว่างพิจารณา

1. เมื่อความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาหมดไป ศาลสามารถสั่งยกเลิกการขังระหว่างพิจารณาได้เมื่อได้รับคำร้องขอของพนักงานอัยการ จำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา

---

[15]Shigemitsu Dando, *supra note 10* , p. 262.

[16]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 91 When the confinement of detention has been unduly long, the court shall, upon the request of the person prescribed in Article 88 or ex officio, rescind the detention or grant bail by a ruling.

The provision of paragraph (3) of Article 82 shall apply mutatis mutandis to the request prescribed in the preceding paragraph.

[17]อรวรรณ ไทยวานิช , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9* ,น. 41.

ทนายความของจำเลย ผู้แทนโดยชอบธรรม สามี ภรรยา ทายาท พี่น้อง หรือเป็นดุลพินิจของศาลเอง (มาตรา 87)[18]

2. แม้ว่ากรณียังมีความจำเป็นที่จะต้องขังระหว่างพิจารณา แต่การขังระหว่างพิจารณานั้นต้องไม่เป็นการขังเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร ดังนั้น เมื่อมีกรณีการขังเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร ศาลโดยคำร้องของบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 88 หรือโดยดุลพินิจของศาลเอง ต้องยกเลิกการขังระหว่างพิจารณานั้นหรืออนุญาตให้มีการประกันตัว (มาตรา 91)[19]

หลักการเรื่องการขังเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร (Unduly Prolonged) นี้เป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละราย ไม่ใช่เป็นการพิจารณาตามจำนวนระยะเวลา โดยอาจพิจารณาได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจริงตามหลักสามัญสำนึก ลักษณะของจำเลย ความเป็นไปได้ของการที่จำเลยจะหลบหนีหรือทำลายพยานหลักฐาน ความร้ายแรงของฐานความผิด ความยากง่ายในการได้ตัวจำเลย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน โดยต้องพิจารณาทั้งปัจจัย

---

[18]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 87

(1) When the grounds or necessity of detention no longer exist, the court shall, upon the request of a public prosecutor, the accused under detention, his/her counsel, legal representative, curator, spouse, lineal relative or sibling or ex officio, rescind the detention by a ruling.

(2) The provision of paragraph (3) of Article 82 shall apply mutatis mutandis to the request prescribed in the preceding paragraph.

[19]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 91

(1) When the confinement of detention has been unduly long, the court shall, uponthe request of the person prescribed in Article 88 or ex officio, rescind the detention or grant bail by a ruling.

(2) The provision of paragraph (3) of Article 82 shall apply mutatis mutandis to the request prescribed in the preceding paragraph.

ที่เป็นอัตวิสัยและภาวะวิสัยควบคู่กันไป โดยสำหรับกรณีมาตรา 91 นั้น ต้องพิจารณาองค์ประกอบในเชิงภาวะวิสัยเป็นสำคัญ[20]

อย่างไรก็ดี การยกเลิกการขังระหว่างพิจารณาต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการด้วย เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรือเป็นการร้องขอของพนักงานอัยการเอง (มาตรา 92 (2))

(3) การปล่อยชั่วคราว

การได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวเป็นสิทธิของจำเลยและศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต กล่าวคือ เมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จำเลย ญาติพี่น้อง หรือทนายความของจำเลย มีสิทธิขอประกันตัวจำเลยได้ (มาตรา 88)[21] โดยเมื่อมีคำขอให้ปล่อยชั่วคราว ศาลจะต้องพิจารณาอนุญาตเป็นหลัก เว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้น (มาตรา 89)[22] ดังต่อไปนี้

---

[20]Shigemitsu Dando , *supra note 10 ,* p. 196 -197.

[21]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 88

(1) The accused under detention or his/her counsel, legal representative, curator, spouse, lineal relative or sibling may request bail.

(2) The provision of paragraph (3) of Article 82 shall apply mutatis mutandis to the request prescribed in the preceding paragraph.

[22]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 89

The request for bail shall be granted, except when:

(i) The accused has allegedly committed a crime which is punishable by the death penalty, life imprisonment with or without work or a sentence of imprisonment with or without work whose minimum term of imprisonment is one year or more;

(ii) The accused was previously found guilty of a crime punishable by the death penalty, life imprisonment with or without work or a sentence of imprisonment with or without work whose maximum term of imprisonment was in excess of ten years;

(iii) The accused allegedly habitually committed a crime punishable by imprisonment with or without work whose maximum term of imprisonment was in excess of three years;

1. เมื่อจำเลยถูกฟ้องในความผิดที่มีโทษขั้นสูงให้ประหารชีวิต หรือจำคุกขั้นต่ำเกินกว่าหนึ่งปี

2. เมื่อจำเลยเคยรับโทษถึงที่สุดในความผิดให้ประหารชีวิต หรือได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษจำคุกเกินกว่าสิบปี

3. เมื่อจำเลยเป็นผู้กระทำผิดติดนิสัย เคยถูกลงโทษจำคุกเกินกว่าสามปี

4. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะทำลายพยานหลักฐาน

5. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะทำร้ายร่างกาย หรือทำอันตรายทรัพย์สินของผู้เสียหาย หรือบุคคลอื่นซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นผู้รู้เห็นในการพิจารณาคดีนั้น หรือญาติของเขา หรือจำเลยอาจกระทำการข่มขู่บุคคลนั้น

6. เมื่อไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ของจำเลย

อย่างไรก็ดี แม้เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 89 แล้ว ศาลอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแก่จำเลยได้โดยใช้ดุลพินิจของศาลเมื่อมีเหตุที่เหมาะสม (มาตรา 90)[23] ทั้งนี้ การพิจารณาให้ประกันหรือยกคำร้องของศาลต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการด้วย (มาตรา 92 (1))

นอกจากนี้ สามารถอุทธรณ์คำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลอุทธรณ์ได้ [24]

(4) การพักการขังระหว่างพิจารณา

ศาลอาจถ้าเห็นว่าเหมาะสมอาจให้พักการขังระหว่างพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้จำเลยอยู่ภายใต้การควบคุมของญาติหรือองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลหรือปรับปรุงความประพฤติ หรือ

(iv) There is probable cause to suspect that the accused may conceal or destroy evidence;

(v) There is probable cause to suspect that the accused may harm or threaten the body or property of the victim or any other person who is deemed to have essential knowledge for the trial of the case or the relatives of such persons;

(vi) The name or residence of the accused is unknown.

[23]The Code of Criminal Procedure of Japan (Act No. 131 of 1948)

Article 90 The court may, when it finds it appropriate, grant bail ex officio.

[24]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 127.

อาจจำกัดที่อยู่ของจำเลยเป็นการเฉพาะ (มาตรา 95 มาตรา 88 มาตรา 90 และมาตรา 98) และเหตุถอนการพักการขังเป็นระหว่างพิจารณาเป็นเหตุเช่นเดียวกับเหตุการถอนประกัน (มาตรา 96)

3.2 ประเทศฝรั่งเศส

3.2.1 ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา

สำหรับการดำเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสนั้น ใช้ระบบกล่าวหาและแยกกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญา และขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญา โดยมีองค์กรที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในขั้นตอนก่อนฟ้องคดีอาญานั้น เป็นขั้นตอนการหาข้อเท็จจริงก่อนฟ้องร้องเป็นหน้าที่ขององค์กรตำรวจสอบสวนและพนักงานอัยการ ส่วนขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญาจะเป็นหน้าที่ขององค์กรศาล อย่างไรก็ตาม ในระบบการดำเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสยังมีระบบผู้พิพากษาสอบสวน ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบสวนคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนด้วย ซึ่งมีหลักสำคัญว่าผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่สอบสวนในคดีใดแล้ว ก็จะทำการนั่งพิจารณาในคดีเดียวกันนั้นอีกไม่ได้ และเมื่อผู้พิพากษาสอบสวนสรุปสำนวนการสอบสวนแล้ว ก็ต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการทำการฟ้องและดำเนินคดีต่อไปตามระบบกล่าวหา[25]

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส แบ่งความผิดต่าง ๆ ออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ความผิดลหุโทษ (contravention) ได้แก่ ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงมีอัตราโทษปรับหรือจำกัดสิทธิบางอย่างของจำเลย และไม่มีโทษจำคุก

2. ความผิดมัธยโทษ (delit) ได้แก่ ความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 เดือน จนถึงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

3. ความผิดอุกฤษโทษ (crime) ความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต

ศาลที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดีในฝรั่งเศสนั้น จะมีอยู่ 3 ระดับ คือ ศาลสูง (Cour de cassation) ศาลอุทธรณ์ (Cour d'appel) และศาลชั้นต้น (Tribunal de premier degre) ส่วนศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาระดับศาลชั้นต้นนั้น จะแยกออกไปตามประเภทความผิด กล่าวคือ หากเป็นความผิดลหุโทษ จะพิจารณาพิพากษาคดีในศาล Tribunal

---

[25]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 63.

de police หากเป็นความผิดมัธยโทษ จะพิจารณาพิพากษาคดีในศาล Tribunal correctional และหากเป็นความผิดอุกฤษโทษ จะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลลูกขุน (Cour d'assises)

3.2.1.1 ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญา

ในขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีอาญาหรือชั้นสอบสวนฟ้องร้อง นั้น มีองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3 องค์กร ได้แก่ ตำรวจสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาสอบสวน โดยการสอบสวนคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสอบสวนเบื้องต้น การสอบสวนความผิดซึ่งหน้า และการสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน[26]

(1) การสอบสวนเบื้องต้น

การสอบสวนเบื้องต้นเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจสอบสวน ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อที่จะทราบว่าได้มีความผิดเกิดขึ้นหรือไม่ และถ้ามีก็จะได้หาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป ผลการสอบสวนเบื้องต้นนี้มีผลอย่างยิ่งในการดำเนินคดีอาญาเพราะจะทำให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินคดีอาญาต่อไปหรือไม่ โดยพนักงานอัยการอาจจะยุติเรื่องไว้หากเห็นว่าการกระทำไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่เป็นความจริง หรืออาจส่งฟ้องต่อศาลโดยตรงหากมีพยานหลักฐานหรือผู้กระทำความผิดรับสารภาพ และหากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนก็อาจทำคำร้องให้ผู้พิพากษาสอบสวนทำการสอบสวนได้

ในการสอบสวนเบื้องต้นนี้ ตำรวจสอบสวนมีอำนาจในการสอบสวนอย่างจำกัดมาก โดยเฉพาะอำนาจที่จะเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ การถามปากคำบุคคล การค้นเคหสถานและยึดของกลาง และการควบคุมตัว และเมื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จแล้ว ตำรวจสอบสวนต้องส่งสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้สงสัยนั้นแก่พนักงานอัยการเพื่อวินิจฉัยว่าควรมีการฟ้องร้องต่อไปหรือไม่ และการสอบสวนจะสิ้นสุดลงทันที หากผู้พิพากษาสอบสวนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวน โดยตำรวจสอบสวนจะมีหน้าที่สอบสวนในข้อหาที่ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาสอบสวนเท่านั้น

(2) การสอบสวนความผิดซึ่งหน้า

สำหรับความผิดซึ่งหน้านี้ จะมีได้แต่เฉพาะกรณีที่เป็นความผิดอุกฤษโทษ (crime) หรือความผิดมัธยโทษ (delit) เท่านั้น ส่วนความผิดลหุโทษ (contravention) ไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า

---

[26]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 63 - 72.

การสอบสวนความผิดซึ่งหน้า ตำรวจสอบสวนจะมีอำนาจมากขึ้นกว่ากรณีการสอบสวนเบื้องต้น โดยมีวิธีรวบรัดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอำนาจที่เป็นมาตรการเชิงบังคับ ทั้งนี้เนื่องจากจะทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นและทำให้สามารถพิสูจน์ความจริงได้โดยมีความผิดพลาดน้อย กล่าวคือ เมื่อตำรวจสอบสวนได้ทราบการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้ว มีหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องไปยังพนักงานอัยการในทันที เมื่อพนักงานอัยการทราบเรื่องแล้วก็สามารถใช้ดุลพินิจได้ว่าจะไปควบคุมการสอบสวนด้วยตนเองหรือไม่ และตำรวจสอบสวนต้องไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว

อำนาจหน้าที่ที่ตำรวจสอบสวนสามารถใช้ในการสอบสวนความผิดซึ่งหน้าได้นั้น ได้แก่ การค้น การยึดสิ่งของ การตั้งผู้เชี่ยวชาญ การถามปากคำพยานและผู้ต้องสงสัย การจับและการควบคุมตัว

อำนาจของตำรวจสอบสวนในการสอบสวนกรณีความผิดซึ่งหน้าจะหมดลง หากพนักงานอัยการซึ่งได้รับแจ้งถึงความผิดที่เกิดขึ้นมายังสถานที่เกิดเหตุ อำนาจต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นอำนาจของพนักงานอัยการในทันที (มาตรา 68 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) แต่พนักงานอัยการสามารถสั่งให้ตำรวจสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปได้ นอกจากนั้นพนักงานอัยการยังมีอำนาจในการออกหมายนำตัวอีกด้วย และหากเป็นคดีที่ไม่ยุ่งยาก พนักงานอัยการสามารถส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องยังศาลได้ทันที

นอกจากนั้น หากผู้พิพากษาสอบสวนมายังที่เกิดเหตุ อำนาจของพนักงานอัยการย่อมหมดลง และเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาสอบสวนที่จะทำหน้าที่สอบสวนหรือมอบให้ตำรวจสอบสวนทำการสอบสวนแทนก็ได้ ในกรณีดังกล่าว พนักงานอัยการอาจขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนเปิดการสอบสวนได้ (Instruction) และผู้พิพากษาสอบสวนก็จะทำหน้าที่ของตนโดยอำนาจตำรวจสอบสวนจะยุติลง แต่ในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้ขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนทำการสอบสวน ผู้พิพากษาสอบสวนก็จะมีอำนาจเท่าที่ตำรวจสอบสวนมีเท่านั้น ซึ่งอาจมอบหมายให้ตำรวจสอบสวนดำเนินการสอบสวนต่อไป และเมื่อการสอบสวนความผิดซึ่งหน้าเสร็จสิ้นลง ผู้พิพากษาสอบสวจะต้องมอบสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการต่อไป โดยพนักงานอัยการอาจดำเนินการฟ้องคดี ยุติ หรือขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนเปิดการสอบสวนได้

(3) การสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน (Instruction)

การสอบสวนในคดีต่าง ๆ หากเป็นคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นความผิดร้ายแรง พนักงานอัยการอาจร้องขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนเปิดการสอบสวน (Instruction) ได้ อย่างไรก็ดี การสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวนนั้น สำหรับความผิดอุกฤษโทษต้องมีการสอบสวนโดย

ผู้พิพากษาสอบสวนเสมอ ส่วนความผิดมัธยโทษและลหุโทษ ไม่จำเป็นต้องสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน (มาตรา 79)

ทั้งนี้ ผู้พิพากษาสอบสวนจะมีอำนาจสอบสวนก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการมีคำร้องขอให้สอบสวนเท่านั้น (requisitoire) แม้จะเป็นกรณีความผิดซึ่งหน้าก็ตาม นอกจากนี้ในความผิดอุกฤษโทษและความผิดมัธยโทษ ผู้เสียหายในคดีอาญาก็สามารถร้องขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนทำการสอบสวนได้ โดยการยื่นคำร้องขอเป็นคู่ความทางแพ่งต่อผู้พิพากษาสอบสวนและผู้พิพากษาสอบสวนจะส่งคำร้องนี้ไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนเปิดการสอบสวนได้ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีใดแล้ว จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีนั้นอีกไม่ได้

เมื่อผู้พิพากษาสอบสวนเปิดการสอบสวนแล้ว จะมีอำนาจสอบสวนกว้างขวางมาก เนื่องจากผู้พิพากษาสอบสวนมีสถานะเป็นตุลาการซึ่งเป็นผู้ให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจสอบสวนของผู้พิพากษาสอบสวนเป็นอำนาจสอบสวนในการกระทำที่อ้างว่าเป็นความผิด ดังนั้น ผู้พิพากษาสอบสวนจึงมีอำนาจครอบคลุมถึงบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวได้ แต่หากมีการกระทำอื่น ๆ นอกเหนือจากที่พนักงานอัยการร้องขอให้สอบสวนแล้ว ผู้พิพากษาสอบสวนจะทำการสอบสวนเองไม่ได้ จะต้องแจ้งแก่พนักงานอัยการเพื่อมีคำร้องเพิ่มเติมให้ทำการสอบสวนความผิดของการกระทำที่พบขึ้นใหม่ ทั้งนี้ผู้พิพากษาสอบสวนมีอำนาจทุกประการที่จะเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อเท็จจริงทั้งในด้านที่เป็นคุณและโทษต่อแก่ผู้ต้องหา ได้แก่ อำนาจในการออกหมายอาญาต่าง ๆ ได้แก่ หมายเรียก หมายนำตัว หมายขัง และหมายจับ อำนาจในการสอบถามคำให้การ อำนาจในการค้น อำนาจในการขังผู้ต้องหา และอำนาจปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไข

อย่างไรก็ดี คำสั่งต่าง ๆ ของผู้พิพากษาสอบสวนสามารถอุทธรณ์ยังศาลสอบสวนชั้นอุทธรณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาต้องให้ศาลสอบสวนชั้นอุทธรณ์พิจารณาอีกครั้งเสมอ

3.2.1.2 ขั้นตอนหลังการฟ้องคดีอาญา

เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว การพิจารณาคดีของศาลมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่สำคัญ[27] ได้แก่ หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

---

[27]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 80 - 86.

หลักการพิจารณาคดีเป็นองค์คณะ หลักการให้เหตุผลในคำพิพากษา กล่าวคือ หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยเป็นหลักประกันแก่จำเลยว่าจำเลยจะได้รับการพิจารณาคดีโดยยุติธรรม และความจริงต้องปรากฏออกมาในการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยดังกล่าว โดยกำหนดเป็นหลักทั่วไปว่าการพิจารณาคดีของศาลต้องทำโดยเปิดเผยเสมอ อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นไม่ให้มีการพิจารณาคดีโยเปิดเผยได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และโดยที่การรับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆ จะต้องกระทำโดยวาจาต่อหน้าศาลในห้องพิจารณาและพยานหลักฐานที่จะนำมาเสนอนั้นเป็นไปตามหลักการเสนอพยานหลักฐานโดยอิสระ ส่วนศาลจะรับฟังเพียงใดหรือไม่เป็นไปตามหลักความเชื่อโดยสุจริตใจของผู้พิพากษาจากการรับฟังการเบิกความของพยานต่าง ๆ ในศาลโดยวาจา และจากหลักการรับฟังพยานดังกล่าวทำให้การรับฟังพยานมีความเกี่ยวพันกับเรื่องจิตวิทยาพยานหลักฐาน โดยหลักทั่วไปการพิจารณาคดีของศาลจึงต้องเป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีเป็นองค์คณะ เพื่อให้ผู้พิพากษาทั้งคณะช่วยกันรับฟังพยานหลักฐานซึ่งจะทำให้มีข้อผิดพลาดในการรับฟังพยานหลักฐานน้อยลง นอกจากนี้เนื่องจากศาลมีความเป็นอิสระในการดำเนินอรรถคดีทั้งปวงโดยไม่มีอำนาจใดมาควบคุม ดังนั้นเพื่อเป็นการคานและตรวจสอบอำนาจของผู้พิพากษา กฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้พิพากษาจะต้องให้เหตุผลไว้ในคำพิพากษาด้วย เพื่อเป็นหลักประกันแก่จำเลยว่าคำพิพากษานั้นได้ไตร่ตรองด้วยความถี่ถ้วนแล้ว เพื่อเป็นหลักประกันแก่บุคคลทั่วไปว่าคำพิพากษานั้นเป็นผลของการใช้เหตุผลที่แท้จริง ไม่ใช่การตัดสินตามอำเภอใจ และเพื่อเป็นการตรวจสอบคำพิพากษาโดยศาลสูง ในกรณีมีการคัดค้านคำพิพากษานั้นว่ามีการปรับใช้กฎหมายโดยถูกต้องหรือไม่

3.2.2 **หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา**

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ได้วางหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยไว้หลายประการในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ได้แก่

(1) อารัมภบทของรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ประชาชนฝรั่งเศสยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติดังที่ได้บัญญัติไว้ในปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ซึ่งได้รับการยืนยันและขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1946 รวมทั้งบรรดาสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2004

(2) การจับกุมคุมขังบุคคลใดตามอำเภอใจจะกระทำมิได้ และให้องค์กรตุลาการในฐานะผู้คุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นผู้ดูแลให้มีการเคารพหลักการนี้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 66)

(3) ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ข้อ 7 กำหนดว่า บุคคลใดจะถูกกล่าวหา จับกุม หรือคุมขังได้ก็แต่ในกรณีที่มีการระบุไว้ในรัฐบัญญัติ และตามรูปแบบที่รัฐบัญญัติกำหนดไว้เท่านั้น และข้อ 9 กำหนดว่า บุคคลทุกคนย่อมได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการประกาศว่าบุคคลนั้นมีความผิด ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องจับกุมผู้ใด การใช้กำลังโดยไม่จำเป็นเพื่อให้ได้ตัวบุคคลนั้นมาจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดตามที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติ

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวางหลักทั่วไปว่า (มาตรา 1-P)

(1) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องเป็นไปโดยความยุติธรรม โดยระบบกล่าวหา และต้องรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิของคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยมีการแยกกระบวนการในชั้นสอบสวนฟ้องร้องออกจากชั้นพิจารณาพิพากษา และบุคคลต้องได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาคกัน

(2) บุคคลผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษาว่าบุคคลนั้นกระทำความผิด และต้องได้รับการแจ้งข้อหาเมื่อถูกจับรวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมาย มาตรการบังคับต้องกระทำโดยหมายของศาลและต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับการพิพากษาคดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีสิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลสูง

3.2.3 **การขังระหว่างสอบสวน**

การขังระหว่างสอบสวนนั้น เมื่อเปิดการสอบสวนแล้ว ผู้พิพากษาสอบสวนมีอำนาจในการขังผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งอำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจเฉพาะของผู้พิพากษาซึ่งต้องออกเป็นหมายขัง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 144 - 150 วางหลักทั่วไปว่า ก่อนมีคำพิพากษาจะต้องปล่อยให้ผู้ต้องหาเป็นอิสระ และการขังเป็นข้อยกเว้น

3.2.3.1 **เหตุของการขังระหว่างสอบสวน**

(1) อัตราโทษที่ศาลสามารถสั่งขังได้ (มาตรา 143-1)

1. ความผิดอุกฤษโทษ ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถสั่งขังได้เสมอ

2. ความผิดมัธยโทษ ศาลจะสั่งขังได้ก็ต่อเมื่อความผิดนั้นมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

3. ความผิดลหุโทษ ศาลไม่อาจสั่งขังได้เลย

(2) เหตุของการขังระหว่างสอบสวน (มาตรา 144)[28]

ศาลจะสั่งขังหรือสั่งขังต่อได้ต่อเมื่อการขังระหว่างพิจารณาเป็นมาตรการเดียวที่จะสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ได้ (มาตรา 144)

1. เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของหลักฐานหรือร่องรอยต่าง ๆ ในคดี หรือเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาข่มขู่พยาน ผู้เสียหาย และครอบครัว รวมถึงเพื่อป้องกันการหารือระหว่างผู้ต้องหากับผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่น ๆ เพื่อบิดเบือนคำให้การ

2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกสอบสวนเอง หรือเพื่อเป็นหลักประกันในการนำตัวผู้ต้องหาฟ้องร้องต่อศาล หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดขึ้นใหม่

3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยหยุดการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในระดับที่รุนแรงและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของความผิดหรือความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น

3.2.3.2 การไต่สวนเพื่อมีคำสั่งขัง

ผู้พิพากษาที่จะออกคำสั่งขังผู้ต้องหา จะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิในการมีทนายความและมีระยะเวลาตามควรที่จะเตรียมการสู้คดี

---

[28]CODE OF CRIMINAL PROCEDURE of France

Article 144

Pre-trial detention may only be ordered or extended if it is the only way:

1º to preserve material evidence or clues or to prevent either witnesses or victims or their families being pressurized or fraudulent conspiracy between persons under judicial examination and their accomplices;

2º to protect the person under judicial examination, to guarantee that he remains at the disposal of the law, to put an end to the offence or to prevent its renewal;

3º to put an end to an exceptional and persistent disruption of public order caused by the seriousness of the offence, the circumstances in which it was committed, or the gravity of the harm that it has caused.

ทนายที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว และก่อนวันที่มีคำสั่งขังผู้ต้องหา ทนายความมีสิทธิตรวจดูสำนวนการสอบสวนและมีสิทธิติดต่อผู้ต้องหา

ผู้พิพากษาจะออกคำสั่งขังได้ต่อเมื่อมีการพิจารณาต่อหน้าพนักงานอัยการ ผู้ต้องหาและทนายความ (หากมี) และหากผู้ต้องหาขอระยะเวลาในการเตรียมสู้คดี ผู้พิพากษามีสิทธิสั่งขังไว้ชั่วคราวโดยระบุมูลเหตุในการสั่งขังไว้ไม่เกินกว่า 4 วันทำการ ก่อนที่จะมีการพิจารณาเพื่อมีออกคำสั่งขังผู้ต้องหา ระยะเวลาขังชั่วคราวจะต้องหักออกจากระยะเวลาการขังตามปกติ (มาตรา 145)

หากผู้พิพากษามีคำสั่งประการใดแล้ว พนักงานอัยการและผู้ต้องหามีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาลสอบสวนขั้นอุทธรณ์ได้

3.2.3.3 ระยะเวลาขังระหว่างสอบสวน

ระยะเวลาขังต้องไม่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร เมื่อพิจารณาประกอบกับความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและความซับซ้อนของการสืบสวนและการสอบสวนซึ่งจำเป็นเพื่อค้นหาความจริง และผู้พิพากษาสอบสวนต้องสั่งให้ปล่อยผู้ต้องหาทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเหตุการขังระหว่างสอบสวนตามมาตรา 144 และตามมาตรา 144-1 นี้ โดยการปล่อยผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรา 147 (มาตรา 144-1)[29]

ระยะเวลาที่ผู้พิพากษาสามารถสั่งขังได้นั้น เป็นไปตามประเภทความผิด ดังนี้

(1) ความผิดมัธยโทษ ระยะเวลาการขังต้องไม่เกิน 4 เดือน ถ้าผู้ถูกต้องหาไม่เคยถูกลงโทษว่ากระทำความผิดอุกฤษโทษหรือมัธยโทษมากกว่า 1 ปี มาก่อน และความผิดที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำในครั้งนี้มีโทษจำคุกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี

---

[29]CODE OF CRIMINAL PROCEDURE of France

Article 144-1

Pre-trial detention may not exceed a reasonable length of time in respect of the seriousness of the charges brought against the person under judicial examination and of the complexity of the investigations necessary for the discovery of the truth.

The investigating judge, or where seised the liberty and custody judge, must order the immediate release of the person placed in pre-trial detention, pursuant to the terms provided for by article 147, as soon as the conditions provided under article 144 and under the present article are no longer fulfilled.

ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้พิพากษาสามารถสั่งขยายระยะเวลาขังได้อีกไม่เกิน 4 เดือน โดยคำสั่งศาลซึ่งต้องอธิบายและให้เหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 137 – 3 และต้องจัดให้มีการชี้แจงของผู้ต้องหา ตามมาตรา 145 วรรคหก และโดยมีทนายความของผู้ต้องหาร่วมอยู่ด้วย

ภายใต้บังคับมาตรา 145-3 ศาลสามารถสั่งขยายระยะเวลาได้อีกโดยใช้กระบวนการเดิม แต่ระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณาทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตามระยะเวลานี้ สามารถขยายออกไปได้อีกเป็น 2 ปี เมื่อเป็นกรณีที่การกระทำความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร หรือเมื่อบุคคลนั้นถูกสอบสวนในความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การสมคบการกระทำความผิดอาญา การค้ามนุษย์ การกรรโชกทรัพย์ หรือความผิดอุกฤษโทษที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม และเมื่อความผิดนั้นมีโทษจำคุก 10 ปี

ในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างยิ่ง เมื่อยังมีความจำเป็นต้องทำการสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน และการปล่อยตัวผู้ต้องหาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ 2 ปี ได้ออกไปอีก 4 เดือน โดยผู้พิพากษาสอบสวนต้องให้เหตุผลและมีการไต่สวนภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 137-1 วรรคสี่ และต้องดำเนินการพิจารณาตามมาตรา 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 และ 207 (มาตรา 145-1)[30]

---

[30]CODE OF CRIMINAL PROCEDURE of France

Article 145-1

Detention may not be in excess of four months in misdemeanour matters if the person under judicial examination has not previously been sentenced, in respect of a felony or an ordinary misdemeanour, to an unsuspended prison sentence of at least a year, and when he is at risk of a sentence of five years or less.

In any other case, the liberty and custody judge may exceptionally decide to extend the pre-trial detention for period not in excess of four months, in a reasoned decision in accordance with the provisions of article 137-3 and delivered after a debate organised in accordance with the provisions of the sixth paragraph of article 145, where

(2) ความผิดอุกฤษโทษ ห้ามมิให้สั่งขังผู้ต้องหาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม เว้นแต่กรณีตามมาตรา 145-3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปีนั้น ผู้พิพากษาสามารถสั่งให้ขยายระยะเวลาต่อได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยคำสั่งศาลซึ่งต้องให้เหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 137– 3 และต้องจัดให้มีการชี้แจงของผู้ต้องหา ตามมาตรา 145 วรรคหก และโดยมีทนายความของผู้ต้องหาร่วมอยู่ด้วย คำสั่งขยายนี้สามารถสั่งขยายต่อได้อีกด้วยกระบวนการพิจารณาเดียวกัน

ผู้ต้องหาไม่สามารถถูกขังได้เกินกว่า 2 ปี เมื่อความผิดนั้นมีโทษต่ำกว่า 20 ปี และไม่สามารถถูกขังได้เกินกว่า 3 ปี ในกรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจขยายระยะเวลาขังเป็น 3 และ 4 ปี ในกรณีที่การกระทำความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร และ 4 ปี ในกรณีที่บุคคลนั้นถูกสอบสวนเกี่ยวกับความผิดอุกฤษโทษใน Books II and IV ของ

---

the advocate has been duly summoned according to the provisions of the second paragraph of article 114.

This decision may be renewed following the same procedure, subject to the provisions of article 145-3. The total duration of the detention may not exceed a year. However, this time limit is extended to two years where one of the component parts of the offence was committed outside the national territory, or where the person is being prosecuted for drug trafficking, terrorism, criminal conspiracy, living off immoral earnings, extortion of money or for a felony committed by an organised gang and which carries a sentence of ten years' imprisonment.

In exceptional cases, where the investigating judge must continue his inquiries and releasing the person under judicial examination would pose a particularly serious risk to persons and property, the investigating chamber may increase the period of two years provided for by the present article by a further four months. The investigating chamber, which the person under examination has the right to appear before in person, is seised by a reasoned decision from the liberty and custody judge, under the conditions set out by the last paragraph of article 137-1, and it rules according to the provisions of articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 and 207.

ประมวลกฎหมายอาญา การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การกรรโชกทรัพย์ หรือความผิดอุกฤษโทษที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม

ในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างยิ่ง เมื่อยังมีความจำเป็นต้องทำการสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน และการปล่อยตัวผู้ต้องหาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ออกไปได้อีก 4 เดือน โดยผู้พิพากษาสอบสวนชั้นอุทธรณ์ต้องให้เหตุผลและมีการไต่สวนภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 137-1 วรรคสี่ และต้องดำเนินการพิจารณาตามมาตรา 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 และ 207 คำสั่งขยายนี้ สามารถขยายต่อได้อีกครั้งหนึ่งด้วยกระบวนการพิจารณาเดียวกัน

มาตรานี้ใช้บังคับได้จนกระทั่งมีคำสั่งปิดการสอบสวน (มาตรา 145-2)[31]

---

[31]CODE OF CRIMINAL PROCEDURE of France

Article 145-2

For a suspected felony, the person under judicial examination may not be kept under detention for more than ayear. However, subject to the provisions of article 145-3, the liberty and custody judge may, upon the expiry of this time limit, extend the detention for a length of time which may not exceed six months, in a reasoned decision in accordance with the provisions of article 137-3 and delivered after an adversarial hearing organised in accordance with the provisions of the sixth paragraph of article 145, the advocate having been duly summoned in accordance with the provisions of the second paragraph of article 114. This decision may be renewed by following the same procedure.

The person under judicial examination may not be kept in custody for more than two years, where the applicable sentence is less than twenty years' imprisonment, and for more than three years in all other cases. The time limits are extended to three and four years respectively where one of the elements of the offence has been committed outside the national territory. The time limit is also four years where the person is being prosecuted for one or more felonies mentioned in Books II and IV of the

ทั้งนี้ เมื่อขังเกินกว่า 1 ปี ในความผิดอุกฤษโทษ หรือเกินกว่า 8 เดือน ในความผิดมัธยโทษ การขยายระยะเวลาขังหรือยกคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจะต้องมีเหตุผลพิเศษเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคาดหมายระยะเวลาสิ้นสุดของกระบวนพิจารณาได้ (มาตรา 145-3)[32]

Criminal Code, or for drug trafficking, terrorism, living off immoral earnings, extortion of money or for a felony committed by an organised gang.

In exceptional cases, where the investigating judge must continue his inquiries and releasing the person under examination would create a particularly serious risk to persons and property, the investigating chamber may increase the detention periods provided for by the present article by a further four months. The investigating chamber, before which the person under examination has the right to appear in person, is seised by a reasoned decision from the liberty and custody judge, under the conditions set out by the last paragraph of article 137-1, and it rules according to the provisions of articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 and 207. This ruling may be renewed once under the same conditions and in the same manner.

The provisions of the present article are applicable until the order closing the examination.

[32]CODE OF CRIMINAL PROCEDURE of France

Article 145-3

Where the length of the pre-trial detention is in excess of one year for a felony, or eight months for a misdemeanour, the decisions ordering its extension or dismissing the applications for release must also include the specific indications which justify in the given case the continuance of the investigation and the foreseeable delay for the ending of the procedure.

It is, however, not necessary for the extension order to indicate the nature of the investigations which the investigating judge is intending to carry out, where this indication risks hindering the carrying out of these investigations.

3.2.3.4 การปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และยังคงมีเสรีภาพ กล่าวคือ จะต้องปล่อยผู้ต้องหาเป็นอิสระ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเพื่อการสอบสวนหรือเพื่อเป็นวิธีการเพื่อการรักษาความปลอดภัย สามารถสั่งให้มีการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขได้ อย่างไรก็ดี ถ้าการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้และเป็นกรณียกเว้นจึงจะสั่งขังผู้ต้องหาได้ (มาตรา 137)

(1) เงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว

1. ผู้ต้องหาจะต้องถูกกล่าวหาในความผิดที่มีโทษจำคุกมัธยโทษหรือสูงกว่า (มาตรา 138 วรรคหนึ่ง)

2. จะต้องมีความจำเป็นเพื่อการสอบสวนหรือเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย (มาตรา 137)

3. ผู้พิพากษาจะต้องออกเป็นคำสั่งที่กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ต้องหาจะต้องปฏิบัติระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว (มาตรา 138) ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหลบหนี หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดซ้ำ หรือเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในการรักษาพยาบาล หรือเป็นเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย นอกจากการกำหนดเงื่อนไขแล้วบางกรณีผู้พิพากษาอาจสั่งให้ผู้ต้องหาจัดหาหลักประกันด้วยก็ได้ (มาตรา 142 และมาตรา 139 วรรคหนึ่ง (11)) ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (มาตรา 139) หรืออาจยกเลิกการปล่อยชั่วคราวก็ได้ (มาตรา 140)

(2) การร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราว

1. ในทุกคดี การปล่อยชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขนั้น ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งปล่อยชั่วคราวได้หลังจากที่ได้รับฟังความเห็นของพนักงานอัยการแล้วโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ต้องหาต้องมาปรากฏตัวในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณาและแจ้งให้ผู้พิพากษาสอบสวนทราบถึงการเคลื่อนไหวของเขาเสมอ (มาตรา 147 วรรคหนึ่ง)

2. พนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวได้เสมอ (มาตรา 147 วรรคสอง)

3. ผู้ต้องหาหรือทนายความสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวได้เสมอ ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 147 ในกรณีไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหามีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อศาลสอบสวนขั้นอุทธรณ์ ซึ่งต้องวินิจฉัยภายใน 20 วัน มิฉะนั้นแล้วจะต้องปล่อยผู้ต้องหาทันที (มาตรา 148)[33]

3.2.4 **การขังระหว่างรอการเริ่มพิจารณา**

ถ้าผู้พิพากษาสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการกระทำความผิดอุกฤษโทษ หรือความผิดมัธยโทษ หรือความผิดลหุโทษ หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ทำการสอบสวน ผู้พิพากษาสอบสวนจะต้องสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ถูกขังระหว่างสอบสวนต้องได้รับการปล่อย และมีคำสั่งปิดการสอบสวน (มาตรา 177)

ถ้าผู้พิพากษาสอบสวนพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ส่งให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อ แบ่งออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ

3.2.4.1 **กรณีความผิดมัธยโทษ (มาตรา 179)**

กรณีเป็นความผิดมัธยโทษ ส่งไปพิจารณาพิพากษาที่ศาล Tribunal correctional โดยคำสั่งปิดการสอบสวนทำให้การขังระหว่างสอบสวนและการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขสิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถสั่งขังจำเลยต่อไปได้จนกว่าจะเริ่มกระบวนพิจารณาในชั้นศาล โดยมีคำสั่งแยกต่างหากและมีเหตุผลพิเศษ ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาขังระหว่างสอบสวน คำสั่งขังต่อนี้จะต้องเป็นมาตรการพิเศษเมื่อกรณีมีความจำเป็นเพื่อป้องกันพยานหรือผู้เสียหาย หรือป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดขึ้นอีก หรือป้องกันจำเลยหรือเป็นการประกันการมีตัวของจำเลย นอกจากนี้ คำสั่งในลักษณะนี้สามารถสั่งได้ในกรณีที่ความผิดนั้นมีความร้ายแรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายมากหรือสามารถก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อประชาชนซึ่งอาจยับยั้งได้เมื่อมีการขยายระยะเวลาขังก่อนการพิจารณาเท่านั้น

จำเลยที่ถูกขังอยู่ต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีถ้าศาล Tribunal correctional ไม่เริ่มพิจารณาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่มีคำสั่งส่งคดีมาฟ้องยังศาลนี้

อย่างไรก็ตาม หากการพิจารณาคดีไม่สามารถเกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีพิเศษ ศาลอาจสั่งขยายระยะเวลาขังได้อีก 6 เดือน โดยระบุเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย คำสั่งนี้สามารถขยายได้อีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยเงื่อนไขเดิม ถ้าสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายแล้วจำเลยยังไม่ได้รับการพิจารณาคดี ต้องปล่อยตัวจำเลยทันที

---

[33]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 77 - 78.

3.2.4.2 กรณีความผิดอุกฤษโทษ (มาตรา 181)

กรณีเป็นความผิดอุกฤษโทษ ส่งไปพิจารณายังศาลลูกขุน (Cour d'assises) การปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขยังคงใช้บังคับได้

ส่วนการขังระหว่างสอบสวนหรือการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขในกรณีที่เกี่ยวกับความผิดมัธยโทษต้องสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกรณีตามมาตรา 179 วรรคสาม โดยระยะเวลาตามมาตรา 179 วรรคสี่ ขยายออกไปได้ 6 เดือน

ถ้าผู้ต้องหาถูกขังระหว่างสอบสวน คำสั่งขังยังคงบังคับใช้จนกว่าจะเริ่มการพิจารณาในศาลลูกขุน (Cour d'assises)

ผู้ต้องหาที่ถูกขังก่อนขึ้นศาลลูกขุน (Cour d'assises) ต้องได้รับการปล่อยตัวทันที ถ้าศาลลูกขุน (Cour d'assises) ไม่เริ่มพิจารณาคดีภายในสิ้นปีนับแต่วันที่มีคำสั่งฟ้องคดีหรือวันที่มีคำสั่งขังระหว่างสอบสวน

อย่างไรก็ตาม ถ้าการพิจารณาคดีไม่สามารถเกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีพิเศษ ผู้พิพากษาสอบสวนอาจสั่งขยายระยะเวลาขังออกไปอีก 6 เดือน โดยคำสั่งต้องระบุทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย คำสั่งนี้ขยายได้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยเงื่อนไขเดิม ถ้าสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายแล้ว จำเลยยังไม่ได้รับการพิจารณาคดี ต้องปล่อยตัวจำเลยทันที

3.2.5 การขังระหว่างพิจารณา

เมื่อมีการสอบสวนและฟ้องคดีมายังศาลแล้ว และผู้พิพากษาสอบสวนยังไม่ปล่อยตัว ก็เป็นอำนาจของศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้พิจารณาปล่อยตัว[34]

การพิจารณาปล่อยตัวจำเลยของศาลนั้น ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับในชั้นสอบสวน กล่าวคือ เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแล้ว การปล่อยชั่วคราวให้นำไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 148-2 กล่าวคือ ในทุกศาล การพิจารณาคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการ จำเลย หรือทนายความด้วย (มาตรา 143 ประกอบมาตรา 148-2) ทั้งนี้ ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 139 หรือการยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขตามมาตรา 140 ได้ ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 148-1 และการยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวสามารถยื่นได้เสมอโดยผู้ต้องหาหรือจำเลย (มาตรา 141-1 ประกอบมาตรา 148-1)

---

[34]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 76.

ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณา สำหรับศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีให้นำเรื่องการขังระหว่างสอบสวนมาใช้ด้วย (มาตรา 148-1)[35]

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีคำพิพากษาจำคุก ระยะเวลาที่ผู้นั้นต้องขังอยู่จะต้องหักออกจากระยะเวลาต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา ในกรณีมีคำพิพากษาปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในภายหลัง ผู้นั้นจะได้รับชดใช้ค่าทดแทนหากเขาได้รับความเสียหายที่ผิดปกติอย่างชัดเจนและเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นพิเศษ (มาตรา 149 และมาตรา 150)[36]

---

[35]CODE OF CRIMINAL PROCEDURE of France

Article 148-1

A release may also be requested in every case by any person under judicial examination, defendant or accused person and at any stage of the proceedings.

Where a trial court is seised of the case, it must rule on the pre-trial detention. However, in felony cases, the court of assizes is only competent where the application is made during the session within which it must judge the accused. In all other cases, the request is examined by the investigating chamber.

…

[36] ณรงค์ ใจหาญ และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6* , น. 77.

บทที่ 4

การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล และการจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุมขังบุคคลไว้ กล่าวคือ ในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง ได้แก่ การควบคุมระหว่างสอบสวน การขังระหว่างสอบสวน และการขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง และในชั้นพิจารณาพิพากษา ได้แก่ การขังระหว่างพิจารณา และการขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาเพื่อนำไปสู่ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาและการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาต่อไป

4.1 <u>วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา</u>

4.1.1 **หลักการพื้นฐานของการขังระหว่างพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22) บัญญัติว่า “การขัง หมายถึง การกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล”

และมาตรา 57 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จำคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้น

บุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล”

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วางหลักการสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา ดังนี้

1. มุ่งคุ้มครองเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นหลัก การจำกัดเสรีภาพในชีวิตร่างกายโดยการจับและคุมขังบุคคลเป็นข้อยกเว้น

2. กำหนดให้ศาลเท่านั้นที่มีอำนาจออกหมายจับ หมายขัง หมายจำคุก และหมายค้น เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งให้ศาลเท่านั้นที่มีอำนาจในการออกหมายปล่อยบุคคลตามหมายขังหรือหมายจำคุกด้วย

สำหรับการขังนั้น มาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาแล้ว ในระยะใดระหว่างสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 ก็ได้ และให้นำบทบัญญัติในมาตรา 66 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ดังนั้น การออกหมายขังของศาลทำได้ 3 ระยะ กล่าวคือ ระหว่างการสอบสวน[1] ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี[2] และระหว่างการพิจารณา[3]

สำหรับการขังระหว่างพิจารณานั้น มาตรา 88 บัญญัติว่า “คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้” เมื่อพิจารณามาตรา 88 ประกอบกับมาตรา 59 มาตรา 66 และมาตรา 71 ที่กำหนดให้ศาลเป็นผู้พิจารณาเหตุจำเป็นในการออกหมายขังตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อนออกหมายขังแล้ว จึงสามารถสรุปได้ว่า

---

[1]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87

[2]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165

[3]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88

การขังระหว่างพิจารณา หมายถึง การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี เนื่องจากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยไว้ในอำนาจศาลตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำเลยจะได้รับการปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก และการขังเป็นข้อยกเว้น ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นในการพิจารณาว่าจะมีคำสั่งศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้

4.1.2 **เหตุการออกหมายขังระหว่างพิจารณา**

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุในการขังระหว่างพิจารณาไว้ ตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 66 มาตรา 59 และมาตรา 59/1 กล่าวคือ

มาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาแล้ว ในระยะใดระหว่างสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 ก็ได้ และให้นำบทบัญญัติในมาตรา 66 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา 66 บัญญัติว่า “เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ

(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี”

มาตรา 59 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้”

มาตรา 59/1 “ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 71

คำสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกคำร้อง จะต้องระบุเหตุผลของคำสั่งนั้นด้วย

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา”

จะเห็นได้ว่า เหตุในการออกหมายขังเป็นเหตุเดียวกันกับเหตุในการออกหมายจับ โดยศาลจะออกหมายขังตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้ และการออกหมายขังต้อง

พิจารณาตามหลักการมีหลักฐานตามสมควร (probable cause) และศาลต้องแสดงเหตุผลของคำสั่งที่ให้ออกหมายขังโดยชัดแจ้งด้วย

4.1.3 กำหนดระยะเวลาของหมายขังระหว่างพิจารณา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสอง บัญญัติว่า "หมายขังคงใช้ได้อยู่จนกว่าศาลจะได้เพิกถอน โดยออกหมายปล่อยหรือออกหมายจำคุกแทน" ดังนั้น มาตรานี้จึงเป็นการกำหนดระยะเวลาของหมายขังไว้ว่าใช้ได้จนกว่าศาลจะได้เพิกถอน

สำหรับเหตุในการออกหมายปล่อยระหว่างพิจารณานั้น มาตรา 72 บัญญัติว่า "หมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งต้องขังอยู่ตามหมายศาล ให้ออกในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อศาลสั่งปล่อยชั่วคราว

(2) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอให้ศาลปล่อย โดยเห็นว่าไม่จำเป็นต้องขังไว้ระหว่างสอบสวน

(3) เมื่อพนักงานอัยการร้องต่อศาลว่าได้ยุติการสอบสวนแล้วโดยมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา

(4) เมื่อพนักงานอัยการไม่ฟ้องผู้ต้องหาในเวลาที่ศาลกำหนด

(5) เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลและสั่งให้ยกฟ้อง เว้นแต่เมื่อโจทก์ร้องขอและศาลเห็นสมควรให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา

(6) เมื่อโจทก์ถอนฟ้องหรือมีการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว หรือเมื่อศาลพิจารณาแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งยกฟ้อง เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ฎีกา

(7) เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษจำเลยอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่โทษประหารชีวิต จำคุกหรือให้อยู่ภายในเขตที่อันมีกำหนด ถ้าโทษอย่างอื่นนั้นเป็นโทษปรับเมื่อจำเลยได้เสียค่าปรับแล้ว หรือศาลให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีกำหนดวันเพื่อให้จำเลยหาเงินค่าปรับมาชำระต่อศาล"

จะเห็นได้ว่า การออกหมายปล่อยกรณีมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณานั้นกระทำได้โดยการปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 72 (1)

4.2 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกขังระหว่างการพิจารณา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้

4.2.1 หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 บัญญัติว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”

จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรองรับหลักการสากลในเรื่องการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น จำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาจึงได้รับหลักประกันสิทธินี้ตามหลักของรัฐธรรมนูญ นับแต่การออกหมายขังระหว่างพิจารณา ซึ่งศาลต้องพิจารณากลั่นกรองตามเหตุแห่งการออกหมายขังประกอบกับหลักฐานตามสมควรว่าจำเลยควรต้องถูกขังระหว่างพิจารณาหรือไม่ และเมื่อจำเลยต้องถูกขังระหว่างพิจารณาก็จะปฏิบัติต่อจำเลยเสมือนเป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ได้

4.2.2 สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 40 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยใน (7) บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิ ... ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว” และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 - มาตรา 119 ทวิ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวไว้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการปล่อยชั่วคราวอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อได้รับคำร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดย

อาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และมาตรา 113/1 .." ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญยิ่งของจำเลยในอันที่จะได้รับการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก และรัฐต้องรีบพิจารณาดำเนินการเพื่อปล่อยชั่วคราวอย่างรวดเร็ว ส่วนการไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นข้อยกเว้นซึ่งต้องพิจารณาโดยเคร่งครัด

4.2.3 **สิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 40 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยใน (7) บัญญัติว่า "ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม" และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 179 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ศาลจะดำเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม่เลื่อนก็ได้" และมาตรา 8 บัญญัติว่า "นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จำเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้ (1) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ..."

สำหรับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นั้นศาลยุติธรรมได้มีการแก้ไขปัญหาการพิจารณาคดีล่าช้าโดยการนำระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องมาใช้แทนระบบเดิมซึ่งจะมีการนัดสืบพยานหลักฐานเป็นคราว ๆ โดยศาลจะนัดพิจารณาคดีติดต่อกันจนเสร็จทีละคดีตามลำดับโดยใช้ระบบศูนย์นัดความและระบบกำหนดวันนัดตามประเภทของคดี และนำมาตรการเปิดเผยพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 มาใช้ กล่าวคือ คดีที่จะเปิดเผยพยานตามกฎหมายได้ต้องเป็นคดีที่จำเลยไม่ให้การหรือจำเลยให้การปฏิเสธเท่านั้น และต้องกระทำเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมด้วย หากคดีอาญาเรื่องใด สภาพและลักษณะคดีไม่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องกระทำการโดยเปิดเผย กรณีย่อมไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 173/1 นอกจากนี้ยังให้อำนาจศาลมีดุลพินิจที่จะกำหนดให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานก่อนการ

พิจารณาคดีได้อย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถบริหารจัดการคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น[4]

ส่วนการพิจารณาคดีโดยเป็นธรรม นั้น ศาลย่อมผูกพันต่อหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญาต่าง ๆ เช่น สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ และมาตรา 40 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

4.3 <u>การตรวจสอบและถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณา</u>

4.3.1 การปล่อยชั่วคราว

4.3.1.1 ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (3) บัญญัติว่า “คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาลย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้ ... (3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น ...”

4.3.1.2 หลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราว

เนื่องจากการปล่อยชั่วคราวเป็นอำนาจของศาลในการพิจารณาตามสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวข้างต้น อย่างไรก็ดีการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีกรอบในการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมาตรา 108 และมาตรา 108/1 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ

มาตรา 108 บัญญัติว่า “ในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ

(1) ความหนักเบาแห่งข้อหา

(2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด

---

[4]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , <u>รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา</u> , (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2551) , น. 92.

(3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร

(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด

(5) ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่

(6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่

(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องด้วยก็ได้

ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หรือกำหนดเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวก็ได้”

และมาตรา 108/1 บัญญัติว่า “การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี

(2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

(3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น

(4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ

(5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล

คำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย และผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว”

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวไว้อย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับเหตุในการออกหมายจับและหมายขังตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 66 และมาตรา 59/1 นั่นเอง นอกจากนี้ยังกำหนดให้ศาลต้องให้เหตุผลในคำสั่งโดยชัดเจนและต้องแจ้งให้แก่ผู้ถูกจำกัดสิทธิได้ทราบโดยเร็วด้วย

4.3.1.3 กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

หากศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปได้ตามมาตรา 119 ทวิ ได้ โดยมาตรา 119 ทวิ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ดังต่อไปนี้

(1) คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์

(2) คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา

ให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งรีบส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมด้วยสำนวนความหรือสำเนาสำนวนความเท่าที่จำเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งโดยเร็ว

คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องให้ปล่อยชั่วคราวใหม่”

จะเห็นได้ว่า กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและศาลออกหมายขังจำเลยระหว่างพิจารณา นั้น จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของศาลชั้นต้นในการสั่งขังจำเลยระหว่างพิจารณาได้ เนื่องจากจำเลยสามารถทราบเหตุผลในการสั่งของศาลอย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ แม้ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยก็สามารถยื่นคำร้องการร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้อีกตลอดระยะเวลาที่ถูกขังระหว่างพิจารณาโดยไม่มีข้อจำกัดอีกด้วย

4.3.2 การร้องขอให้ปล่อยจากการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 บัญญัติว่า “เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ

(1) ผู้ถูกคุมขังเอง

(2) พนักงานอัยการ

(3) พนักงานสอบสวน

(4) ผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัศดี

(5) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง

เมื่อได้รับคำร้องดั่งนั้น ให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูล ศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดง

ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที"

ทั้งนี้ กรณีที่มีการขังโดยไม่มีความจำเป็นหรือกรณีขังเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เห็นว่าสามารถยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตามมาตรานี้ได้ นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้วางแนวคำพิพากษาตลอดมาว่า การควบคุมหรือขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี้เป็นถ้อยคำในความหมายธรรมดา หาใช่ความหมายตามคำจำกัดความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (21) และ (22) ไม่ ดังนั้นการควบคุมอาจเกิดจากบุคคลธรรมดาก็ได้ เช่น ภริยาของผู้ร้องถูกคนร้ายฉุดคร่าไปเพื่อข่มขืนและหน่วงเหนี่ยวกักขัง ดังนี้ ผู้ร้องจึงร้องขอต่อศาลให้ปล่อยภริยาของตนตามมาตรา 90 ได้[5] ฉะนั้นถ้าบุคคลต้องถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมหรือขังโดยเจ้าพนักงานหรือบุคคลธรรมดาก็อยู่ในความหมายของคำว่าควบคุมหรือขังตามมาตรา 90 ทั้งสิ้น[6]

4.4 <u>วิเคราะห์การขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทย</u>

4.4.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา

จากหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ องค์กรตุลาการมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำหรับการของการขังระหว่างพิจารณานั้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายและการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของจำเลย และศาลมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาด้วย โดยบทบาททั้งสองของศาลเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลยโดยการขังจำเลยระหว่างพิจารณานี้ต้องกระทำในเวลาเดียวกันควบคู่กันไป ทั้งนี้ ศาลย่อมต้องคำนึงถึงหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็นหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา นอกจากนี้ศาลย่อมต้องใช้หรือ

---

[5]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1200/2504

[6]ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล "การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง", (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 2548), น. 33.

ตีความกฎหมายเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาในลักษณะที่มุ่งคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพและหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยด้วย

4.4.1.1 ลักษณะของเหตุแห่งการออกหมายขังกับการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา

เมื่อพิจารณาตามลักษณะของเหตุแห่งการออกหมายจับและเหตุแห่งการออกหมายขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 และมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แล้วจะพบว่า เหตุออกหมายจับหรือเหตุออกหมายขังนั้น มีทั้ง “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” และ “เหตุที่เป็นเหตุรอง” “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” คือ เหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น ส่วน “เหตุที่เป็นเหตุรอง” คือ เหตุแห่งความร้ายแรงของความผิด

ดังนั้น เมื่อกรณีใดมี “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” แล้ว การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐย่อมมีความจำเป็นเสมอ และส่งผลต่อไปว่าการปล่อยชั่วคราวย่อมกระทำไม่ได้ เพราะจะทำให้การดำเนินคดีไม่อาจเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและขัดขวางต่อการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดี

ส่วนกรณีใดมี “เหตุที่เป็นเหตุรอง” หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความร้ายแรงของความผิด กรณีนั้นย่อมไม่แน่นอนเสมอไปว่าการดำเนินคดีจะไม่อาจเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและจะขัดขวางต่อการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดี เหตุความร้ายแรงของความผิดจึงเป็น “เหตุที่เป็นเหตุรอง” และส่งผลต่อไปเกี่ยวกับการพิจารณาปล่อยชั่วคราว กล่าวคือ ในกรณีของเหตุรองนั้น อาจมีการปล่อยชั่วคราวได้ตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะตามกฎหมายผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติดูเหมือนองค์กรในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ของรัฐไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จะไม่มีการแยกแยะความเป็นเหตุหลักและเหตุรองดังที่กล่าวมา โดยจะพิจารณาเหตุแห่งความร้ายแรงของความผิดซึ่งเป็นเหตุรองในลักษณะเดียวกันกับเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น ซึ่งเป็นเหตุหลัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐนั่นเอง ดังนั้นความคิดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงไม่เกิดขึ้น แต่องค์กรในกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐกลับไปพิจารณากันที่หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ซึ่งแท้จริงแล้วในเรื่องหลักประกันกฎหมายไม่ได้เรียกร้องแต่อย่างใด[7]

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงเกิดกรณีของการขังระหว่างพิจารณาโดยไม่จำเป็นอยู่ด้วย ซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขังระหว่างพิจารณาโดยเหตุรองเพียงเหตุเดียวโดยไม่มีเหตุหลักประกอบ คือ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยน่าจะกระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามปี แต่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น กรณีนี้แม้เข้าหลักเกณฑ์ของการขังระหว่างพิจารณา แต่ศาลควรคำนึงถึงบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยในการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาด้วย เนื่องจากอาจไม่มีกรณีที่จะกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลแต่อย่างใด ศาลจึงสามารถสั่งปล่อยชั่วคราวในกรณีนี้ได้

4.4.1.2 ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

(1) การขังหรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88

เนื่องจากภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นภารกิจของศาล และการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจของรัฐจะกระทำได้ต่อเมื่อกรณีมีความจำเป็นอย่างแท้จริง หลักการดังกล่าวนี้ต้องใช้ในชั้นพิจารณาคดีของศาลด้วย แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 ซึ่งบัญญัติว่า “คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้” จะบัญญัติจนอาจทำให้เข้าใจได้ว่าถ้าไม่มีการขอปล่อยชั่วคราวแล้ว จะต้องเอาตัวไว้ในอำนาจรัฐจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นก็ตาม[8]

---

[7]คณิต ณ นคร, “การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐกับการปล่อยชั่วคราว” ใน กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2553) , น. 60 - 61.

[8]คณิต ณ นคร , “บทบาทของศาลในคดีอาญา”, วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ , ฉบับที่ 1 , (มกราคม - มิถุนายน 2544) , น.58.

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 88 แล้ว เห็นว่า มาตรานี้บัญญัติให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาโดยจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ เพราะฉะนั้น แม้กรณีมีการสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้ว หากแต่ต่อมาศาลพบว่าไม่มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาอีกต่อไป ศาลย่อมต้องปล่อยตัวจำเลยทันที เช่น เป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีอีกต่อไป หรือเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เนื่องจากศาลได้สืบพยานที่มีความสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น ดังนั้น ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาจึงไม่จำเป็นต้องเท่ากับระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โดยระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาจะมีระยะเวลาเพียงเท่าที่มีความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาเท่านั้น หากกรณีไม่มีความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาอีกต่อไป ศาลควรย่อมต้องเข้าคุ้มครองสิทธิของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณานั้นโดยการปล่อยตัวจำเลยทันที

อย่างไรก็ตาม มักมีความเข้าใจว่าเมื่อศาลมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้วต้องเอาตัวจำเลยไว้ในระหว่างพิจารณาจนกว่าจะพิพากษาเสมอ เว้นแต่ กรณีมีคำร้องขออนุญาตปล่อยชั่วคราวและศาลอนุญาต ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการให้ความสำคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อมีการขังระหว่างพิจารณาแล้ว ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในช่วงระยะเวลาระหว่างระยะเวลาที่มีการขังระหว่างพิจารณานั้นอีกต่อไปนั่นเอง

(2) หลักการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม กับการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา

สำหรับหลักการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม นั้นมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อจำเลยซึ่งถูกขังระหว่างพิจารณาในกรณีที่ยังมีความจำเป็นต้องขังจำเลยไว้ในระหว่างพิจารณาต่อไป ดังนั้น หากมีการพิจารณาคดีในระยะเวลาอันสั้น ย่อมทำให้ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในกรณีนี้สั้นลงเช่นกัน ซึ่งจะทำให้สิทธิและเสรีภาพของจำเลยถูกกระทบน้อยลงและเท่าที่จำเป็นตามสมควร

อย่างไรก็ดี แม้การพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม นั้น จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ แต่ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญลำดับรองจากการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา เนื่องจากหากมีการขังระหว่างพิจารณาในกรณีไม่มีความจำเป็นแล้ว แม้มีการพิจารณาคดีด้วยความต่อเนื่องรวดเร็วอย่างไร ย่อมต้องเป็นกรณีที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยอยู่นั่นเอง

4.4.2 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบการขังระหว่างสอบสวนกับการขังระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4.4.2.1 หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา

หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟ้องร้องนั้น เป็นหลักการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมเพื่อค้นหาและตรวจสอบความจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเพื่อนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลเพื่อชี้ขาดข้อเท็จจริงและวินิจฉัยต่อไป กระบวนการในชั้นสอบสวนฟ้องร้องนี้จึงเป็นการดำเนินคดีเป็นการลับเพื่อสืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด และมุ่งดำเนินคดีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอสำนวนหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นนี้ไม่จำต้องกระทำต่อหน้าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนื่องจากยังเป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง อย่างไรก็ดีเมื่อมีการฟ้องร้องในชั้นศาลแล้วต้องนำตัวจำเลยเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วย

ส่วนหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมในชั้นพิจารณาพิพากษานั้น ต้องเป็นการดำเนินคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยเพื่อให้โอกาสแก่จำเลยในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีต่อไป และการดำเนินการในชั้นนี้เป็นการดำเนินคดีโดยวาจาโดยศาลเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาและซักถามพยานเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงและลงโทษผู้กระทำความผิดต่อไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษามีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานและธรรมชาติของกระบวนการ อย่างไรก็ดีกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษาต่างมีความมุ่งหมายในลักษณะเป็นกระบวนการเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบเพื่ออำนวยความยุติธรรม หากแต่เป็นไปโดยการแยกองค์กรที่ทำหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องออกจากองค์กรพิจารณาวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4.4.2.2 จุดมุ่งหมายในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจรัฐ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้การมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือศาลเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเรียกว่า เป็นการควบคุมตัวระหว่างคดี โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (21) บัญญัติว่า “ควบคุม หมายความถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่าง

สืบสวนและสอบสวน" และมาตรา 2 (22) บัญญัติว่า "ขัง หมายความถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล"

การเอาตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในอำนาจรัฐ หรือควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างคดี มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ กล่าวคือ เพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อย เพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดีอาญาของรัฐ และเพื่อประกันการบังคับโทษ

การควบคุมตัวระหว่างคดี กับการเรียกและการจับ เป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ การเรียก เพราะจำเป็นต้องได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การจับ เพราะกรณีอาจมีความจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลนั้นมาไว้ในอำนาจรัฐ ส่วนการควบคุมหรือขัง เพราะกรณีจำเป็นว่า หากไม่ควบคุมหรือขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าพนักงาน หรือไม่ขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จะไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาได้ และเนื่องจากศาลมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ศาลจะสั่งให้มีการควบคุมตัวระหว่างคดีหรือไม่ จำต้องพิจารณาถึงความจำเป็นหรือจุดมุ่งหมายในการควบคุมตัวระหว่างคดีเป็นสำคัญ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความจำเป็นของการควบคุมตัวระหว่างคดีในชั้นการสอบสวนฟ้องร้อง ซึ่งได้แก่ การขังระหว่างสอบสวน นั้น จะเริ่มมีความจำเป็นก็ต่อเมื่อคดีได้คลี่คลายไปถึงจุดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าคดีมีมูลและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากที่อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อไป[9] กรณีจึงเป็นการขังในระยะเวลาอันสั้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อฟ้องร้องและนำตัวเข้าสู่ชั้นพิจารณาพิพากษาต่อไปเท่านั้น หาใช่การขังเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการกระทำผิดแต่อย่างใด ส่วนในชั้นพิจารณาพิพากษานั้น เนื่องจากเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมาจากในชั้นสอบสวนฟ้องร้องประกอบกับการสืบพยานในชั้นศาล ความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นไปเพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดีอาญาของรัฐและเพื่อประกันการบังคับโทษเท่านั้น

---

[9] คณิต ณ นคร, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7*, น. 57.

4.4.2.3 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2) บัญญัติว่า “ผู้ต้องหา หมายความถึงบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล" ผู้ต้องหาจึงเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา โดยต้องมีกระบวนการสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงและหากพบว่าเป็นผู้กระทำความผิดย่อมต้องมีการฟ้องคดียังชั้นศาลต่อไป

และมาตรา 2 (3) บัญญัติว่า “จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด" การฟ้องบุคคลยังศาลว่าได้กระทำผิดก็เป็นการกล่าวหาเช่นเดียวกัน เพราะแม้ว่าการฟ้องจะหมายถึงคำยืนยันการกระทำความผิดของจำเลย แต่กรณีก็ยังต้องมีการพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อไปอีกว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนั้นหรือไม่

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ต้องหาและจำเลยต่างมีสถานภาพเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเช่นเดียวกัน ดังนั้น หลักการประกันสิทธิและเสรีภาพย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราว สิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย และสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

4.4.2.4 การตรวจสอบและถ่วงดุลความจำเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจรัฐ

(1) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร

การขังระหว่างสอบสวนนั้น มีระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ข้อ 145 กำหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการขออำนาจศาลขังผู้ต้องหา และให้พนักงานสอบสวนหัวหน้าท้องที่นั้นหมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคแปด ได้กำหนดให้ผู้ต้องหามีสิทธิคัดค้านการขอหมายขังได้ด้วย[10]

ส่วนการขังระหว่างพิจารณานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 วรรคสอง บัญญัติว่า “คำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย และผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว” กรณีจึงเป็นการกำหนดให้ศาลต้องให้เหตุผลในคำสั่งโดยชัดเจนและต้องแจ้งให้แก่ผู้ถูกจำกัดสิทธิได้ทราบโดยเร็วด้วย โดยหากศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยก็สามารถอุทธรณ์

---

[10]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่* 4 , น. 45.

คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปได้ตามมาตรา 119 ทวิ อันเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของศาลชั้นต้นโดยศาลอุทธรณ์นั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ทั้งการขังระหว่างสอบสวนและการขังระหว่างพิจารณาต่างก็มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กรเช่นเดียวกัน

(2) การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก

ในชั้นสอบสวนฟ้องร้องนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนจะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วแต่ยังมีความจำเป็นต้องควบคุมผู้นั้นต่อไปอีก พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องยื่นคำร้องขอศาลเพื่อขอให้สั่งขังผู้ต้องหานั้นไว้ในระหว่างการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจำเป็นในการมีตัวผู้ต้องหาไว้ในอำนาจรัฐเพื่อทำการสอบสวนหรือฟ้องร้องตามเหตุของการออกหมายขังตามมาตรา 71 ประกอบมาตรา 66 หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวน ศาลจึงจะสามารถออกหมายขังจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวนได้ ทั้งนี้ ศาลจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการขังจำเลยแต่ละตามความเหมาะสม ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การที่ศาลเป็นผู้ออกหมายขังตามคำร้องของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเช่นนี้ ย่อมเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอกคือศาลนั่นเอง

ส่วนในชั้นพิจารณานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 กำหนดให้คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ โดยศาลต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณากับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลยตามเหตุแห่งการออกหมายขังตามมาตรา 71 ประกอบมาตรา 66 ซึ่งเป็นเหตุเช่นเดียวกันกับในการขังระหว่างสอบสวน ทั้งนี้ จำเลยจะได้รับการปล่อยชั่วคราวเป็นหลักและขังเป็นข้อยกเว้น ซึ่งเป็นหลักเช่นเดียวกับผู้ต้องหา และหากศาลมีคำสั่งให้ขังระหว่างพิจารณา จำเลยก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยศาลจะพิจารณาตามมาตรา 108 และมาตรา 108/1 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับในชั้นสอบสวน ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้น จำเลยก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปได้ตามมาตรา 119 ทวิ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอกคือ ศาล ส่วนการขังระหว่างพิจารณานั้น เนื่องจากศาลเป็นทั้งผู้มีอำนาจสั่งขังระหว่าง

พิจารณาและอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ประกอบกับผู้พิพากษาได้รับความคุ้มครองตามหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการ กรณีจึงไม่มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกแต่อย่างใด

(3) การตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลา

ในชั้นการสอบสวนฟ้องร้องนั้น พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้ในเวลาจำกัด หากยังมีความจำเป็นก็ต้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อขังระหว่างการสอบสวนเป็นรายครั้งไป โดยมาตรา 87 กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมตัวผู้ต้องหา ดังนี้

1. ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี

2. ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การและที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น

3. ในกรณีความผิดอื่น ๆ ควบคุมตัวผู้ถูกจับได้ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83

4. ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้

5. ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

นอกจากนี้ ระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำและอัตราโทษแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกินเจ็ดวัน

2. กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปีหรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน

3. กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน

อย่างไรก็ดี ในระดับความผิดและอัตราโทษนี้ เมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีก ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ

1) พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็น และนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล

2) ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้านและซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 134/1 และผู้ต้องหาร้องขอให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 134/1 วรรคสาม โดยอนุโลม

จะเห็นได้ว่ามาตรา 87 ได้วางหลักประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาไว้สองขั้นตอน กล่าวคือ ตอนที่หนึ่ง จะควบคุมผู้ต้องหาเกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ได้ และตอนที่สอง ความจำเป็นดังกล่าวจะจำเป็นเพียงใดก็ตาม ก็จะควบคุมเกินกว่ากำหนดเวลาดังบัญญัติไว้ไม่ได้[11] กล่าวคือ มีการกำหนดระยะเวลาทั้งระยะเวลาในการควบคุมของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และระยะเวลาในการขังระหว่างสอบสวนของศาลไว้ตามมาตรา 87 นั่นเอง[12]

ดังนั้น การควบคุมที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถทำได้ระหว่างการสอบสวนนั้น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และในการขังระหว่างสอบสวน ศาลมีอำนาจสั่งขังได้เท่าที่จำเป็นตามเหตุการออกหมายขัง และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน

ส่วนการขังระหว่างพิจารณานั้น มาตรา 88 ได้บัญญัติเรื่องการขังระหว่างพิจารณาโดยแยกกรณีผู้เสียหายฟ้องคดี และกรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี กล่าวคือ ถ้าคดีนั้นศาลได้รับเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ศาลสามารถขังหรือปล่อยชั่วคราวจำเลยก็ได้ ทั้ง 2 กรณี คือ คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว และคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาคดีของศาลนี้ไม่มีการตรวจสอบความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาตามกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา ดังนั้น หากจำเลยไม่ได้รับการปล่อย

---

[11]คำพิพากษาฎีกาที่ 326-327/2505 (ป) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วางหลักเป็นประกันเสรีภาพของประชาชนไว้ 2 ตอน ตอนต้นว่า จะควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ได้ ตอนที่สองว่า ความจำเป็นดังกล่าวจะจำเป็นเพียงใดก็ตามก็จะควบคุมเกินกว่ากำหนดเวลาดังบัญญัติไว้ไม่ได้

[12]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4* , น. 115.

ชั่วคราวระหว่างพิจารณา บางคดีจำเลยอาจถูกคุมขังเป็นปีก็ได้[13] หรือศาลอาจสั่งขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาตลอดไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ได้[14]

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลา โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 กำหนดระยะเวลาในการขังระหว่างสอบสวนไว้ตามความผิดและอัตราโทษ แต่เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลแล้วกลับไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด[15] การขังระหว่างพิจารณาจึงไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลา

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการขังระหว่างสอบสวนกับการขังระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว พบว่า แม้หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษาและจุดมุ่งหมายในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจรัฐจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา แต่หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยนั้น มีความเหมือนกันเนื่องจากทั้งผู้ต้องหาและจำเลยต่างมีสถานภาพเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเช่นกัน ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างสอบสวนและการขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยได้รับการคุ้มครองตามหลักประกันสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลความจำเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจรัฐของการขังระหว่างสอบสวนและการขังระหว่างพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุล 3 ลักษณะ คือ การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก และการตรวจสอบถ่วงดุลตาม

---

[13]ณรงค์ ใจหาญ, “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ดุลยภาพระหว่างสิทธิมนุษยชนกับประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม (ตอนที่ 1)”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2546), น. 43.

[14]คนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น. 255.

[15]สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4*, น. 115.

กำหนดระยะเวลา สำหรับการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาของการขังระหว่างสอบสวนนั้น มีข้อพิจารณาดังนี้

1. การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดระยะเวลาสูงสุดในการขังระหว่างสอบสวนไว้ตามความผิดและอัตราโทษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามมาตรา 87 หากศาลไม่อนุญาตให้ขังระหว่างสอบสวนหรือได้สั่งขังระหว่างสอบสวนครบกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่จะสามารถขังระหว่างสอบสวนแล้ว ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป แม้ว่าการสอบสวนจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตาม

2. กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกสูงซึ่งศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวน 1 ครั้ง (12 วัน) หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการร้องขอให้มีการขังระหว่างสอบสวนต่อ ศาลก็ต้องพิจารณาคำร้องนั้นโดยพิจารณาถึงเหตุความจำเป็นของการขังระหว่างสอบสวนทุกครั้งโดยอัตโนมัติเพื่อประกอบการมีคำสั่ง กรณีจึงเป็นการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 กำหนดระยะเวลาเป็นระยะเพื่อให้ศาลเข้าไปตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างสอบสวนได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อครบกำหนดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนในแต่ละครั้งนั้น ๆ

3. การใช้ดุลพินิจของศาลเพื่อประกอบการมีคำสั่งขังระหว่างสอบสวนนั้น ศาลสามารถทำการไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้ต้องหา และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจได้อย่างรอบด้านด้วย กล่าวคือ มาตรา 87 วรรคสามกำหนดให้ศาลต้องสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านคำร้องของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลก็ได้ และมาตรา 87 วรรคเจ็ดกำหนดให้กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หากศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้แสดงถึงเหตุจำเป็น และนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล นอกจากนี้กรณีที่มีการไต่สวนตามมาตรา 87 วรรคสามและวรรคเจ็ด มาตรา 87 วรรคแปด ยังกำหนดให้ผู้ต้องหามีสิทธิในการแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้านและซักถามพยานได้ด้วย หากผู้ต้องหาไม่มีทนายความและผู้ต้องหาร้องขอ ศาลต้องแต่งตั้งทนายความให้

ส่วนการขังระหว่างพิจารณานั้น พบเฉพาะการตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พบการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด โดยเมื่อศาลออกหมายขังจำเลยระหว่างพิจารณาแล้ว หมายขังสามารถใช้ได้จนกว่าศาลจะเพิกถอนหมายขังโดยการออกหมายปล่อยหรือออกหมายจำคุกแทน โดยศาลจะออกหมายปล่อยจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาได้ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 72 (1) ดังนั้น การขังระหว่างพิจารณาในชั้นนี้มีเพียงดุลพินิจของศาลผู้ออกหมายขังเองว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ดังนั้น หากจำเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ศาลอาจสั่งขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาตลอดไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ได้ แม้ว่าการพิจารณาคดีของศาลจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม

4.4.3 ข้อพิจารณาตามหลักความได้สัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้”

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงว่ารัฐธรรมนูญได้นำหลักความได้สัดส่วนซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐมาบัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปในรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดการใช้อำนาจของรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอำเภอใจ ดังนั้นย่อมต้องนำหลักสัดส่วนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการกระทำของรัฐที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนหรือไม่

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณานั้น นอกจากจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณาเพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา และจำเลยสามารถถูกขังระหว่างพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลแล้ว ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาของจำเลยแต่ละคน แม้ว่าจะถูกฟ้องตามฐานความผิดที่มีความร้ายแรงหรืออัตราโทษจำคุกแตกต่างกันเพียงใด ก็สามารถถูกขังระหว่างพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลเช่นเดียวกัน

โดยไม่มีการพิจารณาถึงสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องและไม่พบว่ามีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด

กรณีจึงมีข้อพิจารณาว่า เมื่อการขังระหว่างพิจารณาเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา คือ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของจำเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันการมีตัวจำเลยในชั้นพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ และเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่าที่มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณา ดังนั้น สำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาตามเหตุของการขังระหว่างพิจารณาแล้ว จึงควรต้องพิจารณาต่อไปว่าระยะเวลาขังระหว่างพิจารณานั้นมีความสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ หลักความเหมาะสม หลักความจำเป็น และหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ หรือไม่ด้วย โดยพิจารณาชั่งน้ำหนักประโยชน์ที่รัฐจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไปเนื่องมาจากการขังระหว่างพิจารณา

ทั้งนี้ อาจพิจารณาเปรียบเทียบได้กับการขังระหว่างสอบสวน ซึ่งกำหนดสัดส่วนของระยะเวลาของการขังระหว่างสอบสวนตามระดับของอัตราโทษของความผิดอาญาที่กระทำ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ 1) กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกินเจ็ดวัน 2) กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน และ 3) กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน

จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยพื้นฐานของจุดมุ่งหมายของการขังระหว่างสอบสวนที่เป็นไปเพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้ โดยเรียบร้อยประกอบกับความยุ่งยากซับซ้อนของการสอบสวน กล่าวคือ กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงย่อมมีความยุ่งยากซับซ้อนของการสอบสวนมากกว่ากรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษต่ำกว่า ดังนั้น เมื่อมีการขังระหว่างสอบสวน ระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนของกรณี

ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงย่อมมีระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนยาวนานกว่ากรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษต่ำกว่านั่นเอง

สำหรับระยะเวลาขังระหว่างพิจารณานั้น เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับหลักการของสัดส่วนระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงเป็นการพิจารณาสัดส่วนโดยชั่งน้ำหนักระหว่างระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาที่มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่จะต้องสูญเสียสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายและการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทาง กับอัตราโทษจำคุกของความผิดอาญาที่มีการฟ้องร้อง โดยสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาเป็นการกำหนดโดยพื้นฐานของจุดมุ่งหมายของการขังระหว่างพิจารณาที่เป็นไปประกันการมีตัวของจำเลยประกอบกับความยุ่งยากซับซ้อนในการพิจารณาพิพากษา ดังนั้นหากกรณีมีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณา จำเลยที่ถูกฟ้องร้องว่ากระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกต่างกัน ย่อมควรต้องถูกขังระหว่างพิจารณาในระยะเวลาที่ต่างกันไปด้วย กล่าวคือ หากกรณีจำเลยถูกฟ้องร้องว่ากระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกสูงกว่า ย่อมควรมีสัดส่วนระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณาในระยะเวลาที่ยาวนานกว่ากรณีที่จำเลยถูกฟ้องร้องว่ากระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกต่ำกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาควรมีสัดส่วนตามอัตราโทษจำคุกของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องหรือตามระดับความร้ายแรงของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องนั่นเอง

นอกจากนี้ เนื่องจากการขังระหว่างพิจารณาต้องคำนึงถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วย ดังนั้น การจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาตามฐานความผิดนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงเพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่จำเลยว่าจะต้องอยู่ในอำนาจรัฐในระยะเวลาที่ได้สัดส่วนและมีจำกัดระยะเวลาสูงสุด โดยจะไม่ถูกขังระหว่างพิจารณาอย่างยาวนานโดยไม่มีกำหนดอันเสมือนเป็นการถูกลงโทษจำคุกไปแล้วนั่นเอง

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาแล้ว ไม่พบว่ามีการกำหนดสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง และไม่พบว่ามีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

เมื่อเกิดการกระทำความผิดอาญา เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นเครื่องมือของรัฐในการดำเนินการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ขาดข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น และหากมีการชี้ขาดว่าได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดต่อไปและโดยที่การชี้ขาดข้อเท็จจริงในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนฟ้องหรือขั้นตอนการสอบสวนฟ้องร้อง หรือขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาอาจมีการดำเนินการที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาได้ การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ จึงต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำผิด

การควบคุมตัวระหว่างคดี คือ การจำกัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของผู้ถูกกล่าวหา การดำเนินคดีอาญาในปัจจุบันแม้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาจะเป็นประธานในคดี แต่การใช้มาตรการบังคับของรัฐกับผู้ถูกกล่าวหาก็ยังมีความจำเป็น การควบคุมตัวระหว่างคดีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ กล่าวคือ เพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อย เพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย และเพื่อประกันการบังคับโทษ นอกจากนี้ การควบคุมตัวระหว่างคดีเป็นเรื่องของข้อยกเว้น กล่าวคือ โดยหลักจะต้องปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยเสมอ จะควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น คือการควบคุมตัวระหว่างคดีต้องเป็นการเอาตัวไว้เพราะความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวระหว่างคดีดังกล่าวข้างต้นอย่างแท้จริง หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวระหว่างคดีต้องปล่อยชั่วคราวเสมอ อันเป็นการรักษาสมดุลระหว่างอำนาจรัฐในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่บุคคลจะต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนเสมอว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำผิดและต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

เนื่องจากการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐโดยการควบคุมตัวระหว่างคดีนั้นเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างแท้จริง การตรวจสอบถ่วงดุลการการควบคุมตัวระหว่างคดีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์กร (Responsibility) และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) และสามารถตรวจสอบได้การใช้อำนาจได้ (Accountability) ผ่านกลไกการตรวจสอบทางกฎหมายต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และองค์กรศาลซึ่งมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการควบคุมตัวระหว่างคดี และต้องมุ่งคุ้มครองให้การควบคุมตัวระหว่างคดีนั้นเป็นไปโดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นสำคัญ

การขังระหว่างพิจารณา คือ การควบคุมตัวระหว่างคดีโดยการจำกัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของจำเลย โดยเป็นการดำเนินกระบวนการดำเนินคดีในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (Trial stage) กล่าวคือได้ผ่านกระบวนการดำเนินคดีในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง (pre – trial stage) และมีการนำตัวจำเลยมาต่อศาลและเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นแล้ว การขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นใช้ดุลพินิจของศาลพิจารณาความจำเป็นในการขังจำเลยในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น โดยศาลซึ่งมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา ต้องมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยโดยการพิจารณาเหตุจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาอย่างจริงจังและต้องมุ่งให้จำเลยได้รับหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาด้วย อันได้แก่ หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว และหลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ การขังระหว่างพิจารณาของศาลจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปอย่างแท้จริง โดยต้องคำนึงถึงหลักความเป็นอิสระของตุลาการ (Independent of Judge) อันเป็นขอบเขตในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายตุลาการด้วย นอกจากนี้การขังระหว่างพิจารณาดังกล่าวต้องไปเป็นโดยสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนอันเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่จะต้องสูญเสียไปในระหว่างที่ถูกขังระหว่างพิจารณากับประโยชน์ของรัฐในการขังระหว่างพิจารณา

5.1.1 การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในประเทศญี่ปุ่น

การขังระหว่างพิจารณาของประเทศญี่ปุ่นนั้น ศาลจะสั่งขังระหว่างพิจารณาได้ต่อเมื่อมีเหตุของการขังระหว่างพิจารณาตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ (1) จำเลยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน (2) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะซ่อนเร้นหรือทำลายพยานหลักฐาน หรือ (3) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะหลบหนี เท่านั้น หากไม่มีเหตุของการขังระหว่างพิจารณา ศาลจะต้องปล่อยตัวจำเลยในทันที

สำหรับการปล่อยชั่วคราวนั้น การได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวเป็นสิทธิของจำเลยและศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต กล่าวคือ เมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จำเลย ญาติพี่น้อง หรือทนายความของจำเลย มีสิทธิขอประกันตัวจำเลยได้ ตามมาตรา 88 โดยเมื่อมีคำขอให้ปล่อยชั่วคราว ศาลจะต้องพิจารณาอนุญาตเป็นหลัก เว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 89 กล่าวคือ (1) เมื่อจำเลยถูกฟ้องในความผิดที่มีโทษขั้นสูงให้ประหารชีวิต หรือจำคุกขั้นต่ำเกินกว่าหนึ่งปี (2) เมื่อจำเลยเคยรับโทษถึงที่สุดในความผิดให้ประหารชีวิต หรือได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษจำคุกเกินกว่าสิบปี (3) เมื่อจำเลยเป็นผู้กระทำผิดติดนิสัย เคยถูกลงโทษจำคุกเกินกว่าสามปี (4) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะทำลายพยานหลักฐาน (5) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะทำร้ายร่างกาย หรือทำอันตรายทรัพย์สินของผู้เสียหาย หรือบุคคลอื่นซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นผู้รู้เห็นในการพิจารณาคดีนั้น หรือญาติของเขา หรือจำเลยอาจกระทำการข่มขู่บุคคลนั้น หรือ (6) เมื่อไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ของจำเลย อย่างไรก็ดี แม้เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 89 แล้ว ตามมาตรา 90 ศาลอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแก่จำเลยได้โดยใช้ดุลพินิจของศาลเมื่อมีเหตุที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่า ศาลมีบทบาทในการปล่อยชั่วคราวโดยดุลพินิจของศาลด้วยแม้เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่สามารถขังระหว่างพิจารณาได้ก็ตามเมื่อศาลเห็นว่ามีเหตุที่เหมาะสม

เมื่อกรณีมีการสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้ว มีการกำหนดระยะเวลาให้ศาลต้องตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 60 วรรคสอง กล่าวคือ ศาลสามารถขังจำเลยระหว่างพิจารณาได้เป็นเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่พนักงานอัยการฟ้องคดี ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องขังระหว่างพิจารณานานกว่านั้น สามารถขอขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาได้ต่อไปอีก 1 เดือน โดยต้องมีเหตุผลโดยชัดแจ้งในการขอขยายระยะเวลานี้ อย่างไรก็ดี สามารถขยายระยะเวลาได้ออกไปเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ดังนั้น ระยะเวลาสูงสุดในการขังระหว่างพิจารณาจึงเป็น 3 เดือน นับแต่วันที่พนักงานอัยการฟ้องคดี โดยการกำหนดระยะเวลาการขังระหว่าง

พิจารณานี้เป็นไปเพื่อให้การพิจารณาคดีเสร็จในเวลาอันรวดเร็วในกรณีที่มีการขังจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดี อันเป็นการคุ้มครองจำเลยตามสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า การขังระหว่างพิจารณานี้แม้จะไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก หากแต่มีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณา อันเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณาของศาล

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาสูงสุดแล้วและกรณียังมีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาต่อไปอีก สามารถขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาต่อไปครั้งละ 1 เดือนได้ในกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 60 วรรคสอง คือเป็นกรณีที่สามารถขยายระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณาได้มากกว่า 1 ครั้ง ได้แก่ กรณีตามมาตรา 89 (1) เมื่อจำเลยถูกฟ้องในความผิดที่มีโทษขั้นสูงให้ประหารชีวิต หรือจำคุกขั้นต่ำเกินกว่าหนึ่งปี (3) เมื่อจำเลยเป็นผู้กระทำผิดติดนิสัย เคยถูกลงโทษจำคุกเกินกว่าสิบปี (4) เมื่อมีเหตุผลเพียงพออันสมควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะทำลายพยานหลักฐาน หรือ (6) เมื่อไม่รู้ชื่อหรือที่อยู่ของจำเลย จะเห็นได้ว่าสำหรับกรณีขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณามากกว่า 1 ครั้งนี้ เป็นการกำหนดให้ศาลต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาว่ายังมีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาต่อไปหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาต่อ ศาลสามารถสั่งขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาได้เฉพาะกรณีตามข้อยกเว้นที่กำหนดและขยายระยะเวลาได้เท่าที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน โดยหากไม่มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาต่ออีก ต้องสั่งปล่อยตัวจำเลยทันที และสำหรับกรณีที่ไม่สามารถขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณามากกว่า 1 ครั้งได้นั้น แม้มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาต่อก็ตาม ศาลก็ต้องสั่งปล่อยตัวจำเลยทันทีเช่นกัน

กรณีอยู่ระหว่างการขังระหว่างพิจารณาหรือการขังระหว่างพิจารณาต่อ หากความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาหมดไป ศาลสามารถสั่งยกเลิกการขังระหว่างพิจารณาได้ตามมาตรา 87 กล่าวคือ เมื่อได้รับคำร้องขอของพนักงานอัยการ จำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา ทนายความของจำเลย ผู้แทนโดยชอบธรรม สามี ภรรยา ทายาท พี่น้อง หรือโดยดุลพินิจของศาลเอง และแม้ว่ากรณียังมีความจำเป็นที่จะต้องขังระหว่างพิจารณา แต่การขังระหว่างพิจารณานั้นต้องไม่เป็นการขังเกินกว่าระยะเวลาอันสมควรด้วย ดังนั้น เมื่อมีกรณีการขังเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร ตามมาตรา 91 ศาลโดยคำร้องของบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 88 หรือโดยดุลพินิจของศาลเอง ต้องยกเลิกการขังระหว่างพิจารณานั้นหรืออนุญาตให้มีการประกันตัว โดยหลักการเรื่องการขังเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร (Unduly Prolonged) นี้

เป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี โดยต้องพิจารณาองค์ประกอบในเชิงภาวะวิสัยเป็นสำคัญในการพิจารณา อย่างไรก็ดี การยกเลิกการขังระหว่างพิจารณาต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการด้วย เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรือเป็นการร้องขอของพนักงานอัยการเอง จะเห็นได้ว่า เมื่อความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาหมดไปหรือในกรณีที่มีการขังระหว่างพิจารณาเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร นอกจากศาลจะพิจารณายกเลิกการขังระหว่างพิจารณาเมื่อได้รับคำร้องจากผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องแล้ว ศาลยังมีบทบาทในเชิงรุกที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการยกเลิกการขังระหว่างการพิจารณาหรือปล่อยชั่วคราวได้เองด้วย

5.1.2 การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในประเทศฝรั่งเศส

หลักการของการขังระหว่างพิจารณานั้น เมื่อมีการสอบสวนและฟ้องคดีมายังศาลแล้ว และผู้พิพากษาสอบสวนยังไม่ปล่อยตัว ก็เป็นอำนาจของศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้พิจารณาปล่อยตัว โดยการพิจารณาปล่อยตัวจำเลยของศาลนั้น ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับในชั้นสอบสวน และในทุกศาลการพิจารณาคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการ จำเลย หรือทนายความด้วย ตามมาตรา 143 ประกอบมาตรา 148-2 และการยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวสามารถยื่นได้เสมอโดยผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามมาตรา 141-1 ประกอบมาตรา 148-1 นอกจากนี้ ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณาของศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี มาตรา 148-1 กำหนดให้นำเรื่องการขังระหว่างสอบสวนมาใช้ด้วย ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

สำหรับเรื่องการปล่อยชั่วคราวนั้น ผู้ต้องหาได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และยังคงมีเสรีภาพ กล่าวคือ ตามมาตรา 137 จะต้องปล่อยผู้ต้องหาเป็นอิสระ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเพื่อการสอบสวนหรือเพื่อเป็นวิธีการเพื่อการรักษาความปลอดภัย สามารถสั่งให้มีการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขได้ อย่างไรก็ดี ถ้าการปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้และเป็นกรณียกเว้น จึงจะสั่งขังผู้ต้องหาได้

เงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ได้แก่ ผู้ต้องหาจะต้องถูกกล่าวหาในความผิดที่มีโทษจำคุกมัธยโทษหรือสูงกว่า และจะต้องมีความจำเป็นเพื่อการสอบสวนหรือเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย โดยผู้พิพากษาจะต้องออกเป็นคำสั่งที่กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ต้องหาจะต้องปฏิบัติระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว นอกจากการกำหนดเงื่อนไขแล้ว บางกรณีผู้พิพากษาอาจสั่งให้ผู้ต้องหาจัดหาหลักประกันด้วยก็ได้

สำหรับการร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวนั้น (1) ในทุกคดี การปล่อยชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขนั้น ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งปล่อยชั่วคราวได้หลังจากที่ได้รับฟังความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ต้องหาต้องมาปรากฏตัวในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณาและแจ้งให้ผู้พิพากษาสอบสวนทราบถึงการเคลื่อนไหวของเขาเสมอ ตามมาตรา 147 วรรคหนึ่ง (2) พนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวได้เสมอ ตามมาตรา 147 วรรคสอง และ (3) ผู้ต้องหาหรือทนายความสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวได้เสมอ ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 147 ในกรณีไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหามีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลสอบสวนขั้นอุทธรณ์ ซึ่งต้องวินิจฉัยภายใน 20 วันมิฉะนั้นแล้วจะต้องปล่อยผู้ต้องหาทันทีตามมาตรา 148

การขังนั้นศาลเป็นผู้พิจารณาเหตุในการขัง โดยต้องออกเป็นหมายขังเพื่อบังคับแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเหตุของการขังนั้น ต้องพิจารณาจากอัตราโทษที่ศาลสามารถสั่งขังได้ประกอบกับเหตุของการขังระหว่างสอบสวน กล่าวคือ ตามมาตรา 143-1 ความผิดอุกฤษโทษผู้พิพากษาสอบสวนสามารถสั่งขังได้เสมอ ความผิดมัธยโทษ ศาลจะสั่งขังได้ก็ต่อเมื่อความผิดนั้นมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ส่วนความผิดลหุโทษนั้น ศาลไม่อาจสั่งขังได้เลย ส่วนเหตุของการขังระหว่างสอบสวนตามมาตรา 144 นั้น ศาลจะสั่งขังหรือสั่งขังต่อได้ต่อเมื่อการขังระหว่างพิจารณาเป็นมาตรการเดียวที่จะสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ได้ คือ (1) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของหลักฐานหรือร่องรอยต่าง ๆ ในคดี หรือเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาข่มขู่พยาน ผู้เสียหาย และครอบครัว รวมถึงเพื่อป้องกันการหารือระหว่างผู้ต้องหากับผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่น ๆ เพื่อบิดเบือนคำให้การ (2) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกสอบสวนเอง หรือเพื่อเป็นหลักประกันในการนำตัวผู้ต้องหาฟ้องร้องต่อศาล หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดขึ้นใหม่ หรือ (3) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยหยุดการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในระดับที่รุนแรงและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของความผิดหรือความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นต้องขังระหว่างสอบสวนศาลต้องสั่งปล่อยชั่วคราวเสมอ

เมื่อกรณีมีการสั่งขังระหว่างสอบสวนแล้ว การขังจะถูกตรวจสอบตามกำหนดระยะเวลา โดยมีหลักการสำคัญตามมาตรา 144-1 คือ ระยะเวลาขังต้องไม่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร เมื่อพิจารณาประกอบกับความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและความซับซ้อนของการสืบสวนและการสอบสวนซึ่งจำเป็นเพื่อค้นหาความจริง และผู้พิพากษาสอบสวนต้องสั่งให้ปล่อยผู้ต้องหาทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเหตุการขังระหว่าง

สอบสวนตามมาตรา 144 และตามมาตรา 144-1 นี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดหลักการทั่วไปของระยะเวลาขังอย่างชัดเจนว่าต้องไม่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร และหากมีกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นของการขังอีกต่อไป ศาลต้องสั่งให้ปล่อยผู้ต้องหาทันที

นอกจากหลักการทั่วไปดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการกำหนดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนด้วย กล่าวคือ ระยะเวลาที่ผู้พิพากษาสามารถสั่งขังได้นั้น เป็นไปตามประเภทความผิดโดยมีระยะเวลาสูงสุดจำกัดในการขังระหว่างพิจารณาตามประเภทของความผิด

สำหรับความผิดมัธยโทษนั้น ตามมาตรา 145-1 กำหนดว่า ระยะเวลาการขังต้องไม่เกิน 4 เดือน ถ้าผู้ถูกต้องหาไม่เคยถูกลงโทษว่ากระทำความผิดอุกฤษโทษหรือมัธยโทษมากกว่า 1 ปี มาก่อน และความผิดที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำในครั้งนี้มีโทษจำคุกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี และในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้พิพากษาสามารถสั่งขยายระยะเวลาขังได้อีกไม่เกิน 4 เดือน โดยคำสั่งศาลซึ่งต้องอธิบายและให้เหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและต้องจัดให้มีการชี้แจงของผู้ต้องหาโดยมีทนายความของผู้ต้องหาร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ ศาลสามารถสั่งขยายระยะเวลาได้อีกโดยใช้กระบวนการเดิม แต่ระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณาทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม ระยะเวลานี้สามารถขยายออกไปได้อีกเป็น 2 ปี เมื่อเป็นกรณีที่การกระทำความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร หรือเมื่อบุคคลนั้นถูกสอบสวนในความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การสมคบการกระทำความผิดอาญา การค้ามนุษย์ การกรรโชกทรัพย์ หรือความผิดอุกฤษโทษที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม และเมื่อความผิดนั้นมีโทษจำคุก 10 ปี และในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างยิ่ง เมื่อยังมีความจำเป็นต้องทำการสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน และการปล่อยตัวผู้ต้องหาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ 2 ปี ได้ออกไปอีก 4 เดือน โดยผู้พิพากษาสอบสวนต้องให้เหตุผลและมีการไต่สวนด้วย

ส่วนความผิดอุกฤษโทษนั้น ตามมาตรา 145-2 กำหนดว่า ห้ามมิให้สั่งขังผู้ต้องหาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี ผู้พิพากษาสามารถสั่งให้ขยายระยะเวลาต่อได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยคำสั่งศาลซึ่งต้องให้เหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและต้องจัดให้มีการชี้แจงของผู้ต้องหาและโดยมีทนายความของผู้ต้องหาร่วมอยู่ด้วย คำสั่งขยายนี้สามารถสั่งขยายต่อได้อีกด้วยกระบวนการพิจารณาเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาไม่สามารถถูกขังได้เกินกว่า 2 ปี เมื่อความผิดนั้นมีโทษต่ำกว่า 20 ปี และไม่สามารถถูกขังได้เกินกว่า 3 ปี ในกรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจขยายระยะเวลาขังเป็น 3 และ 4 ปี ในกรณีที่การกระทำความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร และ 4 ปี ในกรณีที่บุคคลนั้นถูกสอบสวนเกี่ยวกับความผิดอุกฤษโทษใน Books II and IV ของประมวลกฎหมายอาญา การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การกรรโชกทรัพย์ หรือความผิดอุกฤษโทษที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม และในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างยิ่ง เมื่อยังมีความจำเป็นต้องทำการสอบสวนโดยผู้พิพากษาสอบสวน และการปล่อยตัวผู้ต้องหาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ผู้พิพากษาสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ออกไปได้อีก 4 เดือน โดยผู้พิพากษาสอบสวนชั้นอุทธรณ์ต้องให้เหตุผลและมีการไต่สวนด้วย และคำสั่งขยายนี้สามารถขยายต่อได้อีกครั้งหนึ่งด้วยกระบวนการพิจารณาเดียวกัน

ทั้งนี้ มาตรา 145-3 กำหนดว่า เมื่อขังเกินกว่า 1 ปี ในความผิดอุกฤษโทษ หรือเกินกว่า 8 เดือน ในความผิดมัธยโทษ การขยายระยะเวลาขังหรือยกคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจะต้องมีเหตุผลพิเศษเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคาดหมายระยะเวลาสิ้นสุดของกระบวนพิจารณาได้ด้วย

จะเห็นได้ว่า การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน โดยแบ่งตามระดับของความผิด และเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างสอบสวนโดยกำหนดระยะเวลาให้ศาลต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างสอบสวนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำหรับในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาขังต่อได้ ก็เป็นการกำหนดให้ศาลต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาว่ายังมีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาต่อไปหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องขังต่ออีกจึงจะสั่งขยายระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนได้และขยายระยะเวลาได้เท่าที่กฎหมายกำหนด โดยคำสั่งศาลในการสั่งขังนั้นต้องอธิบายและให้เหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบเสมอและต้องรับฟังคำชี้แจงของผู้ต้องหาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มีความจำเป็นต้องขังต่ออีก ต้องสั่งปล่อยตัวจำเลยทันที ส่วนกรณีที่ไม่สามารถขยายระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนได้ แม้มีความจำเป็นต้องขังระหว่างสอบสวนต่อก็ตาม ศาลก็ต้องสั่งปล่อยตัวจำเลยทันที

5.1.3 การขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 บัญญัติว่า “คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้”

เหตุของการขังระหว่างพิจารณาตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 66 กล่าวคือ ศาลจะออกหมายขังจำเลยไว้ในระหว่างพิจารณาได้ (1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี (2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น โดยถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณา ต้องสั่งปล่อยชั่วคราว

เมื่อมีการสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้ว ไม่มีการจำกัดระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด โดยศาลสามารถขังระหว่างพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลและการออกหมายปล่อยกรณีมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณานั้น กระทำได้โดยการปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 72 (1)

สำหรับผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (3) กำหนดให้คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวนั้นย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น ส่วนหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราว เนื่องจากการปล่อยชั่วคราวเป็นอำนาจของศาลในการพิจารณาตามสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างไรก็ดีการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีกรอบในการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมาตรา 108 และมาตรา 108/1 หากศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปได้ตามมาตรา 119 ทวิ ได้ นอกจากนี้จำเลยก็สามารถยื่นคำร้องการร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้อีกตลอดระยะเวลาที่ถูกขังระหว่างพิจารณาโดยไม่มีข้อจำกัดอีกด้วย

การขังระหว่างพิจารณาในประเทศไทยมีข้อพิจารณาดังนี้

(1) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ถูกขังระหว่างพิจารณา

องค์กรในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ของรัฐไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ไม่มีการแยกแยะความเป็นเหตุหลักและเหตุรองของการขังระหว่างพิจารณา โดยจะพิจารณาเหตุแห่งความร้ายแรงของความผิดซึ่งเป็นเหตุรองที่สามารถปล่อยชั่วคราวได้ในลักษณะเดียวกันกับเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น ซึ่งเป็นเหตุหลักที่ไม่สามารถปล่อยชั่วคราวได้ จึงเกิดกรณีของการขังระหว่างพิจารณาโดยไม่จำเป็นอยู่ด้วย ซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ มักมีความเข้าใจว่าเมื่อศาลมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88 แล้ว ต้องเอาตัวจำเลยไว้ในระหว่างพิจารณาจนกว่าพิจารณาพิพากษาเสมอ กล่าวคือ เมื่อมีการขังระหว่างพิจารณาแล้ว ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในช่วงระยะเวลาระหว่างระยะเวลาที่มีการขังระหว่างพิจารณานั้นอีกต่อไปนั่นเอง

กรณีจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการขังระหว่างพิจารณาไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐอย่างจริงจัง ดังนั้นภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาอันเป็นภารกิจของศาลจึงควรเป็นเรื่องที่ควรมีการพิจารณา ส่วนการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนั้น แม้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ แต่ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญลำดับรองจากการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณา เนื่องจากหากมีการขังระหว่างพิจารณาในกรณีไม่มีความจำเป็นแล้ว แม้มีการพิจารณาคดีด้วยความต่อเนื่องรวดเร็วอย่างไร ย่อมต้องเป็นกรณีที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจำเลยอยู่นั่นเอง

(2) ข้อพิจารณาเปรียบเทียบระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของการขังระหว่างสอบสวนกับการขังระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลความจำเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจรัฐของการขังระหว่างสอบสวนและการขังระหว่างพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุล 3 ลักษณะ คือ การตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กร การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก และการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาของการขังระหว่างสอบสวนนั้น การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญากำหนดระยะเวลาสูงสุดในการขังระหว่างสอบสวนไว้ตามความผิดและอัตราโทษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามมาตรา 87 หากศาลไม่อนุญาตให้ขังระหว่างสอบสวนหรือได้สั่งขังระหว่างสอบสวนครบกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่จะสามารถขังระหว่างสอบสวนแล้ว ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป แม้ว่าการสอบสวนจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตาม นอกจากนี้ยังกำหนดระยะเวลาเป็นระยะเพื่อให้ศาลเข้าไปตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างสอบสวนได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อครบกำหนดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนในแต่ละครั้งนั้น ๆ อีกทั้งการใช้ดุลพินิจของศาลเพื่อประกอบการมีคำสั่งขังระหว่างสอบสวนนั้น ศาลสามารถทำการไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้ต้องหา และพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจได้อย่างรอบด้านด้วย

ส่วนการขังระหว่างพิจารณานั้น พบเฉพาะการตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พบการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลา กล่าวคือ เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลแล้วไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด ดังนั้น หากจำเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ศาลอาจสั่งขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาตลอดไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ได้

(3) ข้อพิจารณาตามหลักความได้สัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาแล้ว ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาของจำเลยแต่ละคน แม้ว่าจะถูกฟ้องตามฐานความผิดที่มีความร้ายแรงหรืออัตราโทษจำคุกแตกต่างกันเพียงใด ก็สามารถถูกขังระหว่างพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง และไม่พบว่ามีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการขังระหว่างสอบสวน คือ การขังระหว่างสอบสวนมีการกำหนดสัดส่วนของระยะเวลาของการขังระหว่างสอบสวนตามระดับของอัตราโทษของความผิดอาญาที่กระทำ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยพื้นฐานของจุดมุ่งหมายของการขังระหว่างสอบสวนที่เป็นไปเพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อยประกอบกับความยุ่งยากซับซ้อนของการสอบสวน กล่าวคือ กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงย่อมมีความยุ่งยากซับซ้อนของการสอบสวนมากกว่ากรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษต่ำกว่า ดังนั้น เมื่อมีการขังระหว่างสอบสวน

ระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนของกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงย่อมมีระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนยาวนานกว่ากรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษต่ำกว่านั่นเอง

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 **ควรมีการเพิ่มบทบาทเชิงรุกของศาลให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเพิ่มมากขึ้น**

แม้ว่าปัจจุบันศาลยุติธรรมได้ปรับปรุงระบบการพิจารณาคดีโดยมีการนำระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องเข้ามาใช้ ซึ่งช่วยทำให้ระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดช่องทางพิเศษสำหรับคดีที่จำเลยต้องขังระหว่างพิจารณาไว้ด้วย ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ศาลเห็นความสำคัญและมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักประกันสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการขังระหว่างพิจารณาไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการขังระหว่างพิจารณาโดยไม่จำเป็น ทั้งที่ภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเป็นภารกิจของศาล อีกทั้งศาลเป็นองค์กรสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมที่จะสามารถให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ ดังนั้น จึงควรมีการเพิ่มบทบาทเชิงรุกของศาลให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ

(1) บทบาทของศาลก่อนมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณา ควรมีการพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาโดยการแยกแยะความเป็นเหตุหลักและเหตุรองของการขังระหว่างพิจารณา กล่าวคือ การพิจารณาความจำเป็นในการสั่งขังระหว่างพิจารณาของศาลเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในลำดับแรกที่ต้องพิจารณา เนื่องจากหากกรณีไม่มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาแล้ว ศาลต้องมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวจำเลยเสมอ โดยอาจมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาควรพิจารณาจากลักษณะของเหตุแห่งการออกหมายขังซึ่งแบ่งออกเป็น “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” และ “เหตุที่เป็นเหตุรอง” “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” คือ เหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่ออันตรายประการอื่น ส่วน “เหตุที่เป็นเหตุรอง” คือ เหตุแห่งความร้ายแรงของความผิด ดังนั้น เมื่อกรณีใดมี “เหตุที่เป็นเหตุหลัก” แล้ว การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐย่อมมีความจำเป็นเสมอ และการปล่อยชั่วคราวย่อมกระทำไม่ได้ เพราะจะทำให้การดำเนินคดีไม่อาจเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและขัดขวางต่อการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดี ส่วน

กรณีใดมี “เหตุที่เป็นเหตุรอง” กรณีนั้นย่อมไม่แน่นอนเสมอไปว่าการดำเนินคดีจะไม่อาจเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและจะขัดขวางต่อการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินคดี และอาจมีการปล่อยชั่วคราวได้ ทั้งนี้ หากศาลได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐอย่างจริงจังแล้ว ก็จะเป็นการเข้าคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นแรกก่อนที่จะมีการขังระหว่างพิจารณา และจะทำให้บทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(2) บทบาทของศาลเมื่อมีคำสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้ว ควรมีการมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในช่วงระยะเวลาระหว่างที่มีการขังระหว่างพิจารณาด้วย เพื่อให้มีความจำเป็นของการขังตลอดระยะเวลาที่มีการขังระหว่างพิจารณา กล่าวคือ แม้กรณีมีการสั่งขังระหว่างพิจารณาแล้ว หากแต่ต่อมาศาลพบว่าไม่มีความจำเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาอีกต่อไป ศาลย่อมต้องปล่อยตัวจำเลยทันที โดยระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาจะมีระยะเวลาเพียงเท่าที่มีความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาเท่านั้น หากกรณีไม่มีความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาอีกต่อไป ศาลควรย่อมต้องเข้าคุ้มครองสิทธิของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณานั้นโดยต้องหยิบยกหรือพิจารณาทบทวนถึงเหตุความจำเป็นดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 88 แล้ว เห็นว่า มาตรานี้บัญญัติให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาโดยจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้อยู่แล้ว ดังนั้น ศาลต้องสั่งปล่อยตัวจำเลยทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด เนื่องจากจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลและศาลมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยโดยตรงอยู่แล้ว

ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มบทบาทเชิงรุกของศาลให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเทียบเคียงจากหลักการยกเลิกการขังระหว่างพิจารณาของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดให้ศาลมีบทบาทในเชิงรุกของที่จะสามารถใช้ดุลพินิจในการยกเลิกการขังระหว่างการพิจารณาได้เมื่อความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาหมดไป (มาตรา 87) รวมทั้งเทียบเคียงการปล่อยชั่วคราวโดยดุลพินิจของศาล ในกรณีที่แม้เข้าข้อยกเว้นที่ศาลสามารถขังระหว่างพิจารณาได้ ศาลอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแก่จำเลยได้โดยใช้ดุลพินิจของศาลเมื่อมีเหตุที่เหมาะสม (มาตรา 90) นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบเคียงกับหลักการของประเทศฝรั่งเศส คือ ผู้พิพากษาสอบสวนต้องสั่งให้ปล่อยผู้ต้องหาทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเหตุการขังระหว่างสอบสวน และระยะเวลาขังเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร (มาตรา 144-1)

5.2.2 ควรมีการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาเพื่อเกิดกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบการขังระหว่างสอบสวนกับการขังระหว่างพิจารณาแล้ว พบว่าการเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในชั้นสอบสวนมีการตรวจสอบที่เข้มข้นกว่าในชั้นพิจารณามาก กล่าวคือ การขังระหว่างสอบสวนมีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ทั้งที่ความจริงแล้วการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวนฟ้องร้องนั้น ต้องใช้ระยะเวลาและความยุ่งยากซับซ้อนกว่าในชั้นพิจารณาคดีมาก กล่าวคือ การสอบสวนฟ้องร้อง ต้องเริ่มตั้งแต่การสืบสวน สอบสวนเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะกระทำผิด อีกทั้งยังต้องหาพยานหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลแล้วจะสามารถลงโทษจำเลยได้จริง แต่กฎหมายก็ยังคงให้ความสำคัญกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา ไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการดำเนินคดีอาญาของรัฐจนเกินควร โดยการจำกัดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนที่สั้น ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้องทำการสอบสวนจนแน่ชัดเสียก่อนที่จะควบคุมตัว เพราะหากไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัดเสียแล้ว การจะใช้ช่วงระยะเวลาที่จะสามารถควบคุมตัวได้เพื่อหาพยานหลักฐานจึงแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากกฎหมายให้อำนาจในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานไว้อย่างจำกัด

ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งใช้หลักการดำเนินคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย และดำเนินคดีตามหลักวาจา ตามหลักควรจะสามารถพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว เพราะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์จนแน่ชัดแล้วว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดและควรได้รับการลงโทษ ศาลเพียงแต่เป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานและค้นหาความจริงเพิ่มเติม และทำการพิพากษา ดังนั้น การขังระหว่างพิจารณาจึงควรให้ความสำคัญกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลยไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากการดำเนินคดีอาญาของรัฐโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล

สำหรับการขังระหว่างพิจารณานั้น แม้การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอกไม่อาจทำได้ กรณีก็ยังคงต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะอื่นที่สามารถกระทำได้โดยไม่เป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการต่อไป เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาในการขังระหว่างสอบสวนแล้วจะเห็นว่า การตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยไม่มีองค์กรภายนอกอื่นเข้าแทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการแต่อย่างใด การตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยการกำหนดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาจึงเป็นการตรวจสอบ

ถ่วงดุลที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบถ่วงดุลการขังระหว่างพิจารณามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้จำเลยได้รับการคุ้มครองตามหลัก Presumption of innocence มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มเติมการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อเกิดกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล โดยเทียบเคียงจากหลักการกำหนดระยะเวลาในการขังระหว่างพิจารณาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส ที่มีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่สามารถขังระหว่างพิจารณาและหากต้องการขยายระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาต่อก็ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ขยายได้และขยายระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดเป็นระยะก็เพื่อให้ศาลมีการตรวจสอบความจำเป็นของการขังระหว่างพิจารณาอยู่เสมอเมื่อครบกำหนดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาในแต่ละครั้งนั้น ๆ ซึ่งหากศาลสั่งขังครบกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่จะสามารถขังระหว่างพิจารณาแล้ว ย่อมต้องปล่อยจำเลยไป แม้ว่าการพิจารณาคดีจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตาม

5.2.3 การจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาควรเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน

เมื่อมีการเพิ่มการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยจำกัดระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาแล้ว เพื่อให้ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาจึงควรเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบได้กับการขังระหว่างสอบสวน ซึ่งกำหนดระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนของกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงให้มีระยะเวลาขังระหว่างสอบสวนยาวนานกว่ากรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษต่ำกว่ากล่าวคือ ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณานั้น สามารถกำหนดสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาเป็นการกำหนดโดยพื้นฐานของจุดมุ่งหมายของการขังระหว่างพิจารณาที่เป็นไปประกันการมีตัวของจำเลยประกอบกับความยุ่งยากซับซ้อนในการพิจารณาพิพากษา กล่าวคือ ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาควรมีสัดส่วนตามอัตราโทษจำคุกของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องหรือตามระดับความร้ายแรงของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องนั่นเอง และควรมีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาด้วย เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่จำเลยว่าจะต้องอยู่ในอำนาจรัฐในระยะเวลาที่ได้สัดส่วนและมีจำกัดระยะเวลาสูงสุด

ทั้งนี้ อาจกำหนดหลักการเกี่ยวกับระยะเวลาขังระหว่างพิจารณาโดยเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศส มาตรา 144-1 ที่กำหนดให้การขังต้องไม่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินควร โดยใช้หลักในการพิจารณาตามความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและความซับซ้อนของการสืบสวน ประกอบกับความจำเป็นของการสอบสวนซึ่งจำเป็นเพื่อค้นหาความจริง และมาตรา 145-1 และมาตรา 145-2 ที่ระยะเวลาที่ผู้พิพากษาสามารถสั่งขังได้นั้น สัดส่วนของระยะเวลาเป็นไปตามประเภทและความร้ายแรงของความผิด โดยมีระยะเวลาสูงสุดจำกัดในการขังระหว่างพิจารณาตามประเภทและความร้ายแรงของความผิด

นอกจากนี้ ในกรณีที่ยังมีความจำเป็นในการขังระหว่างพิจารณาอยู่ แต่การขังระหว่างพิจารณานั้นเกินกว่าระยะเวลาอันสมควร อาจเทียบเคียงกับหลักการของประเทศญี่ปุ่นตามมาตรา 91 (Unduly Prolonged) ซึ่งกำหนดให้ศาลสามารถพิจารณายกเลิกการขังระหว่างพิจารณานั้นได้

บรรณานุกรม

หนังสือ

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2543.

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ. มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม , 2548.

กุลพล พลวัน. การบริหารกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม , 2544.

กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์. การจัดการความรู้ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง. กรุงเทพมหานคร : งานดีครีเอชั่น , 2549.

_____. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาการร้องเรียนของกรมราชทัณฑ์.กรุงเทพมหานคร: งานดีครีเอชั่น, 2549.

เกียรติขจร วัจนะศักดิ์. คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการพิมพ์, 2547.

กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กรมราชทัณฑ์. คู่มือเจ้าพนักงานเรือนจำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. กรุงเทพมหานคร:ราชทัณฑ์, 2541.

คนึง ฦาไชย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ,พิมพ์ครั้งที่ 8 . กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548 .

คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ. รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษอาญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2547.

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2549.

_____. กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน , กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2553.

_____. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา , กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน ,2552.

_____. รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม , กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน ,2549.

_____. วิ. อาญาวิพากษ์, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน ,2552.

คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ; คณิต ณ นคร และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม , 2552.

ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2550.

_____. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2550.

นพนิธิ สุริยะ. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2537

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2552.

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์. สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ. กรุงเทพมหานคร , 2540.

สถาบันกฎหมายอาญา . รายงานการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกันค้นหาความจริงในคดีอาญาได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร : BJ.Plate Processor, 2540.

_____. สารานุกรมกระบวนการยุติธรรมนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : เซเว่น ,2540.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “การนำรูปแบบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป.” รายงานการวิจัยหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม , 2548.

_____. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา . พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2553.

วิทยานิพนธ์

บุศรา เกิดวิชัย. “สิทธิของจำเลยที่จะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

ปัญญา แสวงสุข. “กระบวนการตรวจสอบก่อนการพิจารณาคดี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

ทวีวัฒน์ ธาราจันทร์. “การชดใช้ค่าทดแทนโดยรัฐเนื่องจากการคุมขังอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล. “การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 2548.

ภัทร์รพี อุ่นใหม่ . “การพิจารณาคดีอาญาต่อหน้าจำเลย : ศึกษากรณีข้อยกเว้นและปัญหา”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550.

มาลี ทองภูสวรรค์. “การคุมขังและกักขังผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524.

รัตนา ธมรัตน์. "อำนาจรัฐในการควบคุมผู้ต้องหา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น" ,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

รุ่งรวี โหล่วประดิษฐ์. "บทบาทของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิดอาญา". วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 2543.

วิชัย ช้างหัวหน้า. "การบริหารจัดการคดีเพื่อการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม". สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.

วิภา ปิ่นวีระ. "บทบาทศาลในการพิจารณาคดีอาญา". วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550.

วิลาสินี รอตฤดี. "ปัญหากฎหมายในการเยียวยาแก่จำเลยในการพิจารณาคดีอาญาที่ผิดพลาด" วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.

สัญลักษ์ ปัญวัฒนลิขิต. "การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม". วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540.

_____. "ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน และชั้นศาล". วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552.

สมทรัพย์ นำอำนวย. "บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการค้นหาความจริงในคดีอาญา" วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541.

แสงทวี อินทวงศ์ , "การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในชั้นก่อนการพิจารณาของศาล : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว" วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.

อรวรรณ ไทยวานิช , "การปล่อยชั่วคราว". วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539.

บทความ

คณะกรรมการการบริหารและการยุติธรรม. “รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่ง”. บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 52 ตอนที่ 1 (มีนาคม 2539).

คณิต ณ นคร. “วิธีพิจารณาความอาญาไทย : หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน” . วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2528).

_____, “บทบาทของศาลในคดีอาญา” . วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2544).

นัทธี จิตสว่าง. “แนวทางการปฏิรูปการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย”. บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 54 ตอน 4 (ธันวาคม 2541).

ณรงค์ ใจหาญ. “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ดุลยภาพระหว่างสิทธิมนุษยชนกับประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม (ตอนที่ 1)”. วารสารนิติศาสตร์. เล่มที่ 33 ตอนที่ 1 (มีนาคม 2546).

วรวิทย์ ฤทธิทิศ. “ขังไว้ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา”. ดุลพาห. ปีที่ 43 เล่ม 4 (2539).

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “ความโปร่งใสและการตรวจสอบกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”. บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 54 ตอนที่ 4 (ธันวาคม 2541).

_____. “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะบางประการ”. ดุลพาห. ปีที่ 43 เล่มที่ 4 (2539).

บทความจากหนังสือรวมบทความ

คณิต ณ นคร. “ความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการยุติธรรม”. ใน รวมบทความด้านวิชาการของ ศ.ดร. คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อักษร , 2540.

_____. “การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐกับการปล่อยชั่วคราว” . ใน กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2553.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา”. ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ , จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536.

_____. “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจำเลยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย”. ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม , จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2538.

เอกสารอื่น ๆ

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สิทธิผู้ต้องหา จำเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา. กองทุนพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540.

ธิรพันธุ์ รัศมิทัต. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. 1958 และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฝรั่งเศส. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร. ธิรพันธุ์ รัศมิทัต 6 สิงหาคม 2541.

เพลินใจ แต้เกษม และคณะ .รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บรรเจิด สิงคะเนติ. การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ .
< http://www.pub-law.net/publaw/view.asp?PublawIDs=241>, 29 ตุลาคม 2544

http://www.correct.go.th .

http://www.kantei.go.jp .

http://www.legifrance.gouv.fr .

http://www.rlpd.moj.go.th .

Book

Shigemitsu Dando. Japanese criminal procedure. South Hackensack,N.J. : Fred B. Rothman & Co. , 1965.

ประวัติการศึกษา

ชื่อ	นางสาวศัลยา ชาญศรีสมุทร
วันเดือนปีเกิด	3 พฤศจิกายน 2527
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 59 ปีการศึกษา 2549